제1편【총론】<신의칙>
[추완항소 부적법 주장] **(일신모피)**
判例 i) 당사자 일방이 과거에 일정한 태도를 취하여 ii) 상대방이 이를 신뢰하고 소송상 지위를 구축했는데, iii) 신뢰를 저버리고 종전 태도와 모순되는 소송행위를 하는 것은 신의칙상 허용되지 않는다. iv) 따라서 추완항소 했던 피고 자신이 그 부적법을 스스로 주장하는 것은 허용될 수 없다.

[부적법한 표시정정 간과판결] **(법피본새)** 곽B 7회-2-1
判例 i) 법원이 부적법한 표시정정신청을 받아들이고 ii) 피고도 이에 명시적으로 동의하여 iii) 정정된 원고와 피고 사이에 본안판결이 선고되었다면, iv) 그 후에 새삼스럽게 이를 문제 삼는 것은 소송경제나 신의칙에 비추어 허용될 수 없다.

[항소권 실효]
1) 실효의 원칙 **(권신새)**
判例 i) 권리자가 장기간 권리를 행사하지 않아 ii) 상대방이 더 이상 권리자가 권리를 행사하지 아니할 것으로 신뢰할 만한 정당한 기대를 가지게 된 경우에, iii) 새삼스럽게 권리를 행사하는 것은 신의칙에 위반되어 허용되지 않는다.
2) 실효의 판단 **(길신쌍객통)**
判例 실효기간의 길이와 상대방의 권리가 행사되지 아니하리라고 신뢰할만한 정당한 사유가 있었는지는 쌍방의 사정 및 객관적 사정을 고려해 사회통념에 따라 합리적으로 판단한다.

[관할선택권 남용] **(목제남신)**
判例 i) 관할만을 발생시킬 목적으로 ii) 본래 제소할 의사가 없는 청구를 병합한 것이 명백한 경우에는 iii) 관할선택권의 남용으로서 iv) 신의칙에 반하므로, 관련재판적에 관한 규정이 적용될 수 없다.

제2편【소송의 주체】
제1장 법원 3개
<제척·기피·회피>
[제척이유] 41조1호 **(소공공)**
소송의 목적이 된 권리관계에 관하여 공통되는 법률상 이해관계가 있어 재판의 공정성을 의심할 만한 사정이 존재하는 지위에 있는 관계이다.

[기피이유 판단] **(평불주/편공)**
判例 i) 우리사회의 평균적인 일반인 관점에서 볼 때, ii) 법관이 불공정한 재판을 할 수 있다는 의심을 할 만한 객관적인 사정이 있고, iii) 그러한 의심이 단순한 주관적 우려나 추측을 넘어 합리적인 것이라고 인정될 때 기피이유에 해당한다. iv) 이 경우 실제로 법관에게 편파성이 존재하지 않거나, v) 헌법과 법률이 정한 바에 따라 공정한 재판을 할 수 있는 경우에도 기피가 인정된다.

{기피각하결정 확정 template} 이B 1회-2-2
(기피각하결정확정으로 하자 치유 여부)
긍정설: 소송경제 ·신속
부정설: 당사자의 절차권 보장
절충설: 기피신청자의 소송상 이익 침해하지 않은 때 하자 치유
判例
1) 기피신청 정지 중임에도 종국판결 한 경우
判例 기피신청을 당한 법관이 기피재판 확정 전에 한 판결은 그 후 기피신청이 이유 없는 것으로 기각결정이 확정된 때에는 유효하게 된다.
2) 기피신청 정지 중임에도 쌍방불출석 취하간주한 경우
判例 기피각하결정이 확정되었다는 사정만으로 쌍방불출석의 효과를 발생시킨 절차위반의 흠결이 치유된다고 할 수는 없다.
검토: 기피제도의 취지와 소송경제를 동시에 고려하였을 때, 당사자에게 충분한 절차권이 보장되었으면 하자가 치유된다고 보는 절충설 타당.

<관할>
사물관할 토지관할
합의관할
[약관규제법] **(지건/내개거관)**
1) '부당하게 불리한' 의미
判例 사업자가 거래상 지위를 남용하여 약관조항을 작성, 사용함으로써 건전한 거래질서를 훼손하는 등 고객에게 부당하게 불이익을 주었어야 한다.
2) '부당하게 불리한' 판단
判例 약관조항에 의해 고객에게 생길 수 있는 불이익의 내용과 불이익 발생의 개연성, 당사자의 거래과정에 미치는 영향, 관계 법령 등 제반사정을 종합해 판단한다.

[불분명]
통설: 법정관할 중에서 특정한 경우 전속적합의로, 그 외에는 부가적합의로
소수설: 당사자가 일부러 특정 법원을 지정한 이상 전속적합의
判例 이 사건 관할합의는 여러 법정관할 중 하나인 채권자 주소의 법원을 관할법원으로 약정한 것으로서 전속적 관할합의에 해당한다.
검토: 통설이 당사자의 통상의 의사에 부합

[주관적범위] **(지변정)**
특정승계인 중 채권승계인: i) 지명채권과 같이 당사자가 그 내용을 자유롭게 정할 수 있는 경우, ii) 당해 권리관계의 특정승계인은 그와 같이 변경된 권리관계를 승계한 것이어서, 관할합의의 효력은 특정승계인에게 미친다.
특정승계인 중 물권승계인: 통判 물권의 내용은 정형화 되어 있어서 당사자가 그 내용을 자유롭게 변경할 수 없으므로 합의 효력 받지 않는다.

변론관할
[청구기각 답변 본안변론인지]
긍정설: 원고의 청구를 배척한다는 뜻을 명백히 한 것이므로
부정설: 형식적 기준으로 보면 피고의 관할이익이 침해될 수 있는바
判例 반소기각 답변만으로는 412조 2항 소정의 반소의 본안에 관해 변론을 할 때에 해당한다고 볼 수 없다.

[진술간주 변론관할 인정여부] 이B 1회-1-1
判例 변론관할이 생기기 위해서는 현실적인 진술이어야 하므로 진술간주만으로는 변론관할 발생 부정하였다.

이송 (관할위반 이송, 34)
[원심법원제출주의 위반] **(대원기/혼원기진손)** 이A 2회-1-3
다수설: 34조는 상소심에도 적용될 수 있는 총칙규정
소수설: 이송 긍정시 판결확정시기를 불명확하게 함
判例
1) 원칙: 상고장이 대법원에 바로 제출되었다가 원심법원에 송부된 사건에서 "상고장이 원심법원에 접수된 때를 기준으로 상고제기기간 준수를 따져야 한다"고 한 바 기록송부로 처리한다.

2) 예외: 청사를 혼동해 다른 법원에 제출되었다가 원심법원에 이송된 사건에서 "원심법원 외 법원에 상고장을 제출한 날을 기준으로 상고기간 준수를 가림이 상고인의 진정한 의사에 부합하고 손해를 방지할 수 있다"고 하여 이송으로 처리했다.
검토: 기록송부로 처리하면 송부 소요시간이라는 우연한 사정에 의해 상소 적법여부가 결정되므로 이송을 긍정할 것이다.

[이송신청권 인정여부] **(법이) (법당항신)** 곽B 1회-4-2
긍정설: 피고의 관할의 이익 보호, 이송신청권 긍정하고 이송신청기각결정에 대해서 즉시항고 가능
判例
1) 이송신청권 존부
判例 관할위반으로 인한 이송신청을 한 경우 i) 법원의 직권발동을 촉구하는 의미밖에 없으므로 법원은 이송신청에 대하여는 재판을 할 필요가 없고, ii) 이송신청기각결정에 대하여도 항고가 허용될 수 없다.
2) 이송결정취소에 대한 재항고권 존부
判例 i) 법원이 직권발동으로 이송결정을 한 경우에는 즉시항고가 허용되지만(제39조), ii) 당사자에게 이송신청권이 인정되지 않는 이상 iii) 항고심에서 당초의 이송결정이 취소되었다 하더라도 이에 대한 iv) 신청인의 재항고는 허용되지 않는다고 본다.
검토: 34조 1항은 피고의 관할 이익을 보호하는 법원의 책무를 규정한 것 일뿐, 이송신청권을 부정하는 취지라고 해석함은 부당하다. (이창한은 判例와 반대로 검토)

[이송결정 기속력 전속관할 위반] **(불반상)**
긍정설: 38조에서 전속관할을 배제하지 않은 점
부정설: 전속관할 위반은 절대적 상고이유
判例
1) 원칙: 이송결정의 기속력은 i) 불복방법으로 즉시항고가 마련되어 있는 점이나, ii) 이송 반복에 의한 소송지연을 피해야 할 공익적 요청에 비추어 볼 때, 전속관할 규정 위배하여 이송한 경우에도 미친다.
2) 예외: iii) 상급심 법원에도 미치면 당사자의 심급이익을 박탈하는 바, 심급관할을 위배한 이송결정의 기속력은 상급심에는 미치지 않는다.
검토: 38조의 입법취지 및 심급이익 보호 고려할 때 판례 타당.

<재판권>
[인적범위] **(사주밀부사/사)**
절대적 주권면제주의: 외국국가의 행위에 대해 성질을 묻지 않고 모두 재판권이 면제
상대적 주권면제주의: 외국국가의 행위에 대해 면제 범위를 정해 일정한 경우에만 면제
判例 i) 외국의 사법행위가 ii) 주권적 활동에 속하거나 iii) 이와 밀접한 관련이 있어서 iv) 이에 대한 재판권 행사가 외국의 주권적 활동에 대한 부당한 간섭이 될 우려가 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한 v) 외국의 사법행위에 대해 우리나라 법원이 재판권을 행사할 수 있다.
검토: 외국이 사경제의 주체로서 활동하는 경우에는 사인과 같은 대우를 하면 족하다

[물적범위 template] 이C 1회-2-1, 이B 1회-1-1
(국제재판관할권 판단기준)
(제조물책임소송) **(제합제실)**
判例 i) 제조업자가 손해발생지에서 사고가 발생하여 그 지역의 법원에 제소될 것임을 ii) 합리적으로 예견할 수 있을 정도로 iii) 제조업자와 손해발생지 사이에 iv) 실질적 관련성이 있는지를 고려하여야 한다.
(실질적 관련을 판단함에는 당해 손해발생지내에서의 거래에 따른 이익을 향유하려는 피고의 의도적인 행위가 있었는지가 고려될 수 있다.)

(불법행위 손배 (ex 항공기추락))
判例 실질적 관련을 판단함에는 당해 손해발생지내에서의 거래에 따른 이익을 향유하려는 피고의 의도적인 행위가 있었는지가 고려될 수 있다. (원래 제조물책임소송에서 판시되었으나 항공기추락 사건, 국제거래 등 판례에서도 사용함)

(국국분/준자소판)
국제사법 2조는 가사사건에도 적용된다. 실질적 관련 유무는 i) 국내법의 토지관할 규정 뿐 아니라 ii) 당사자의 국적이나 주소·거소, iii) 분쟁의 원인이 되는 사실관계가 이루어진 장소, iv) 사건에 적용되는 준거법, v) 자료수집의 용이성, vi) 당사자들 소송 수행의 편의, vii) 판결의 실효성 등을 종합 고려해 판단한다.

(가압류) **(생예집실)**
判例 i) 원고와 피고는 소제기 당시 대한민국에 실질적인 생활기반을 형성했으며, ii) 피고는 대한민국에서 재산을 취득했으므로 자신을 상대로 대한민국 법원에 소를 제기할 것을 예상할 수 있고, iii) 피고의 재산에 대해 가압류한 상황에서 집행을 위해 대한민국법원에 소를 제기할 실익이 있는 점을 고려할 때, iv) 사안은 대한민국과 실질적관련성이 있다.

(고엽제) **(예자실)**
判例 i) 우리나라에서 피고들을 상대로 소제기할 수 있음을 충분히 예견할 수 있었던 점, ii) 손해액 산정에 필요한 자료 또한 우리나라에서 수집함이 편리한 점 등을 참작하면, iii) 당사자 및 사안은 대한민국과 실질적 관련성이 있다.

(강제징용) **(피역손실)**
判例 i) 피해자인 원고들이 모두 한국에 거주하고, ii) 사안이 한국의 역사·정치적 상황과 밀접한 관계가 있는 점, iii) 손해배상청구와 임금청구 사이에는 객관적 관련성이 있는 점에 비춰 iv) 당사자 및 사안은 대한민국과 실질적 관련성이 있다.

(강제징용 추가논점 217조3호) **(식헌승)**
判例 i) 일본판결의 이유에는 일본의 한반도와 한국인에 대한 식민지배가 합법적이라고 평가한 부분이 포함되어 있어 ii) 대한민국 헌법의 핵심적 가치와 정면충돌하므로, iii) 이 판결을 승인하는 결과는 한국의 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 위반된다.

(청어알사건) **(당팩송실)**
判例 i) 피고가 중국법원에 제기한 소가 각하되어 한국법원의 국제재판관할을 부정하면 당사자의 권리구제를 도외시하게 되는 점, ii) 한국에서 서류를 팩스로 전송받아 계약했고, iii) 정산금을 송금받기로 한 곳이 한국인 점을 고려할 때, iv) 당사자 또는 사안은 대한민국과 실질적 관련성이 있다.

(이혼사건) **(생이소집준)**
判例 i) 피고는 한국에 생활의 근거를 두고 거주했고, ii) 한국은 이혼사유와 관련된 곳이면서 분할재산이 된 재산소재지이다. iii) 원고

와 피고는 한국과 연고가 있어 한국에서 소송을 하는 데 어려움은 없고 iv) 한국에 있는 부동산을 가압류한 상황에서 실효성 있는 집행을 위해 한국 법원에서 재판을 받을 실익이 있다. v) 준거법이 외국법이라는 이유만으로 한국의 실질적 관련성이 부정되지 않는다.

[국제재판관할에서 변론관할] **(30공경실)**
判例 i) 국제재판관할에서 30조의 변론관할을 인정하더라도 ii) 당사자 사이의 공평을 해칠 우려가 없는 점, iii) 소송경제에도 적합한 점에 비추어 iv) 당사자 또는 분쟁이 된 사안과 대한민국 사이에 실질적 관련성이 없다 하더라도 국내법원에 변론관할을 인정할 수 있다.

제2장 당사자 3개
<당사자확정>
[공부상 오기]
(당사자확정)
의사설: 원고나 법원이 당사자로 삼으려는 자가 당사자
행동설: 당사자로 행동하는 자가 당사자
실질적표시설: 소장의 당사자의 표시 및 소장의 전 취지를 기준으로 하여 객관적으로 확정
判例 당사자는 소장에 기재된 표시 및 청구의 내용과 원인사실을 합리적으로 해석하여 확정한다.
검토: 명확한 기준을 제공하는 실질적표시설 타당

(항소심에서 표시정정) 이C 2회-2-1
判例 표시정정은 당사자를 변경하는 것이 아니므로 항소심에서 표시정정을 해도 심급이익을 박탈한다고 할 수 없고 따라서 상대방의 동의가 필요하다고 할 수도 없다.

(간과판결 효력) **(표잘무효확)** 이C 2회-2-2
判例 i) 소장의 당사자표시가 착오로 잘못 기재되었음에도 표시정정이 이루어지지 않아 ii) 잘못 기재된 당사자를 상대로 판결이 확정되어도 iii) 그 판결을 당연 무효라고 볼 수 없고, iv) 판결의 효력은 잘못 기재된 당사자와 동일성이 인정되는 범위 내에서 v) 확정된 당사자에게 미친다.

[학교]
(발견시 보정방법)
피고경정설: 당사자능력 없는 자가 피고로 확정되므로 당사자능력 있는 자로 바꾸면 동일성이 없는 피고경정
표시정정설: 당사자능력자가 실질적 당사자로 확정되므로 올바른 당사자능력자로의 보정은 동일성이 인정되는 표시정정
判例 소장에 표시된 당사자에게 당사자능력이 인정되지 않는 경우에는, 올바른 당사자능력자로 그 표시를 정정하는 것은 허용된다
검토: 당사능력이 없는 자를 당사자로 잘못 표시한 것이 명백한 경우 오기에 준해 볼 수 있으므로

(법원의 조치-표시정정을 위한 석명) **(능청확표)** 곽 기초 2회-2-1
判例 i) 당사자능력이 없는 자를 당사자로 잘못 표시했다면 ii) 청구의 내용과 원인사실을 종합해 당사자 확정하고, iii) 확정된 당사자가 소장 표시와 다르거나 분명치 않을시, iv) 표시를 정정시키는 조치를 취해야 한다.

[성명모용]
(규정이 없는 임의적 당사자변경 가부) **(표필/해)**
긍정설: 당사자의 편의와 소송경제
부정설: 절차불안과 소송지연
判例 i) 표시정정신청을 한 경우에도 실질적으로 당사자가 변경되는 것은 허용할 수 없고, ii) 필수적 공동소송이 아닌 사건에서 소송 중에 당사자를 추가하는 것 역시 허용될 수 없다.
검토: 규정에 없는 임의적 당사자변경의 허용은 해석론의 한계를 넘는 것이다.

(잘못 지정 분명한 경우) **(취원법법)**
학설: 당사자의 편의와 소송경제를 이유로 실제 의무자가 누구인지 증거조사를 해 보아야 판단될 수 있는 경우에도 피고경정을 넓게 인정
判例 피고를 잘못 지정한 것이 분명한 때란 i) 청구취지나 청구원인 기재 자체로 보아 ii) 원고가 법률적 평가를 그르치는 등의 이유로 피고 지정이 잘못된 것이 명백하거나 iii) 법인격 유무에 관해 착오를 일으킨 것이 명백한 경우이다.
검토: 증거조사를 통해 비로소 판명될 수 있는 경우라면 잘못 지정한 것이 분명한 경우라고 할 수 없으므로 판례 타당.

[제소전사망]
(당사자확정)
제소 전 죽은 자를 피고로 한 경우 보정되지 않으면 죽은 자가 피고이므로 소가 부적법하다. (1순위 상속포기 추가: 따라서 사안의 경우 보정되지 않으면 1순위 상속인을 피고로 보게 된다.)

(발견시 보정방법) **(실표상/오)** 이C 1회-3-2, 곽B 1회-3-1
피고경정설: 피고경정이 도입된 이상 죽은 자와 상속인은 동일하지 않으므로
判例 (표시정정설): i) 상속인이 처음부터 실질적인 피고이고 ii) 다만 그 표시를 잘못한 것으로 인정된다면, iii) 상속인으로 피고의 표시를 정정할 수 있다
(1순위 상속포기 추가: 실질적 피고로 해석되는 상속인은 실제 상속인이고, 제1순위 상속인이라도 상속을 포기한 경우에는 이에 해당하지 않으며, 후순위 상속인이라도 실제로 상속인이 되면 이에 해당한다.)
(피고경정서 제출 효과: 표시정정의 성질을 지니는 이상 비록 소송에서 피고표시를 바꾸면서 피고경정의 방법을 취했다 해도 표시정정으로서의 법적성질 및 효과는 잃지 않는다.)
검토: 당사능력이 없는 자를 당사자로 잘못 표시한 것이 명백한 경우 오기에 준해 볼 수 있으므로

(간과판결 효력과 구제수단) **(대무항수)** 곽B 1회-3-1
학설: 판결을 무효로 보지만 유효한 것처럼 보이는 외관을 제거하기 위해 상소의 대상이 된다
判例 사망자를 피고로 하는 소제기는 i) 대립당사자구조를 요구하는 민사소송법상의 기본원칙이 무시된 부적법한 것으로서 ii) 그 상태에서 선고된 판결은 당연무효이며, iii) 그 판결에 대한 항소나 소송수계신청은 부적법하다. (재심도 부적법)
검토: 대립당사자구조가 무시된 것이므로 무효라고 할 것이며, 판결의 효력이 없는 이상 외관 제거를 위한 상소를 인정할 필요는 없다.

시효중단효력 인정여부 **(무의시170)** 심1회-3-2
判例 i) 제소 전 사망을 간과한 판결은 당연무효로서 그 효력이 상속인에게 미치지 않고, ii) 채권자의 이러한 제소는 의무자에 대한 권리행사라 볼 수 없으므로 iii) 거기에는 애초부터 시효중단 효력이 없어 iv) 민법 170조 2항이 적용되지 않는다.

<당사자자격>

당사자능력

[조합]

(조합과 비법인사단 구별) **(사조단)**

判例 i) 어떤 단체가 고유의 목적을 가지고 사단성을 갖는 규약을 만들어 ii) 이에 근거해 의사결정기관 및 집행기관인 대표자를 두는 등의 조직을 갖추고, iii) 단체로서의 주요사항이 확정된 경우에는 비법인사단의 실체를 가진다.

(조합의 당사자능력)

긍정설: 조합도 사회적으로 하나의 단체로 활동

부정설: 조합은 구성원 개성이 뚜렷

判例 "민법은 조합과 권리능력 없는 사단을 구별하고, 전자의 재산관계를 합유로 후자는 총유로 규정하고 있어 같이 다룰 수 없다"고 하면서 "민법상 조합의 실체를 가지고 있는 경우 당사자능력이 없다"고 한다.

검토: 52조가 당사자능력을 제한적으로 규정한 이상

[공동수급체 공동소송] 이A1회-2-2

원칙 **(조/구합/1지)**

判例 i) 공동수급체는 민법상 조합의 성질을 가지므로, ii) 공동수급체의 공사대금채권은 원칙적으로 구성원에게 합유적으로 귀속하는 것이어서 iii) 1인이 임의로 도급인에 대해 지분비율에 따른 급부를 청구할 수 없다.

예외 **(개지도권/구지구/묵)**

判例 i) 공동수급체와 도급인이 개별구성원으로 하여금 지분비율에 따라 직접 도급인에 대해 권리를 취득하게 하는 약정을 한 경우 ii) 공사대금채권이 구성원 각자에게 지분비율에 따라 구분하여 귀속될 수 있고, iii) 위 약정은 묵시적으로도 이루어질 수 있다.

(규정이 없는 임의적 소송담당)

① 허용기준 **(변신합)**

判例 변호사대리원칙이나 소송신탁금지를 잠탈하는 탈법적 방법에 의하지 않은 것으로서 이를 인정할 합리적 필요가 있는 경우에 한해 허용된다.

② 합리적 필요 있는 경우 **(이지)**

담당자가 소송물에 대해 고유의 이익이 있거나, 실체법상 관리처분권을 가지고 권리관계 주체 못지않은 지식이 있는 경우에 인정된다.

③ 조합의 경우

判例 업무집행권한을 수여받은 업무집행조합원은 조합재산소송에 관해 조합원으로부터 임의적 소송신탁을 받아 자기 이름으로 소송하는 것이 허용된다.

[비법인사단]

(구성원 보존행위의 경우) **(명전구/공)**

종래判例 보존행위의 경우 총회결의를 거치면 구성원이 제소를 할 수 있다는 입장

전합判例 i) 비법인사단 명의로 총회결의를 거쳐 하거나 또는 ii) 구성원 전원이 당사자가 되어 필수적 공동소송형태로 할 수 있을 뿐 iii) 구성원은 설령 그가 사단의 대표자라거나 총회결의를 거쳤어도 그 소송의 당사자가 될 수 없고, 이는 총유재산의 보존행위로 제소할 경우도 같다.

검토: 공유나 합유처럼 보존행위는 구성원 각자가 할 수 있다는 규정을 두지 아니한 바

당사자적격

[당사자적격 판단기준] **(이청의/등말적)** 이C 1회-1-1

통설: i) 이행의 소에서 ii) 원칙적으로 자기에게 이행청구권이 있음을 주장하는 자가 원고적격을 가지며 iii) 그로부터 이행의무자로 주장된 자가 피고적격을 가진다. 말소등기청구의 경우도 말소의무자로 주장되면 피고적격 인정한다.

判例 통설처럼 주장자체로 판단한다. 다만 i) 등기의무자, 즉 등기부의 형식상 그 등기에 의해 권리를 상실하거나 기타 불이익을 받을 자가 아닌 자를 상대로 한 ii) 말소등기청구는 iii) 당사자적격이 없는 자를 상대로 한 부적법한 소이다.

검토: 주장 자체만으로도 당사자적격이 없다고 판단된다면 본안심리에 들어갈 필요가 없으므로 등기의무자가 아닌 경우 판례 타당.

[불법점유 건물인도청구] **(불현소인)**

判例 "i) 불법점유를 이유로 한 건물인도청구에 있어서는 ii) 현실적으로 불법점유하고 있는 사람을 상대로 하여야 한다"는 입장이다. iii) 소유권에 기한 반환청구는 직접점유자만을 상대로 하여야 하고 간접점유자를 상대로는 할 수 없다고 하는 반면, iv) 인도 약정에 따른 이행청구는 간접점유자에 대하여도 할 수 있다.

(이청의/등말적 선결논점)

[저당권이전 부기등기後 말소등기청구 피고적격] **(승새양)**

이C 1회-1-1

判例 저당권이전의 부기등기는 i) 기존의 저당권설정등기에 의한 권리의 승계를 등기부상 명시하는 것뿐으로, ii) 새로운 권리가 생기는 것이 아닌 만큼 iii) 저당권설정등기의 말소등기청구는 양수인만을 상대로 하면 족하고 양도인은 피고적격이 없다.

(지적의무) **(재변각법재)**

判例 i) 피고적격 문제를 재판의 기초로 삼기 위해선 ii) 원고로 하여금 변론을 하게 하는 등 기회를 주었어야 함에도 iii) 그렇지 않고 이를 기초로 소를 각하한 것은 iv) 원고가 예상하지 못한 법률적인 관점에 기한 v) 예상 외의 재판으로서 석명의무를 다하지 않은 위법이 있다.

[저당권이전 부기등기後 말소등기청구 소의 이익]

(일직부/이무효부) 이C 1회-1-1

判例 저당권이전의 부기등기는 i) 주등기인 저당권설정등기에 종속되어 일체를 이루는 것이어서 ii) 주등기의 말소만 구하면 되고 부기등기는 주등기의 말소에 따라 직권으로 말소되므로 iii) 부기등기 말소청구는 소의 이익이 없다.

다만, 저당권 이전원인만이 무효·취소·해제된 경우, 부기등기에 한해 무효사유가 있어 부기등기만의 효력을 다투는 경우에는 부기등기말소청구의 소의 이익이 있다.

[입주자대표회의] **(집재집자)** 이A 2회-1-1

判例 i) 집합건물관리단이 입주자대표회의에 공용부분 변경에 관한 업무를 포괄 위임한 경우, ii) 비용에 관한 재판상·재판외 청구를 할 수 있는 권한도 함께 수여한 것으로 볼 수 있다.

iii) 집합건물관리단으로부터 공용부분 변경에 관한 업무를 위임받은 입주자대표회의는 iv) 구분소유자들을 상대로 자기 이름으로 소제기하여 공용부분 변경에 따른 비용을 청구할 권한이 있다.

소송능력

[미성년자에 대한 송달]

유효설: 법적안정성을 근거로 송달은 유효하고, 상소기간이 진행하

며 판결이 확정된다.
무효설: 미성년자 보호를 근거로 송달은 무효이고, 상소기간이 진행하지 않아 판결이 확정되지 않는다.
判例 미성년자였던 피고에 대해 실시한 송달은 판결이 소송무능력을 이유로 소각하한 것이라는 등 특별한 사정이 없는 한 부적법하여 무효이다.
검토: 언제든지 항소할 수 있게 해야 미성년자가 더 보호된다.

변론능력
(선정당사자에게 선임명령한 경우) **(내의당144변)** 곽1회-2-1
判例 i) 선정당사자는 선정자들과의 내부관계에서 소송대리인과 유사하고, ii) 변호사 선임시 선정자 의견을 고려하므로, iii) 선정당사자에게 변론을 금하고 변호사 선임명령한 경우에도 iv) 144조 3항을 유추하여 선정자들에게 그 취지를 통지해야 하고, v) 그러한 조치 없이 변호사 선임이 없다 하여 소각하 할 수 없다.

<소송상대리인>
법정대리인
[소송상 특별대리인] 이B 2회-3-1
(요건)
'대표자가 없는 경우'란 회사를 대표할 이사, 감사 등이 모두 없는 것. '대표권을 행사할 수 없는 경우'란 법률상 장애 또는 사실상 장애가 있는 것. '불성실·미숙한 대표권 행사의 경우'도 개정법이 본인보호를 위해 추가했다. 지연으로 손해볼 염려가 있음을 소명해야 한다.

(특별대리인의 권한 - 소 제기, 상소 제기 등 특별수권 요부)
이B 2회-3-1
학설: 후견인처럼 소 또는 상소제기의 특별수권이 필요하다는 견해, 광범위한 대리권을 인정하려는 특별대리인제도의 취지상 특별수권이 필요 없다는 견해
判例 64조에 의해 준용되는 62조의 규정에 따라 선임된 특별대리인은 대표자와 동일한 권한을 가져 그 소송수행에 관한 일체의 소송행위를 할 수 있다. 따라서 특별대리인은 법인을 대표해 상소를 제기하거나 상소취하할 권리가 있다.
검토: 개정법(62③)은 '대리권이 있는' 후견인과 같은 권한이 있다고 규정한 점에 비추어 판례 타당.

[공동대리원칙-모순행위 처리] 곽1회-2
56조2항 유추설: 56조2항의 중요한 소송행위는 명시적으로 공동으로 해야 하지만, 기타의 행위는 단독으로 하고 다른 대리인이 묵인하면 묵시적으로 공동으로 한 것으로 본다.
67조 준용설: 유리한 행위는 혼자해도 되지만, 불리한 행위는 전원이 함께 해야 효력이 생긴다.
검토: 대리에 관한 문제이므로 그에 관한 규정인 56조2항 유추함이 타당

[소멸통지]
(대리·대표권 소멸통지 내용) **(알과통절대)**
判例 i) 63조 1항의 취지는 대표권 소멸사실을 알았는지 여부, ii) 모른 데에 과실 여부를 불문하고 iii) 그 사실 통지 유무에 의해 대표권 소멸 여부를 획일적으로 처리함으로써 iv) 절차 안정과 명확을 기하기 위함이므로, v) 대표권이 소멸된 경우에도 통지까지는 소멸되지 않은 것으로 보아야 한다.

임의대리인
[소송대리권의 범위-사법행위] **(변위실)** 곽2회-1-1
문제점: 90조1항에서 규정한 변제의 영수가 실체법상 사법행위를 포함하는지
判例 소송목적인 채권의 변제를 채무자로부터 수령하는 권한을 비롯해 위임을 받은 사건에 관한 실체법상 사법행위를 하는 권한도 포함된다.

[여러 소송대리인에게 송달] **(93180효항)** 곽B 4회-1-2
判例 i) 여러 소송대리인이 있는 때에는 93조에 의해 각자가 당사자를 대리하므로, ii) 180조가 적용될 여지가 없어 판결정본을 여러 소송대리인에게 각각 송달해야 하지만, iii) 그 경우에도 송달의 효력은 소송대리인 중 1인에게 최초로 판결정본이 송달되었을 때 발생한다. iv) 따라서 항소기간은 소송대리인 중 1인에게 최초로 판결정본이 송달되었을 때부터 기산된다.

[심급대리] 이C 2회-4-1
긍정설: 90조 2항 3호는 상소의 제기라고 했지만 해석상 상대방의 상소에 응소하는 것도 특별수권사항에 포함되므로 대리권은 심급종료로 소멸
부정설: 상소의 제기만 특별수권사항으로 했으므로 상대방의 상소에 응소하는 행위는 통상의 대리권에 포함된다고 보아 대리권은 사건종료로 소멸
判例 위임받은 소송대리권의 범위는 특별한 사정이 없는 한 당해 심급에 한정된다.
검토: 심급종료시마다 대리인의 활동을 평가하여 상급심에서도 위임할지 결정하게 함이 타당

[파기환송 후 항소심 대리권부활] 이C 2회-4-1
긍정설: 파기환송 후의 절차는 항소심 절차의 속행에 해당하므로
부정설: 항소심 대리인과는 신뢰관계가 깨졌다고 볼 수 있기 때문
判例 i) 상고 전 항소심 소송대리인의 대리권은 그 사건이 항소심에 계속되면서 부활하므로 ii) 환송받은 항소심에서 환송 전 항소심의 소송대리인에게 한 송달은 당사자에게 한 송달과 마찬가지 효력이 있다.
검토: 당사자가 대리인을 신뢰할 수 없다면 언제든지 대리인을 해임할 수 있으므로

[보수 청구시기] **(속대소위)** 이C 2회-4-1
원칙: 수임인은 위임사무를 완료해야 보수를 청구할 수 있음이 원칙이다. (민법 686조2항) 判例 항소심 소송대리인의 위임사무는 특별한 약정이 없는 한 항소심판결이 송달된 때 종료되므로 이 때 보수를 청구할 수 있다.
파기환송된 경우: 判例 i) 환송받은 항소심이 환송 전의 절차를 속행해야 하고 ii) 환송 전 소송대리인의 대리권이 부활하므로, iii) 환송 후 항소심 사건의 소송사무까지 처리해야만 iv) 위임사무의 종료에 따른 보수를 청구할 수 있다.

[재상고심에서 상고심 대리권부활] **(심파다항상)**
判例 i) 소송대리권은 당해 심급에 한정되므로 ii) 파기환송된 사건이 다시 상고된 경우 iii) 항소심 소송대리인은 그 대리권을 상실하고 iv) 환송 전 상고심 대리인의 대리권이 그 사건이 다시 상고심에 계속되면서 부활하게 되는 것은 아니다.

[재심소송에서 재심 전 대리권부활] **(신분특재)**
判例 i) 재심의 소는 신소제기라는 형식을 취하고 ii) 재심 전의 소송과 일응 분리되어 있으며, iii) 사전·사후의 특별수권이 없는 이상 iv) 재심 전 소송의 소송대리인이 당연히 재심소송의 대리인이 되는 것이 아니다.

무권대리인
[표현대리]
긍정설: 소송도 거래관계의 연장인바 상대방으로서도 등기부 외에 대표자를 확실히 조사할 방법은 없어 보호필요
부정설: 표현대리는 거래안전을 위한 것인데 소송절차는 거래가 아이므로
判例 집행인낙의 표시는 공증인에 대한 소송행위로서 이러한 소송행위에는 민법상의 표현대리 규정이 적용될 수 없다
검토: 상대방의 선의·악의를 따져 소송행위의 유·무효를 판단하면 절차안정을 해하므로

[쌍방대리] **(이알변/소선)** 곽B 1회-4-1
(변호사 쌍방대리의 효력)
절대무효설: 변호사법 31조는 강행규정으로 해석
유효설: 본 조를 훈시규정으로 해석
추인설: 무권대리로 해석하여 후위임자의 추인이 있으면 유효
이의설: 임의규정으로 해석하여 선위임자가 이의하지 않으면 하자치유
判例 쌍방대리행위에 대해 상대방이 이의하는 경우 그 소송행위는 무효이지만, 그 사실을 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 사실심변론종결시까지 이의하지 않았다면 그 소송행위는 완전한 효력이 생긴다.
검토: 절대무효설은 쌍방대리행위에 대해 소송 어느 단계에서든 무효를 주장할 수 있어 소송경제에 反, 유효설과 추인설은 선위임자가 무효를 주장할 수 없어 절차권 박탈 우려

제3편【1심 소송절차】
제1장 소송의 개시 4개
<소>
[공유물분할청구소송 template] 이C 5회-1-3, 이B 7회-1-1
(공유물분할청구소송의 성질) **(절청자비)**
통判은 i) 절차적으로 소송사건 중 장래 법률관계의 창설을 구하는 형성소송이지만, ii) 분할을 청구하는 자가 구하는 방법에 구애받지 않고 iii) 자유로운 재량에 따라 합리적인 방법으로 공유물을 분할할 수 있다고 하여 iv) 비송사건의 성질도 갖는다는 형식적 형성소송설의 입장이다.

(현물분할 방법) **(다금지)**
判例 i) 원고가 구한 것과 다른 방법에 의한 현물분할방법, ii) 금전으로 가치 과부족을 조정하면서 현물분할방법, iii) 분할청구자의 지분한도 안에서 현물분할하고 분할을 원하지 않는 자는 공유로 남는 방법도 허용된다.

(대금분할 방법) **(분가경)**
判例 i) 현물로 분할할 수 없거나 ii) 현물분할하면 현저히 가액이 감손될 염려가 있는 때에 비로소 iii) 물건의 경매를 명하여 대금분할 할 수 있다.

[공유물분할조서 형성력 인정여부] **(공협등소/판187/협)**
이B 7회-1-2
判例 다수의견: 조정이 성립했어도, i) 그 즉시 공유관계가 소멸하고 ii) 협의에 따른 새로운 법률관계가 창설되는 것은 아니고, iii) 다른 공유자의 지분을 이전받아 등기를 마침으로써 iv) 비로소 단독소유로 하기로 한 부분에 대한 소유권을 취득한다.
判例 소수의견: 조정조서는 공유물분할판결과 동일한 효력을 가지는 것으로서 민법 187조 소정의 판결에 해당하므로 조정이 성립한 때 물권변동 효력이 발생한다.
검토: 조정은 본질적으로 당사자들 사이에 협의에 의한 분할과 다를 바 없다.

<소송요건>
소송요건 일반론
{직권조사사항 template}
(대표권 직권조사사항) **(대소의상조)** 이C 2회-3-3
判例 i) 법인의 대표자에게 적법한 대표권이 있는지 여부는 ii) 소송요건으로서 법원의 직권조사사항이므로, iii) 이미 제출된 자료들에 의해 대표권의 적법성에 의심이 갈만한 사정이 엿보인다면 iv) 상대방이 구체적으로 지적하여 다투지 않더라도 v) 이에 관해 조사할 의무가 있고, 비법인 사단인 경우에도 같다.

(피보전채권 직권조사사항) **(피소의조)**
判例 i) 채권자대위소송에서 피보전채권이 존재하는지 여부는 ii) 소송요건으로서 법원의 직권조사사항이므로, iii) 피보전채권의 존부에 관하여 의심할 만한 사정이 발견되면 vi) 직권으로 조사할 의무가 있다.

[당사자적격 회복] **(압피소상)** 이A 8회-4-1
判例 i) 압류 및 추심명령에 대한 압류해제 및 추심포기서가 제출되어 ii) 피압류채권의 채권자가 소를 제기할 수 있게 된 경우, iii) 소송요건은 직권조사사항으로서 iv) 상고심에서도 그 치유를 인정해야 한다.
(피압류채권의 채권자는 채무자를 의미함)

[기판력 저촉 발생]
判例 확정판결의 존부는 법원이 직권으로 조사하여 판단해야 하며, 이 사정이 사실심 변론종결 이후 발생한 경우 상고심에서도 이를 참작해야 한다.

[소송요건 선순위성]
긍정설: 소송요건이 본안심리의 요건
부정설: 소송요건과 실체법상 요건은 동일 평면의 승소판결 요건
判例 소송요건에 흠이 있는 경우, 소송은 부적법하다 하여 각하해야 하고 본안판단을 할 수 없다.
검토: 소송능력이나 대리권 등을 판단하지 않고 기각판결하면 당사자의 절차권 침해

소의 이익
[대장명의말소청구] **(권소말/행사)**
소수설: 대장에 소유권자로 등재되어 있으면 소유권 귀속에 관하여 추정을 받으므로 말소청구는 소의 이익이 있다.
다수설: 등기부와 같은 비중의 추정력, 즉 입증책임의 전환까지 초래하는 추정력을 갖는다고 해석되지 않으므로 말소청구는 소의 이익이 없다.
判例 i) 대장은 권리변동의 공시방법이 아닌 만큼, ii) 소유권을 부인하는 자에 대해 소유권확인을 청구함으로써 충분하고, iii) 대장명의말소청구는 소의 이익이 없다.
검토: 대장은 행정편의를 위해 작성되고 사실관계를 공시하는 장부에 불과하므로

[순차이전등기말소청구] **(후전전)** 곽B 1회-2-2
判例 순차적으로 소유권이전등기가 경료된 경우 i) 후순위등기 말소청구가 인용되지 않아 ii) 전순위등기의 말소 실행이 불가능하더라

도 iii) 전순위등기의 말소를 이행할 의무가 인정되면 말소 이행을 명해야 한다.
검토: 분쟁의 관념적 해결절차, 피고에 대한 심리적 압박

[가압류된 금전채권 이행청구] **(가집/시/배취소)** 이B 6회-2-1
문제점 - 가압류의 처분금지효
判例 소의 이익을 긍정한다. i) 채무자로서는 제3채무자에 대한 그의 채권이 가압류되어 있다 하더라도 집행권원을 취득할 필요가 있고, ii) 시효를 중단할 필요도 있으며 iii) 가압류를 이유로 청구가 배척된다면 가압류가 취소된 후 다시 소제기해야 하는 불편함이 있기 때문이다.

[가압류된 이전등기청구권에 대한 이행청구] **(신저조)**
判例 소유권이전등기를 명하는 판결이 확정되면 (i) 채무자는 이전등기 신청이 가능하고 (ii) 제3채무자는 이를 저지할 방법이 없으므로, (iii) 가압류해제를 조건으로 청구를 인용하여야 한다.

[효과 없는 의사진술을 구하는 청구] **(판간/간소있소)**
判例 i) 의사진술을 명하는 판결은 확정과 동시에 의사를 진술한 것으로 간주되므로, ii) 의사진술이 간주됨으로써 어떤 법적효과를 갖는 경우에는 iii) 소구할 이익이 있지만, iv) 의사진술이 있더라도 아무런 법적 효과가 발생하지 아니할 경우에는 v) 소구할 법률상 이익이 없다.

[불법점유 부당이득반환청구, 손해배상청구] **(수확)** (청구적격)
1) 불법점유의 경우
i) 일반불법점유의 경우, 인도완료일까지의 부당이득반환청구를 해야 한다. ii) 도로불법점유의 경우, 종래 判例는 "피고의 점유종료일 또는 원고의 소유권 상실일"까지의 부당이득반환청구를 해야 한다고 했으나 최근 判例는 "원고 소유권 상실일까지라는 기재는 수소법원이 판단해야 할 사항인 소유권 변동 여부를 다른 기관의 판단에 맡기는 형태의 주문이고, 확정된 이행판결의 집행력에 영향을 미칠 수 없는 무의미한 기재"라고 판시하였다.
2) 사안

[적법점유 부당이득반환청구] **(사의변)**
1) 적법점유의 경우
피고의 점유가 동시이행항변권, 유치권에 따라 적법한 경우,
判例는 "피고가 인도하는 날 이전에 사용수익을 종료할 수 있기 때문에 의무불이행사유가 인도하는 날까지 존속함을 변론종결시에 확정적으로 예정할 수 없다"고 판시한다.
2) 사안

[채권양도통지 조건 이행청구] **(대법양장)**
判例 i) 대항요건을 갖추지 못했다면 ii) 채권양수인은 채무자와 사이에 아무런 법률관계가 없어 iii) 채무자에 대하여 양도통지를 받은 다음 채무를 이행하라는 청구는 iv) 장래이행의 소로서의 요건을 갖추지 못해 부적법하다. (청구권 발생의 기초가 되는 사실상·법률상 관계 존재X. 이창한은 반대로 검토)

[선해-매매계약무효확인, 해제확인] **(과채간)** 곽 1회-3-1
判例 i) 매매계약무효확인청구는 과거 법률행위인 매매계약무효확인을 구하는 것으로 볼 것이 아니라 ii) 현재 매매계약에 기한 채권채무가 존재하지 않는다는 확인을 구하는 취지를 iii) 간결하게 표현한 것으로 선해해야 한다.

[유치권부존재확인]
(확인의 이익) **(저거법유)**
判例 i) 저가낙찰로 인해 경매를 신청한 근저당권자인 원고의 배당액이 줄어들거나 ii) 거액의 유치권 신고로 매각 자체가 불가능하게 될 위험은 iii) 경매절차에서 원고의 법률상 지위를 불안하게 하므로 iv) 유치권부존재확인의 소는 확인의 이익이 있다.

(유치권일부부존재확인 가부) **(전경유법/피법)**
원심은 유치권의 불가분성을 이유로 부정하였으나,
判例 i) 유치권 전부 부존재 뿐만 아니라 ii) 경매절차에서 유치권을 내세워 대항할 수 있는 범위를 초과하는 iii) 유치권부존재확인을 구할 v) 법률상 이익이 있다.
검토: 피담보채무의 범위에 따라서 원고의 법률상 지위의 불안 정도가 달라지므로 대법원 判例 타당

(저당권 소멸시) **(경매유법)**
判例 경매절차에서 유치권이 주장되었으나, 담보목적물이 매각되어 근저당권이 소멸했다면, 근저당권자는 유치권 부존재 확인을 구할 법률상 이익이 없다.

(처분권주의) **(피경일)**
判例 i) 심리결과 피고가 유치권의 피담보채권으로 주장하는 금액의 일부만이 ii) 경매절차에서 유치권으로 대항할 수 있는 것으로 인정된 경우 iii) 그 유치권 부분에 대해 일부패소판결을 해야 한다.

(증명책임)
判例 유치권부존재확인소송에서 유치권의 요건사실인 유치권의 목적물과 견련관계 있는 채권의 존재에 대해 피고가 주장·증명해야 한다. (소극적확인소송에서 원고가 권리장애·멸각·저지규정 요건사실 증명책임, 피고가 권리근거규정 요건사실 증명책임)

[담보지상권 피담보채무부존재확인] **(당지지법)**
담보지상권은 i) 당사자의 약정에 따라 담보권의 존속과 지상권의 존속이 서로 연계되어 있을 뿐이고, ii) 지상권의 피담보채무가 존재하는 것은 아니라고 본다. iii) 지상권설정등기에 관한 피담보채무의 부존재 등 범위 확인을 구하는 청구는 iv) 법률상의 지위에 관한 청구라고 보기 어려우므로, 확인의 이익이 없다.

[국가상대확인] 이C 2회-3, 이B 8회-2-1, 곽B 1회-1-1
(미등기 토지) **(대판보)**
判例 토지가 미등기이고 대장에 등록명의자가 없거나 등록명의자가 누구인지 알 수 없을 때 i) 원고가 토지의 소유자임을 대장등본으로 증명할 수 없다면 ii) 판결에 의하여 증명함으로써 보존등기를 할 수 밖에 없으므로 iii) 보존등기를 하기 위한 소유권의 증명 때문에 제기한 확인의 소는 소의 이익이 있다.

(제3자 명의 등기 토지) **(등국법)**
判例 i) 등기명의자에 대한 승소판결만으로도 등기명의자의 소유권보존등기를 말소하고 보존등기를 신청할 수 있으므로, ii) 국가를 상대로 한 소유권확인청구는 iii) 토지소유권을 둘러싼 법적 불안정성을 해소하는 데 필요하고도 적절한 수단이 될 수 없어 확인의 이익이 없다.

(미등기 건물) **(가분국법)**
判例 i) 가옥대장 관리업무는 국가의 사무라고 할 수 없고, ii) 국가는 소유권 귀속에 관한 분쟁의 당사자가 아니어서 확인해줄 지위에

있지 않다. iii) 국가를 상대로 한 건물소유권확인소송은 iv) 법률상 지위의 불안제거에 실효성이 없는 것으로서 확인의 이익이 없다.

(국가시효취득완성) **(이행변국법)**
判例 국가가 미등기 토지를 시효취득한 경우, i) 토지의 소유자는 국가에게 소유권이전등기절차를 이행할 의무를 부담하므로 ii) 국가에 대하여 그 소유권을 행사할 지위에 있다고 보기 어렵고, iii) 또 소유권확인판결을 받는다고 하여 이러한 지위에 변동이 생기는 것도 아니므로, iv) 국가를 상대로 소유권확인을 구하는 것은 v) 법률상 이익이 없다.

[매매계약무효확인, 해제확인] **(이기다즉)** 곽B 1회-3-1
判例 매매계약해제의 효과로서 이행의 소를 제기할 수 있을지라도 그 기본이 되는 매매계약 존부에 대해 다툼이 있어 즉시 확정의 이익이 있는 때는 계약해제확인을 구할 수 있다.

[근저당권 피담보채무부존재확인] **(피근별/선분)** 이C 7회-1-1
적법설: 저당권말소청구에 대한 기판력은 선결적 법률관계인 채무존부에 미치지 않는 바, 채무존부에 대한 기판력을 얻을 필요
부적법설: 채무존부는 분쟁의 주된 대상이 아니므로
判例 i) 피담보채무부존재확인청구와 함께 근저당권설정등기의 말소를 구하는 경우 ii) 근저당권설정등기의 말소를 구하는 것이 분쟁을 유효·적절하게 해결하는 수단이 될 것이므로 iii) 별도로 피담보채무부존재확인청구를 하는 것은 확인의 이익이 없다.
검토: 채무부존재확인청구는 말소청구의 선결적 법률관계로서 확인의 소의 보충성에 반하지 않고, 분쟁의 종국적 해결을 위해 적법설 타당

[확인의 이익 흠결시 주문기재만 잘못된 경우] 곽 기초 2회-1-1
判例 확인의 이익이 없다는 취지로 판결이유에서 판단하면서 판결주문에서는 청구기각한 경우, 본안에 관한 기판력이 발생하지 않으므로 대법원이 원심을 파기할 사유는 되지 않는다.

<소송물>
[손해배상청구 소송물] 이B 1회-3-2
손해1개설: 전체손해가 1개의 소송물
손해2분설: 재산적 손해와 정신적 손해로 나누어
判例 (손해3분설): 통상의 치료비와 같은 적극적 손해와 일실수익상실에 따른 소극적 손해, 정신적 고통에 따르는 정신적 손해로 나누어진다.
검토: 각 손해별로 처분권주의를 적용해야 각 소송물에 따르는 주장·증명의 범위를 명확히 할 수 있으므로

[진정명의회복 말소등기청구 소송물]
判例 말소등기청구의 소송물은 당해 등기의 말소청구권의 주장이고, 그 동일성 식별의 기준이 되는 청구원인은 등기원인의 무효이므로, 등기원인의 무효를 뒷받침하는 개개의 사유는 독립된 공격방법에 불과하다.

[진정명의회복 말소등기청구와 계약해제 말소등기청구] **(방계원기)**
判例 i) 후소에서 전소와 같이 소유권에 기한 방해배제청구권의 행사로 말소등기청구를 하는 것이 아니라, ii) 계약해제에 따른 계약상의 권리에 기하여 원상회복으로 말소등기청구를 한 경우, iii) 전소와 청구원인을 달리하는 것이어서 iv) 전소 확정판결의 기판력이 후소에 미칠 수 없다.

[부당이득반환청구와 계약해제 원상회복청구] **(계부법공)**
判例 i) 계약해제 효과로서의 원상회복은 부당이득에 관한 특별규정이고, ii) 부당이득반환청구에서 법률상 원인 없는 사유로 계약의 불성립, 취소, 무효, 해제 등으로 주장하는 것은 공격방법에 지나지 않는다.

[점유개시원인이 다른 취득시효완성 이전등기청구]
判例 전소에서 토지를 대물변제 받아 점유하기 시작해 취득시효가 완성되었다는 사실을 이유로 소유권이전등기청구 했다가 배척되었는데도 후소에서 이를 증여받아 점유하기 시작해 취득시효가 완성되었다고 주장하는 것은 전소 소송물인 취득시효완성을 원인으로 한 소유권이전등기청구권에 관한 공격방법에 불과한 사실을 주장하는 것으로 기판력에 저촉된다.

[확인의 소 소송물] **(소권변확기/증상동/성)** 이B 2회-1-1
다수설: 확인의 소의 소송물은 일정한 권리·법률관계의 주장이므로 청구취지만으로 특정
소수설: 이지설의 입장에서 확인의 소의 경우도 이행의 소와 같이 청구원인사실에 의해 특정
判例
1) 기판력 범위
判例 i) 토지에 대한 소유권확인 판결이 확정되면 ii) 그에 대한 권리 법률관계가 그대로 확정되는 것이므로 iii) 변론종결 전에 iv) 그 확인원인이 되는 다른 사실이 있었더라도 v) 확정판결의 기판력은 거기까지도 미친다.
2) 재소금지 범위 (모순되는 判)
判例 i) 아버지 소유의 부동산을 증여받았음을 원인으로 한 소유권확인청구를 했다가 소취하 뒤, ii) 지분소유권을 상속받았음을 원인으로 지분소유권확인청구를 한 것은 iii) 동일한 소로 볼 수 없다.
검토: 청구원인을 이루는 매매, 증여, 상속 등은 소유권 성질에 영향을 주지 않으므로 다수설 타당.

[일부청구]
(소송물) **(특별명소/분분)** 이B 1회-3, 이B 2회-2
일부청구긍정설: 처분권주의 근거로 소송물은 일부
일부청구부정설: 분쟁의 일회적 해결 근거로 소송물은 전부
명시설: 일부청구임을 명시한 경우에만 소송물은 일부
判例 i) 일부만을 특정하여 청구하고 ii) 그 이외의 부분은 별도소송으로 청구하겠다는 취지를 iii) 명시적으로 유보한 때에는 iv) 소송물은 일부에 한정된다.
검토: 원고의 분할청구 자유 존중 및 분쟁의 일회적 해결 조화
(구체적 사례)
判例 상속재산에 대한 협의분할의 소급효에 의해 피상속인의 사망시부터 원고의 단독 소유로 되었는데 원고가 이를 알지 못하고 전소에서 법정상속분만 구한 경우 일부청구임을 명시한 것이다.

判例 공유지분의 범위를 정확히 알 수 없어 전소에서 일부 공유지분에 관한 청구를 못했더라도 명시적 일부청구가 아니다.

判例 (변론종결시 예상할 수 없었던 경우가 아닌 한) 변론종결일에 근접한 일자까지 소요된 치료비임을 밝힌 치료비청구는 명시적 일부청구가 아니다.
cf. 기왕치료비 청구하면서 향후 치료비는 추후소송시 신체감정 결과에 따라 확정하여 청구한다는 취지를 밝힌 경우 명시적 일부청구다. (이A 3회-1)

(중복소제기) 이B 1회-3-2
중복소송부정설: 일부청구 소송물은 일부이므로
중복소송긍정설: 일부청구 소송물은 전부이므로
判例
1) 별소의 중복소제기 여부 - 명시시 중복소제기 부정설
判例 명시한 사건에서, 소송물은 청구한 일부에 한정되는 것이므로 나머지를 별도 소송으로 제기하더라도 중복소제기에 해당하지 않는다.
2) 별소의 소권남용 여부
判例 다만, 명시한 경우라도 사실심에서 청구취지의 확장을 할 수 있는데 별소로 잔부청구하는 것은 소권남용에 해당하여 부적법하다.
검토: 명시한 때는 소송물을 일부로 보는 이상

(기판력) **(가나명기/분분)** 이B 1회-3-1
일부청구긍정설: 전소 소송물은 일부이므로 잔부청구인 후소에는 기판력 미치지 않는다.
일부청구부정설: 전소 소송물은 전부이므로 잔부청구인 후소는 기판력에 저촉된다.
명시설: 일부청구임을 명시한 경우 소송물은 일부이므로 잔부청구에 기판력 미치지 않는다.
判例 i) 가분채권의 일부만 청구하면서 ii) 나머지를 유보하겠다는 취지를 iii) 명시하지 않은 이상 iv) 확정판결의 기판력은 남은 잔부청구에까지 미친다. (2013다96165)
검토: 원고의 분할청구 자유 존중 및 분쟁의 일회적 해결 조화

(시효중단 범위) 이B 2회-2
일부중단설: 청구한 일부만 중단
전부중단설: 권리 위에 잠자고 있지 않다는 점이 나타나 전부 중단
절충설: 일부청구임을 명시한 경우 일부만 중단
判例
1) 기본적인 입장 **(일나시/나소확시)**
判例 일부청구임을 명시한 사건에서 "일부청구는 나머지 부분에 대한 시효중단의 효력이 없고 나머지 부분에 관해 소 제기하거나 청구확장서면을 법원에 제출한 때 비로소 시효중단 효력이 생긴다" 절충설의 입장이다.
2) 일부청구 명시했지만 청구취지확장 뜻 명백히 한 경우
① 소송종료까지 청구금액을 확장한 경우 **(일진종소전)**
判例 i) 소장에서 채권 중 일부만 청구하면서 ii) 진행경과에 따라 청구금액을 확장할 뜻을 표시하고 iii) 소송종료까지 실제 청구금액을 확장한 경우에는 iv) 소 제기 당시부터 v) 채권 전부에 관해 재판상 청구로 인한 시효중단 효력이 발생한다.
② 소송종료까지 청구금액을 확장하지 않은 경우 **(나계최174나)**
判例 i) 나머지 부분에 대하여는 시효중단 효력이 발생하지 않는다. ii) 그러나 소송계속 중에는 iii) 최고에 의한 권리행사상태가 지속되고, iv) 소송종료시부터 6월 내에 민법 174조의 재판상 청구를 함으로써 v) 나머지 부분의 시효를 중단시킬 수 있다.
검토: 일부청구를 명시한 때는 일부만이 소송물이므로 절충설 타당. 다만 소제기시부터 채권 전부에 관해 판결을 구한 것으로 해석되는 경우 판례 타당.

(과실상계)
안분설: 일부청구액을 기초로 상계 후, 남은 잔액에 대해 청구인용
외측설: 총액에서 상계한 후, 남은잔액이 청구액을 초과하면 청구액을, 미달시 잔액을 인용
절충설: 일부청구 명시하지 않은 경우 외측설, 명시한 경우 안분설
判例 법원이 채권자 측의 과실을 참작하여 손해배상의 범위를 정함에 있어서는 채권자가 입은 전체 손해액을 기준으로 해야 한다.
검토: 일부청구라도 채권 전부에 대해 심리하는 것이 통상적인 바 외측설이 타당.

<재판장의 소장심사와 그 후 조치>
(소송대리인에 대한 보정명령 가부)
(심상/인소재인)
判例 i) 소송대리권의 범위는 원칙적으로 당해 심급에 한정되지만, ii) 상소제기 특별수권을 받았다면 상소장을 제출할 권한과 의무가 있으므로, iii) 상소장에 인지를 붙이지 않은 흠이 있다면 소송대리인은 이를 보정할 수 있고, iv) 재판장도 소송대리인에게 인지보정을 명할 수 있다.

(보정명령에 대한 불복불가-통상항고 가부)
(인439불특/인독)
判例 i) 재판장의 인지보정명령은 일반적으로 항고의 대상으로 삼고 있는 439조의 소송절차에 관한 신청을 기각하는 결정이나 명령에 해당하지 않고, ii) 또 이에 대해 불복할 수 있다는 특별규정도 없으므로, iii) 인지보정명령에 대해 독립하여 이의신청이나 항고 할 수 없다.

((항)소장각하 명령 행사시기) 이B 6회-3-2
(항)소장부본송달시설: 보정되지 않은 소장도 상대방에게 송달되면 쌍방이 관여하는 소송절차로 발전하므로 (항)소장부본 송달 전까지
변론개시시설: 합의부 전원이 관여하는 변론 개시 전에 재판장 혼자 처리해 소송경제 도모하는 것이므로 변론개시 전까지
判例 항소심 재판장이 독자의 권한으로 항소장각하명령 할 수 있는 것은 항소장의 송달 전에 한한다.
검토: (항)소장부본 송달하면 대립당사자구조 성립되므로

[독립당사자소송 각하명령 행사시기] **(피항재)** 이B 6회-3-2
判例 i) 피항소인 중 1명에게 항소장이 적법하게 송달되어 ii) 항소심법원과 당사자 사이의 소송관계가 일부라도 성립되면, iii) 재판장은 단독으로 항소장 각하명령을 할 수 없다.

(각하명령 효력발생 후 보정가부)
(각각즉인하)
전원합의체 결정으로 i) 소장이나 항소장의 적법여부는 각하명령을 한 때를 기준으로 할 것이고, ii) 각하명령에 대한 즉시항고를 제기하고 인지를 더 붙였다고 하여 그 하자가 보정되는 것은 아니라고 했다.

(각하명령 성립 후 보정가부)
(각성고인/각위재)
判例 i) 각하명령이 성립한 이상 당사자에게 고지되기 전에 부족한 인지를 보정했다 하여 ii) 각하명령이 위법한 것으로 되거나 재도고안에 의해 그 명령을 취소할 수 있는 것은 아니다.

<소제기 효과 - 중복소제기>
[소송계속 발생시기]
통설 및 判例는 전소, 후소의 판별기준은 소송계속의 발생시기 즉 소장이 피고에게 송달된 때의 선후에 의할 것이라고 하여 소장부본 송달시설을 취한다.

[상계항변] **(모경별상/기권)**
문제점: 상계항변은 판결이 확정되면 기판력이 생기므로 (216조2

항) 상계항변으로 주장한 채권으로 별소제기하거나 별소제기한 채권으로 상계항변하면 중복소제기규정 유추할지 문제
유추적용긍정설: 판결의 모순방지
유추적용부정설: 상계항변은 소송물이 아니고 일종의 방어방법
변론중지설: 두 소를 이부, 이송 등으로 병합심리하되, 불가능한 경우 한 쪽 소송을 변론중지
判例 이부, 이송, 변론병합을 시도함으로써 기판력의 모순을 방지하고 소송경제를 도모함이 바람직하나, 별소로 계속 중인 채권을 자동채권으로 하는 상계주장이 허용되지 않는다고 볼 수 없다.
검토: 상계항변이 기판력이 발생할지 분명하지도 않은데 전면적으로 별소 또는 상계항변을 각하하면 피고의 권리보호 외면

[청구권확인/이행] **(취원중원/상모각)**
이행의 소는 확인의 소보다 큰 요구인 집행력이 있어 확인의 소가 후소인 때만 중복소제기라는 견해,
확인의 소에서 청구취지 확장이 가능하고 판결의 모순 방지 위해 중복소제기 긍정하는 견해, 이행의 소가 기한미도래를 이유로 기각될 수 있으므로 중복소제기 부정하는 견해,
중복소송 문제 아니고 청구권확인의 소는 확인의 이익 없다는 견해
判例 병존적 채무인수인에 대한 이행소송 중 채무인수인이 채권자에 대해 원채무의 부존재확인을 구한 사건에서, "후소는 전소와 청구취지와 청구원인이 서로 다르므로, 후소가 중복제소는 아니고, 원채무 부존재는 전소에서 다툴 수 있으므로 후소는 소의 이익이 없다"고 한다.
(동일한 법률관계에 대한 확인의 소와 이행의 소 사안과는 다르지만, 일단 판례 적어줄 것)
검토: 긍정설은 청구취지확장이 상고심 계속 중인 때는 불가능하다는 점에서, 부정설은 판결의 모순을 막을 수 없다는 점에서, 확인의 이익으로 처리하는 설은 확인의 소가 각하되기 전에는 중복소제기 문제가 생긴다는 점에서 부당하다.

[국제적중복소송] **(외217소/모이)** 이C 1회-2-2
규제소극설: 제259조의 법원에 외국법원은 포함X
권리보호이익설: 국내 다시 소 제기할 권리보호이익이 있으면 적법
비교형량설: 사안별로 비교형량하여 결정
判例 (승인예측설) i) 외국법원의 판결이 ii) 제217조에 의하여 승인을 받을 가능성이 예측되는 때에만 iii) 소송계속으로 볼 것
검토: 판결의 모순저촉을 방지. 법원의 이중심리와 피고의 이중응소부담 방지
(승인 예측 사안 포섭 217조1항 각호)
i) 중국에 국제재판관할권이 인정되고, ii) 피고가 송달을 적법·적시에 받고, iii) 중국판결이 공서양속에 반할 사정이 없으며, iv) 중국의 승인요건이 우리의 승인요건과 실질적 차이가 없다면, 그 판결은 승인이 예측되므로~

<채권자대위소송, 추심소송, 채권자취소소송 논의>
I. 채권자대위소송
(법적성질)
법정소송담당설(判): 채무자의 제3채무자에 대한 권리를 행사
고유의 대위권설: 실체법상의 채권자 자신의 대위권을 행사
검토: 대위권 행사 효과가 채권자에게 귀속되지 않고 직접 채무자에게 귀속되는 점을 볼 때 법정소송담당설 타당

(요건 흠결시 처리) 이C 7회-1-1
문제점: 대위소송은 i) 피보전채권 ii) 보전의 필요성 iii) 채무자의 권리불행사 iv) 피대위권리 요하는데 요건 흠결시 법원 조치가 문제
법정소송담당설: i~iii이 흠결된 경우 당사자적격 흠결로 소 각하하고, iv는 소송물로 본안의 문제이므로 흠결시 청구기각
고유의 대위권설: i~iv는 실체법상 요건사실이므로 흠결시 청구기각
判例 피보전채권이 없으면 당사자적격이 없는 바 대위소송은 부적법 각하된다.
검토: 담당설의 입장에서 피보전채권은 당사자적격의 기초를 이루는 사실로서 흠결시 소 각하 (이C7회-1-1)
(요건 흠결시 처리를 길게 쓰고 싶으면 이렇게 쓸 수 있으나 대위소송 법적성질 및 적법요건으로 짧게 쓰는 게 나아보임)

[금전채권자의 공유물분할청구권 대위행사] **(책현자부보/전현/지)**
判例 다수의견: 금전채권 보전을 위해 공유물분할청구권 대위행사하는 것은 i) 책임재산의 보전과 직접적인 관련이 없어 채권의 현실적 이행을 유효적절하게 확보하기 위해 필요하다고 보기 어렵고, ii) 채무자의 자유로운 재산관리행위에 대한 부당한 간섭이 되므로, iii) 보전의 필요성 인정할 수 없다.
判例 소수의견: i) 공유부동산 전부를 경매해 채무자인 공유자에게 분배될 몫이 남는 경우 ii) 공유물분할청구권을 대위행사해 채권의 현실적 이행을 유효·적절하게 확보할 수 있게 허용해야 한다.
검토: 금전채권자는 공유지분의 집행으로 만족을 얻음이 원칙

[각하판결] 이C 1회-4-1
判例 채무자의 제3채무자를 상대로 한 소가 제기되었다가 각하판결이 확정된 경우에는 채무자가 스스로 제3채무자에 대한 권리를 행사한 것으로 볼 수 없다.

[소취하] **(합청부)** 이C 1회-4-1
학설: i) 채무자가 소 취하해도 대위채권자의 적격이 회복되지 않는다는 견해, ii) 채무자가 소 취하하면 채무자가 권리를 행사한 것으로 볼 수 없어 대위채권자의 적격이 회복된다는 견해
判例 (위 사안에서) i) 채무자가 소를 제기한 뒤 채무자와 제3채무자 사이에 민형사상 분쟁을 종료하기로 하는 합의를 함으로써 ii) 채무자가 제3채무자에 대해 자신의 청구권을 행사했으므로 iii) 대위소송은 당사자적격을 흠결해 부적법하다. (2015다69372)
검토: 채무자가 제3채무자와 합의함으로써 자신의 권리를 행사했다고 볼 수 있으므로
(cf. 채무자가 소제기 후 합의 없이 취하했다면 적격 회복으로)

[대위소송 중 채무자 소제기] **(대실/모)**
긍정설: 담당설의 입장에서, 대위소송 확정판결의 기판력이 채무자에게 미친다는 점을 근거로 당사자는 실질적으로 동일하고, 소송물도 동일하므로
절충설: 담당설의 입장에서, 채무자는 대위소송 계속을 알았을 때만 기판력을 받으므로 이 경우에 한해 중복소송
부정설: 고유의 대위권설의 입장에서, 당사자와 소송물 다름
判例 대위소송 계속 중 채무자가 청구취지·원인이 같은 소를 제기한 경우 "양 소송은 비록 당사자는 달라도 실질적으로 동일소송이므로 후소는 중복제소금지규정에 저촉된다"
검토: 판결의 모순 방지를 위해 대위소송 계속 알았느냐와 관계없이 별소 금지

[대위소송 중 다른 채권자 소제기] **(대실/모)**
긍정설: 담당설의 입장에서, 대위채권자들은 서로 기판력을 받는 관계이어서 당사자는 실질적으로 동일하고, 소송물도 동일하므로
절충설: 담당설의 입장에서, 채무자가 대위소송 계속을 알았을 때만 채권자끼리 기판력을 받으므로 이 경우에 한해 중복소송

부정설: 고유의 대위권설 입장에서, 당사자와 소송물 다름
判例 대위소송 계속 중 다른 채권자가 채무자를 대위해 청구취지·원인이 같은 소를 제기한 경우, "양 소송은 당사자는 달라도 실질적으로 동일소송이므로 후소는 중복소제기금지규정에 저촉된다"
검토: 판결의 모순 방지를 위해 대위소송 계속 알았느냐와 관계없이 별소 금지

[피대위자] **(대피종피/담)**
긍정설: 담당설의 입장에서, 채무자가 대위소송 제기사실을 안 이상 참가 기회가 있었으므로
부정설: 고유의 대위권설의 입장에서, 당사자와 소송물 다르므로
判例 i) 대위소송이 제기된 사실을 채무자가 알았을 때는 판결효력이 채무자에게 미치므로, ii) 대위소송이 제기된 사실을 피대위자가 알게 된 이상, iii) 대위소송의 종국판결이 있은 후 취하된 때에는 iv) 피대위자도 재소금지규정의 적용을 받아 동일한 소를 제기하지 못한다. (79다1618)
검토: 대위소송을 담당으로 보는 한 대위채권자의 소와 채무자의 소는 동일하므로

[피보전채권 인낙한 채무자] **(대적인채)**
判例 i) 채권자가 채무자의 권리를 대위행사할 자격이 없었더라도, ii) 채무자가 적극적으로 채권자의 주장을 인정하면서 iii) 청구를 인낙하여 대위적격을 부여한 이상, iv) 채무자는 재소금지원칙상 제3채무자를 상대로 동일한 소를 제기할 수 없다.

[시효중단 효력 유지여부] **(동특잠)** 심2회-3-4
判例 교환적변경으로서 구 청구는 취하된 것으로 보아야 하나, i) 양 청구는 동일 소송물에 관한 권리의무의 특정승계만 있을 뿐 소송물은 동일한 점, ii) 시효중단 효력은 특정승계인에게도 미치는 점, iii) 원고를 권리 위에 잠자는 자로 볼 수 없는 점에 비추어 볼 때 당초의 채권자대위소송으로 인한 시효중단의 효력이 소멸하지 않는다.

[순차대위소송] 곽2회-4-2
判例 대위소송 제기로 인한 시효중단의 효력은 채무자에게 생기므로, 소멸시효는 채권자들의 순차적인 대위소송에 따라 최초의 대위소제기로 중단되었다.

II. 추심소송
(당사자적격) 이B 5회-3-1
1) 압류·추심명령 송달 유효한 경우 **(압3추채)**
判例 채권의 압류 및 추심명령이 있으면 제3채무자에 대한 이행의 소는 추심채권자만이 가능하고 채무자는 소송을 제기할 당사자적격을 상실한다.
2) 압류·추심명령 송달 무효인 경우 **(3적채)**
判例 제3채무자인 피고에게 적법하게 송달되지 않아 명령의 효력이 발생하지 않은 경우 채권자인 원고는 추심의 소를 제기할 권능이 없다.
3) 압류·추심명령 신청 취하
判例 추심채권자가 압류 및 추심명령 신청의 취하 등에 따라 추심권능을 상실하면 채무자는 적격을 회복한다.

[채무자 소송 중 추심소송제기] 이B 6회-2-2
判例 다수의견: **(이경모/상압참/압채중)**
i) 압류·추심명령이 있으면 채무자는 이행의 소를 제기할 당사자적격을 상실해 채무자의 소는 부적법하다. 따라서 추심의 소에 관해 본안 판단하여도, 제3채무자에게 이중 응소의 부담을 지우고, 소송경제에 반한다거나, 판결의 모순·저촉 위험이 크지 않다.
ii) 채무자의 이행의 소가 상고심에 계속 중인 경우에는 참가가 허용되지 아니하며, 압류채권자가 채무자의 이행의 소에 참가할 의무가 있는 것도 아니다.
iii) 압류채권자의 추심의 소는 채무자의 이행의 소에 대한 관계에서 중복된 소제기에 해당하지 않는다.
判例 소수의견: **(부소중/압참)**
1) 전소가 부적법한 소라도 소송계속이 소멸하지 않는 한 그 소송계속 중에 제기된 후소는 중복소제기로서 각하를 면할 수 없다.
2) 압류채권자에게는 채무자의 이행의 소에 81조, 79조에 따라 참가할 수 있는 길이 열려 있다.
검토: 적격 없는 채무자의 소가 각하되기를 기다려 다시 압류채권자로 하여금 추심의 소 제기하게 하면 소송경제에 반한다.

[다른 채권자]
判例 선행 추심소송과 별도로 다른 추심채권자가 추심의 소를 제기할 경우 새로운 권리보호이익이 발생한 것으로 볼 수 있어 재소금지규정에 반한다고 볼 수 없다.

[추심소송 기판력이 다른 채권자에게 미치는지] 이A2회-2
1) 추심소송에서 '청구 포기'의 의미 **(피포처별)**
判例 i) '피압류채권 중 일부 금액을 지급하고 나머지 청구를 포기한다'는 내용의 재판상 화해를 한 경우, ii) 청구 포기 부분은 더 이상 추심권을 행사하지 않고 소송을 종료하겠다는 의미로 보아야 한다. iii) 자신에게 처분 권한이 없는 피압류채권 자체의 포기로 볼 수는 없다. iv) 따라서 재판상 화해의 효력은 별도의 추심명령을 기초로 추심권을 행사하는 다른 채권자에게 미치지 않는다.
2) 기판력 확장여부 **(추압소당)**
判例 i) 한 채권자가 제기한 추심소송에서 확정된 판결의 기판력은 ii) 압류·추심명령을 받은 다른 추심채권자에게 미치지 않는다. iii) 추심소송의 소송물이 피압류채권으로서 서로 같아도 iv) 당사자가 다른 이상 기판력이 서로에게 미친다고 할 수 없다.

[시효중단 효력 유지여부] 심2회-3-3
(압류·추심명령 받은 채무자 시효중단 효력) **(이권추추)**
判例 압류·추심명령이 있어도, i) 채무자의 채권이 추심채권자에게 이전되는 것은 아니므로, ii) 채무자가 권리주체 지위에서 한 시효중단 효력은 iii) 추심권능을 부여받아 일종의 추심기관으로서 채권을 추심하는 iv) 추심채권자에게도 미친다.

(시효중단 유지 여부) **(갈각추재유)**
判例 i) 채무자에 갈음하여 당사자적격을 취득한 추심채권자가 ii) 채무자의 소에 대한 각하판결이 확정된 날부터 6개월 내에 iii) 제3채무자를 상대로 추심의 소를 제기하였다면, iv) 채무자의 재판상청구로 인해 발생한 시효중단의 효력은 v) 추심소송에서도 유지된다.

III. 채권자취소소송
(법적성질과 피고적격) **(사책집/원)**
형성소송설: 사해행위의 절대적 취소를 목적으로 하므로 채무자와 수익자 또는 전득자를 공동피고로
이행소송설: 원상회복을 목적으로 하므로 수익자 또는 전득자를 피고로
判例
1) 법적성질
判例 "i) 채권자취소권은 채무자의 사해행위를 채권자와 수익자 또

는 전득자 사이에서 상대적으로 취소하고 ii) 채무자의 책임재산에서 일탈한 재산을 회복하여 iii) 채권자의 강제집행을 가능하게 하는 권리"라 하여 형성의 소와 이행의 소의 결합으로 본다.
2) 피고적격
判例 취소권은 수익자 또는 전득자에 대하여만 있고, 채무자에 대한 소는 피고적격이 없서 각하해야 한다.
검토: 원상회복에 중점이 있는만큼 수익자 또는 전득자만 피고적격

(중복소제기)
(다른 채권자가 취소소송)
判例 각 채권자는 고유의 권리로서 채무자의 사해행위를 취소하고 원상회복을 구할 수 있으므로, 각 채권자가 동시 또는 이시에 사해행위취소 및 원상회복을 구하는 소송을 제기해도 중복제소에 해당하지 않는다.
(같은 채권자가 취소소송) **(사법공소)**
判例 i) 채권자가 채무자의 행위가 사해행위라고 하여 그 취소를 청구하면서 ii) 행위의 법률적 평가와 관련해 증여 또는 변제로 달리 주장하는 것은 iii) 공격방법에 관한 주장을 달리하는 것일 뿐 iv) 소송물을 달리하는 것으로 볼 수 없다.

(기판력)
[취소소송 확정판결 효력이 다른 채권자에게 미치는지]
判例 "각 채권자는 고유의 권리로서 채무자의 사해행위를 취소하고 원상회복을 구할 수 있으므로", 소송물이 달라서 기판력이 확장될 이유가 없다.

[확정판결로 마쳐진 등기 사해행위로 말소] **(사원법/확원효)**
判例 i) 채권자가 사해행위취소의 판결을 받은 경우 ii) 수익자가 채권자에 대해 원상회복의무를 부담하게 될 뿐, iii) 채권자와 채무자 사이에서 법률관계가 형성되는 것은 아니므로 iv) 채무자와 수익자 사이의 확정판결을 통해 마쳐진 소유권이전등기가 v) 원상회복으로써 말소된다고 하더라도, vi) 확정판결의 효력에 반하는 것이 아니다.

(소의 이익) **(승권/승재중권)**
1) 승소판결 확정시
判例 i) 한 채권자가 승소판결이 확정되었다는 것만으로 ii) 그 후에 제기된 다른 채권자의 채권자취소 및 원상회복청구가 권리보호이익이 없어지게 되는 것은 아니다.
2) 재산이나 가액회복시
判例 i) 한 채권자가 승소판결이 확정되고 ii) 그에 기해 재산이나 가액의 회복을 마친 경우, iii) 다른 채권자의 채권자취소 및 원상회복청구는 그와 중첩되는 범위 내에서 권리보호이익이 없게 된다.

(피보전채권 교환·추가) **(피공소/피동참)**
判例 i) 피보전채권을 추가·교환하는 것은 ii) 공격방법의 변경이지 iii) 소송물을 변경하는 것은 아니므로, iv) 피보전채권을 달리해 동일한 채권자취소소송을 이중으로 제기할 경우 v) 소송물은 동일하고, iv) 이는 전소나 후소 중 어느 하나가 승계참가신청에 의해 이루어진 경우에도 마찬가지다.

제2장 변론 5개
처분권주의
{일부인용 template}
(처분권주의 의의) **(절당/사)**
i) 절차의 개시, 심판의 대상, 절차의 종결에 대해 ii) 당사자에게 주도권을 주어 그의 처분에 맡기는 원칙. iii) 사적자치의 소송법적 측면.

[단순이행청구 상환이행판결]
[동이항, 유치권]
(처분권주의의 내용) **(매소미상)**
判例 i) 매매계약체결과 대금완납을 청구원인으로 하여 ii) 소유권이전등기를 구하는 청구취지에는 ii) 미지급금이 있을 때에는 iv) 위 금원의 수령과 상환으로 이전등기를 구하는 취지도 포함되어 있다.

(원고가 반대 의사표시 하지 않을 것)
判例 원고의 청구가 자기의 반대급무 의무가 없다는 취지임이 분명한 경우에는 청구를 기각해야 한다. (ex 반대채무인 대금채무가 이미 감액되었다고 주장한 사건)

[건매청] **(건매/취원석)** 이B 4회-1-2
(건물철거청구에 상환인도청구 포함여부)
긍정설: 근거로 분쟁의 1회적 해결, 임대인과 임차인 모두 상환이행판결을 해달라는 의사라는 점을 든다
부정설: 근거로 청구취지가 다르고, 청구원인상 인도청구는 매매계약에 기초하나 철거청구는 소유권에 기한 방해배제에 기초함을 든다
判例 i) 건물철거 및 토지인도청구 속에 ii) 건물의 매수대금지급과 상환으로 건물의 인도를 구하는 청구가 포함되어 있다고 볼 수 없다.
검토: 양 청구의 청구취지와 청구원인이 다르며, 소송경제는 석명권으로 해결할 수 있으니 부정설 타당.

(석명권 의의) **(분질/변)**
소송관계를 분명하게 하기 위하여 당사자에게 질문하고 증명촉구하는 법원의 권능. 변론주의의 결함 시정.

(적극적 석명 가부) **(요공변석/대임지/합경의난공승)**
제한적긍정설: 원칙 부정. 종전의 소송자료와 합리적 연관성이 있고 소송경제에 도움이 되는 사정이 있으면 적극적 석명 가능
부정설: 석명권의 범위를 불분명, 처분권주의·변론주의와 충돌
判例
1) 원칙: 당사자가 주장하지도 아니한 법률효과에 관한 요건사실이나 독립된 공격방어방법을 권유하는 것은 변론주의에 위배되고 석명권 행사의 한계를 일탈한다.
2) 예외: i) 대금지급과 상환으로 지상물 인도를 청구할 의사가 있는 지를 석명하고 ii) 임대인이 그 석명에 응하여 소를 변경한 때에는 iii) 지상물 인도의 판결을 함으로써 분쟁의 1회적 해결을 꾀하여야 한다.
검토: 처분권주의와 변론주의 하에서 원칙적으로 부정하되, 사안의 적정한 해결을 위해 종전 소송자료와 합리적 관련성, 소송경제, 당사자의 의사, 법적 구성의 난이도, 당사자의 공평, 승패개연성을 고려해 제한적으로 긍정

[단순이행청구 선이행판결]
[피담보채무전부변제 저당권말소등기] 곽B 1회-1-3
(처분권주의의 내용) **(피잔잔)**
判例 i) 피담보채무 전액 변제했다고 주장하면서 저당권말소등기청구 했으나 ii) 잔존채무가 남은 경우 iii) 잔존채무 변제를 조건으로 말소등기를 구하는 취지가 포함된 것으로 해석한다.

(원고가 반대 의사표시 하지 않을 것)
判例 피담보채무가 발생하지 않은 것을 전제로 저당권말소등기청구한 경우 선이행판결을 할 수 없다.

[선이행청구 더 불리한 선이행판결]
[피담보채무변제조건 저당권말소등기]
(처분권주의 내용) **(피잔잔)**
判例 i) 피담보채무 중 잔존채무를 변제하는 것을 조건으로 저당권말소등기를 구하는 청구에는 ii) 잔존채무액이 원고 주장의 금액을 초과하는 경우에 iii) 잔존채무 변제를 조건으로 말소등기를 구하는 취지가 포함된 것으로 해석한다.
(원고가 반대 의사표시 하지 않을 것)
判例 피담보채무가 발생하지 않은 것을 전제로 저당권말소등기청구한 경우 선이행판결을 할 수 없다.

[일시금청구에 대해 정기금판결] **(자/어일정불일)**
1) 종래 判例
判例 일시금으로 청구했더라도 정기금지급을 명할지 여부는 법원의 자유재량에 속한다.
2) 변화된 判例
判例 i) 어느 방식에 의해 청구할지는 원칙적으로 손해배상청구권자가 임의로 선택할 수 있으나, ii) 일시금 지급방식에 의한 배상이 iii) 사회정의와 형평의 이념에 비추어 iv) 현저하게 불합리한 결과를 초래할 우려가 있는 때에 iv) 일시금지급을 청구했어도 정기금지급을 명하는 판결을 할 수 있다.

[집행불능·이행불능 대상청구] 이B 8회-1-3
判例 집행불능시의 대상청구 속에 이행불능시의 전보배상청구도 포함된 것으로 보고 판단한 것은 청구하지 않은 것을 심판한 잘못이 있다.

변론주의
{주장책임 template}
(변론주의 의의 및 내용) **(소당/사자증)**
i) 소송자료의 수집·제출 책임을 당사자에게 맡기고, ii) 당사자가 수집하여 제출한 소송자료만을 재판의 기초로 삼는 원칙. iii) 사실주장책임, 자백구속력, 증거제출책임을 그 내용으로 한다.

[주장공통원칙] **(주쌍불)** 곽콜 4회-1-1
判例 i) 주요사실은 반드시 주장책임 지는 자가 진술해야 하는 것은 아니고, ii) 쌍방 당사자 간에 제출된 소송자료를 통해 심리됨으로써 ii) 주장의 존재를 인정하더라도 상대방에게 불의의 타격을 줄 우려가 없으면 재판의 기초로 삼을 수 있다.

(주요사실 간접사실 구별) **(법요추)**
통설·判例인 ii) 법규기준설의 입장에 따라 ii) 주요사실은 법률효과를 가져오는 법규의 요건사실을 말하고, iii) 간접사실은 주요사실의 존부를 추인케하는 사실을 말한다.

[소멸시효기산점] **(소본변/예)** 이B 3회-1-1
통설: 민법166조 1항에서 권리를 행사할 수 있을 때라고 규정
소수설: 변제기도래사실 등으로 법원이 기산일 판단하는 것이므로 법률문제일 뿐 사실문제가 아니다
判例 소멸시효의 기산점은 i) 소멸시효 항변의 법률요건을 구성하는 구체적인 사실에 해당하므로 ii) 본래의 소멸시효 기산점과 당사자가 주장하는 기산점이 서로 다른 경우에는 iii) 변론주의 원칙상 당사자가 주장하는 기산점을 기준으로 소멸시효를 계산해야 한다.
검토: 예상 외 재판을 방지하기 위해 주장이 필요한 주요사실

[소멸시효기간] **(어단변)**
判例 i) 어떤 권리의 소멸시효기간이 얼마나 되는지에 관한 주장은 ii) 단순한 법률상의 주장에 불과하므로 iii) 변론주의의 적용대상이 되지 않고 법원이 직권으로 판단할 수 있다

[취득시효 기산점] **(법당/안)** 이B 3회-1-2
주요사실설: 취득시효의 기산점이 정해지면 계산상 시효완성 여부가 판단할 수 있으므로 (호)
간접사실설: 취득시효 기산점은 민법 245조에 요건사실로 규정되어 있지 않으므로
判例 취득시효 기산점은 i) 법률효과의 판단에 관하여 직접 필요한 주요사실이 아니고 간접사실에 불과하므로 ii) 당사자의 주장에 구속되지 아니하고 소송자료에 의하여 진정한 점유의 시기를 인정하여야 하는 것이다.
검토: 시효완성자가 기산점을 임의로 늦춰 거래안전을 해치는 것을 막으려면 간접사실로

[점유권원] **(자당)** 이A 6회-3-1
判例 i) 시효취득에서 자주점유인지 여부를 가리는 기준이 되는 점유권원은 간접사실이므로, ii) 당사자의 주장에 구애됨 없이 소송자료에 의하여 진정한 점유권원을 심리할 수 있다.

[수입, 가동연한, 공제할 생활비]
判例 수입, 가동연한, 공제할 생활비 등 기초사실에 관한 주장은 사실상의 주장에 속할 것이나, 일실이익 현가 산정방식에 관한 주장은 당사자의 평가에 지나지 않는다.

[간접적 주장] **(명간/구실)**
긍정설: 부당한 결과 시정
부정설: 법원의 심리부담 가중
判例 주장은 직접적으로 명백한 경우뿐만 아니라 변론을 전체적으로 관찰하여 간접적 주장으로 볼 수 있는 경우에도 주요사실의 주장이 있는 것으로 본다.
검토 및 인정요건: 구체적 타당성, 실체적 진실 발견
i) 당사자의 소송행위에 비추어 주요사실 주장이 예상
ii) 상대방에게 방어권 행사 불이익 無

[묵시적 주장] **(본채원채본)**
判例 i) 피고가 본안 전 항변으로 ii) 채권양도사실을 내세워 당사자적격이 없다고 주장하는 경우, iii) 원고가 채권을 양도했기 때문에 iv) 채권자임을 전제로 한 청구는 이유 없는 것이라는 취지의 v) 본안의 항변이 포함되어 있다.

[묵시적 주장] **(동소채원)** 곽콜 2회-2-1
判例 i) 채권자가 동일목적을 달성하기 위해 여러 채권을 행사하고 ii) 채무자가 소멸시효항변을 하는 경우, iii) 그 항변에 의해 어떤 채권을 다투는지 특정해야 하고, iv) 그와 같이 특정된 항변에는 청구원인이 다른 채권에 대한 소멸시효항변까지 포함된 것으로 볼 수 없다.

[가정적 항변] **(원석내이)** 곽B 7회-2-2
判例 i) 청구원인 주장 불분명시, ii) 석명을 구하면서 가정적으로 항변한 경우에도 주요사실 주장이 있다고 볼 수 있으며, iii) 이는

당사자들의 진술 내용뿐 아니라 iv) 상대방이 진술을 어떻게 이해했는지도 고려해 합리적으로 판단한다.
(판단누락 위법. 가정적 항변은 별도의 카테고리로 생각)

(신설 내용)
기준재구성설: 법원의 심리편리와 당사자의 예상 외 재판방지라는 상호이익을 형량하여 결정
준주요사실설: 법규기준설을 유지하되, 과실과 같은 일반조항은 그것을 구성하는 구체적 사실을 주요사실에 준해 본다

{응소행위와 시효중단사유 주장책임 template}
(응소행위가 시효중단사유인지) **(시소응적받/근)**
긍정설: 민법 168조의 청구에 상응하는 권리의 주장
부정설: 민법 168조의 청구는 권리자 자신이 능동적으로 권리를 실현하려는 경우를 의미
判例 i) 시효중단사유로 규정한 재판상 청구에는 ii) 시효를 주장하는 자가 소제기한 데 대해 iii) 피고로서 응소해 iv) 그 소송에서 적극적으로 권리를 주장하고 v) 그것이 받아들여진 경우도 포함한다.
검토: 시효중단의 근거는 권리행사에 있는 것이므로 응소행위도 권리행사의 일환인 경우 시효중단사유

(시효중단사유 주장요부) **(변응시)**
判例 i) 변론주의 원칙상 피고가 시효중단의 주장 또는 이러한 취지가 포함된 주장을 하지 않는 한, ii) 응소행위가 있었다는 사정만으로 iii) 당연히 시효중단의 효력이 발생한다고 할 수 없다.

(석명의무 위반여부) **(시응석)**
判例 i) 피고가 시효중단에 관한 아무 주장을 하지 않은 사건에서 ii) 응소행위가 시효중단사유에 해당하는 여부 심리하지 않았다 하여 iii) 석명권 불행사의 위법이 있다고 할 수 없다.

{표현대리사실 주장책임 template} 이C8회-3-2
(유권대리주장에 표현대리주장 포함여부) **(표요유/요)**
불포함설: 유권대리와 표현대리의 요건사실이 서로 다르기 때문에
포함설: 표현대리의 요건사실의 일부가 피고에 의해 주장된 경우 주장공통원칙에 의해 표현대리 심리
判例 i) 표현대리가 성립된다고 하여 무권대리의 성질이 유권대리로 전환되는 것은 아니므로, ii) 양자의 구성요건 해당사실 즉 주요사실은 다르다. iii) 그러므로 유권대리에 관한 주장 가운데 무권대리에 속하는 표현대리의 주장이 포함되어 있다고 볼 수 없다.
검토: 법규기준설에 의할 때 유권대리와 무권대리의 요건사실은 명백히 다르므로 (심영식 검토)

(석명의무 위반여부)
判例 표현대리의 성립 여부를 심리 판단할 필요가 없음은 물론 당사자에게 표현대리에 관해 요건사실의 주장이나 입증을 촉구할 의무가 없다 (2001다1126)

(지적의무 의의) **(간의/예)**
i) 법원이 당사자가 간과하였음이 분명한 법률상 사항에 관하여 ii) 당사자에게 의견을 진술할 기회를 주어야하는 의무. iii) 예상 외의 재판을 방지

[확인의 이익] **(현과석/의취익)** 곽1회-3-1
判例 i) 현재 법률상 지위 불안제거를 위해 과거 법률관계 확인을 구할 이익이 있는지 석명하고 ii 의견을 진술하거나 청구취지를 변경할 기회를 주어야 함에도 확인의 이익이 없다고 각하한 것은 잘못이다.

[대위소송 보전의 필요성]
(대위소송 각하 정당여부) **(시말상보)**
判例 i) 채무자의 부동산을 시효취득한 채권자의 공동상속인이 ii) 채무자의 말소등기청구권을 대위행사하는 경우, iii) 공동상속인의 지분을 초과하는 부분은 v) 채무자를 대위할 보전의 필요성이 없다.

(지적의무 위반 여부) **(상보석보석)**
判例 i) 상속지분을 넘는 부분에 관하여 ii) 보전의 필요성이 없다는 점을 지적하는 등 iii) 아무런 석명을 하지 아니한 채 iv) 보전의 필요성이 없다는 이유로 소를 각하함은 v) 석명의무를 다하지 않은 위법이 있다.

[소변경 진명등] (석명의무 - 상고이유 여부)
긍정설: 석명권의 범위와 석명의무의 범위는 같으므로
부정설: 석명권은 법원의 권능이고, 행사여부는 재량이므로
검토: 석명권의 중대한 해태로 심리가 현저히 조잡하게 된 때만 상고이유 (절충설)
(지적의무 위반 여부) **(종진주진소)**
判例 i) 자기 앞으로 소유권등기가 되어 있지 않았고, 법률에 의해 소유권을 취득하지도 않았다는 종전 주장을 유지한 채 ii) 진정명의회복을 위한 이전등기청구를 제기함으로써 iii) 주장 자체에 명백한 모순이 있었는데 iv) 이는 진정명의회복을 위한 이전등기의 법리를 제대로 이해하지 못한 것이다. v) 원심은 소 변경에 법률적 모순이 있음을 지적하고 원고에게 의견을 진술할 기회를 부여했어야 한다.

<변론>
I. 변론의 내용
[주장 순서 구속여부] **(예분기/상기출무)**
1) 원칙
i) 예비적 주장에 대해 그 주장순서에 구애받지 않고 그 중 하나를 인정하여 판결을 할 수 있음이 원칙. ii) 어느 것을 채택하더라도 분쟁해결의 결과에 차이를 초래하지 않고, 주장은 판결이유에서 판단되어 기판력이 발생하지 않기 때문.
2) 예외
i) 상계항변에 대한 판단은 판결이유 중의 판단이지만 기판력이 발생하고, 출혈적 방어방법인 점에서 특별한 취급을 요한다. ii) 피고가 면제, 소멸시효 등과 함께 상계를 주장하는 경우 무대가적인 면제나 소멸시효의 항변에 대한 판단을 먼저 해야 한다.
(지상물매수청구권도 예비적 항변으로 취급)

[상계항변에 대한 상계재항변 불허] **(배이대/추별)**
1) 재항변 판단요부
判例 i) 법원이 피고의 상계항변을 배척하는 경우에는 상계재항변을 판단할 필요가 없고, ii) 피고의 상계항변이 이유 있다고 판단하는 경우에는 수동채권과 자동채권이 상계적상 당시에 대등액에서 소멸한 것으로 보므로 이때에도 역시 상계재항변에 관해 판단할 필요가 없다.
2) 원고의 다른 채권 행사방법
判例 원고가 소송물인 청구채권 외에 피고에게 다른 채권이 있다면, 원고는 소의 추가적 변경을 하거나 별소를 제기할 수 있다.
3) 판례 결론
判例 피고의 상계항변에 대한 원고의 상계재항변은 일반적으로 허용할 이익이 없다.

{부인과 항변 template}
(부인과 항변 의의 및 구별기준)
부인은 상대방 주장사실과 양립불가능한 사실을 주장하여 상대방의 주장을 배척하는 진술. i) 단순히 부정하는 단순부인과 ii) 상대방 주장사실과 양립불가능한 별개의 사실을 주장하여 부정하는 이유부 부인이 있다.
항변은 상대방 주장사실과 양립가능한 별개사실에 대한 진술. i) 원고 주장사실을 인정하면서 항변하는 제한부 자백과 ii) 원고 주장사실을 다투면서 항변하는 가정적 항변이 있다.

II. 소송상 형성권 행사 법적성질 **(수상실/사기분상)**
병존설: 사법상 형성권을 행사하는 사법행위와 그 사법상 효과를 법원에 진술하는 소송행위의 병존으로 각각 실체법과 소송법에 의해 규율된다.
소송행위설: 순수한 소송행위로서, 소송법에 의해 규율된다.
신병존설: 병존설을 취하면서도 소송상 형성권 행사는 법원의 판단을 받을 것을 조건으로 그 효과를 발생케 하려는 의사표시.
양성설: 사법행위와 소송행위의 성질을 모두 갖는 1개의 행위
判例
1) 해제권 행사의 경우
判例 소제기로써 해제권을 행사한 후, 그 소송을 취하해도 해제권은 형성권이므로 그 행사의 효력에는 아무런 영향을 미치지 않는다.
2) 상계권 행사의 경우
判例 i) 소송상 상계항변은 수동채권의 존재가 확정되는 것을 전제로 행해지는 예비적 항변으로서 ii) 상계에 관한 법원의 실질적 판단이 이루어지는 경우에 iii) 비로소 실체법상 상계의 효과가 발생한다.
검토: 병존설은 상계항변이 각하되어도 사법행위의 효력이 남는 문제, 소송행위설은 기각판결이 형성판결이 되는 문제. 양성설은 현행법제가 실체법과 소송법을 분리한 것에 반하는 해석. 상계 의사표시는 상계에 관한 법원 판단이 있을 때만 반대채권 소멸시키려는 것이므로 신병존설이 타당. 반대채권만 소멸되는 문제가 없는 해제권은 병존설이 타당.

조정성립시 判
(소송상 상계항변은 수동채권의 존재가 확정되는 것을 전제로 행해지는 예비적 항변으로서 조정이 성립됨으로써 수동채권의 존재에 관한 법원의 실질적 판단이 이루어지지 아니한 경우에는 소송절차에서 행해진 소송상 상계항변의 사법상 효과도 발생하지 않는다)

III. 소송상 합의 이B 5회-1-1
(적법성) **(처변예합)**
통설判例 명문의 규정이 없는 소송상합의에 관해, i) 처분권주의·변론주의가 행해지는 범위 내에서 ii) 당사자가 그 합의의 법효과를 명확히 예측하고 합의하면 적법하다.

(법적성질 및 효과) **(약의항/직종/강권/규우)**
사법계약설: i) 소송상 합의는 약정대로 작위·부작위의무를 발생시키는 사법상의 계약. ii) 의무이행을 소구하여 강제집행을 할 수 있다는 의무이행소구설과 iii) 소송계약 사실을 본안 전 항변으로 주장할 수 있다는 항변권발생설이 있다.
소송계약설: i) 직접적으로 소송법상 효과를 발생시키는 소송계약. ii) 소취하(항소취하)계약이 주장·증명되면 법원은 소송종료선언을 해야 한다.
判例 i) 강제집행취하계약의 경우 그 취하이행의 소송상 청구는 허용되지 않는다 하여 의무이행소구설을 배척하였으며, ii) 소취하계약 또는 부제소계약을 한 경우 권리보호의 이익이 없다고 소각하한다.
判例에 대한 평가: '직권조사사항으로 보는 점' 외에 '사법계약'으로 보고 '권리보호이익의 문제'로 처리하는 점은 항변권발생설과 같다. 다만, 항소취하합의가 있는데도 항소취하서가 제출되지 않은 경우 상대방은 이를 항변으로 주장할 수 있다고 하여 항변사항으로 본 것도 있다.
검토: i) 소송계약설은 방식의 제한이 없는 소송상 합의를 명문의 규정도 없이 소송행위로 보는 문제 ii) 의무이행소구설은 구제방법이 우회적인 바 항변권발생설이 타당.

[민법 취소가부]
判例 소취하합의의 의사표시 역시 민법 109조에 따라 법률행위의 내용의 중요 부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다.

[조건부 소취하합의]
判例 조건부 소취하합의를 한 경우에는 조건성취사실이 인정되지 않는 한 소송을 계속 유지할 법률상 이익을 부정할 수 없다.

[묵시적 합의해제]
判例 소취하합의 후 그 실현을 포기하려는 의사로 이를 주장하지 않고 방치했으므로 합의는 묵시적으로 합의해제되었다고 볼 것이다.

IV. 소송행위 취소와 철회
{소송행위 취소와 철회 template}
(소취하 효력 다투는 방법)
소취하 효력은 규칙67조의 기일지정신청을 하여 다툴 수 있다
기일지정신청 한 경우 법원은 변론을 열어 심사하여야 하며,
i) 소취하 효력을 부인하면 심리를 속행하며, ii) 소취하 효력을 인정하면 소송종료선언을 한다.

(민법 유추적용 취소가부)
하자불고려설: 절차 안정을 위해 표시주의 관철
하자고려설: 절차종료 행위는 절차 안정과 무관하므로
判例 소취하, 항소취하, 화해와 같은 "소송행위에는 민법상의 법률행위에 관한 규정이 적용될 수 없으므로 사기, 강박 또는 착오 등 의사표시의 하자를 이유로 그 무효·취소를 주장할 수 없다."
검토: 소취하에 중대한 하자가 있는 경우 451조1항5호를 유추해 철회하면 되고, 착오취소를 인정하면 절차안정을 해친다

[사무원의 착오] **(표착/착전무)**
判例 i) 사무원은 소송대리인의 표시기관으로서 ii) 그의 착오는 소송대리인의 착오로 보아야 하므로, iii) 사무원의 착오로 소송대리인의 의사에 반해 원고 전원의 소를 취하했어도 무효로 볼 수 없다.

(재심규정 유추적용 철회가부)
(형유의451/형강/남)
유죄확정판결 필요설: 민사법원이 형사범죄 유죄 여부 판단하는 것은 불가능
유죄확정판결 불요설: 당사자의 권리구제를 도외시할 수 있으므로
判例 i) 소송행위가 형사상 처벌 받을 타인의 행위로 이루어진 경우, ii) 타인의 행위에 대해 유죄판결이 확정되고 iii) 소송행위가 그에 부합되는 의사 없이 외형만 존재할 때에 한해 iv) 451조1항5호를 유추적용해 효력을 부인할 수 있다.

다만, 소취하가 형사책임이 수반되는 타인의 강요·폭행에 의해 이루어진 경우 유죄판결이 없어도 무효다.
검토: 유죄판결을 요구한 451조2항은 재심의 남용을 막기 위한 것이므로, 소송행위를 철회할 때는 유죄확정판결이 필요 없다고 해야 한다.

[인낙-민법유추적용 취소가부] **(형인직간/준)**
하자불고려설: 절차 안정을 위해 표시주의 관철
하자고려설: 절차종료 행위는 절차 안정과 무관하므로
判例 "i) 형사상 처벌받을 다른 사람의 행위로 인한 사유가 ii) 인낙에 대한 준재심사유가 되려면 iii) 그것이 인낙표시를 하게 된 직접적인 원인이 된 경우만이고, iv) 간접적인 원인밖에 되지 않은 경우까지 준재심사유가 된다고 볼 수 없다"고 하여 재심사유도 엄격히 해석하는 바 하자불고려설로 평가된다.
검토: 포기·인낙은 준재심의 소(461)로만 취소를 요구할 수 있으므로

<결석>
[변론기일과 변론준비기일 동종] **(일비적/재명)**
긍정설: 제286조에서 제268조의 규정을 준용
부정설: 변론기일과 변론준비기일은 실질적인 차이가 존재
判例 i) 변론준비기일을 변론기일의 일부라고 볼 수 없고 일체성을 갖는다고 볼 수도 없는 점, ii) 변론준비기일은 재판장에 의해 비공개로 진행되어 직접주의와 공개주의가 후퇴하는 점, iii) 취하간주제도는 적극적 당사자에게 불리한 제도인 점을 고려할 때 양쪽 당사자 불출석의 효과는 변론기일에 승계되지 않는다.
검토: 소취하간주 규정은 재판청구권을 제한하는 규정이므로 법률에 명백한 근거가 없는 한 제한불가

[상고대상 여부] **(항요재종)**
判例 i) 268조4항에서 정한 항소취하 간주는 ii) 그 규정상 요건의 성취로 의하여 당연히 발생하는 효과이고 iii) 법원의 재판이 아니므로 iv) 상고의 대상이 되는 종국판결에 해당하지 아니한다.
(규칙 67,68조 기일지정신청해야)

[재판상 자백 여부] **(자변진/출)**
재판상자백설: 서면에서 자백하겠다는 분명한 의사표시 했으므로
자백간주설: 진술간주는 결석자에게 유리하게 취급하는 것인데, 재판상자백으로 보면 그 취지에 반함
判例 i) 답변서나 준비서면에 자백하는 내용이 기재되어 있어도 ii) 그것이 변론기일이나 변론준비기일에서 iii) 진술 또는 진술간주 되어야 재판상자백이 성립한다.
검토: 출석했어도 자백할 것이 분명하므로

[서면에 의한 청구인낙 가부] **(인진변)** 이B 3회-2-1
긍정설: 진술간주제도의 취지, 인격권 존중
부정설: 신중을 기하기 위해
종래 判例 i) 인낙하는 취지를 기재한 준비서면을 제출하여 ii) 그 준비서면이 진술간주되었더라도 iii) 피고가 변론기일에 출석하여 구술로써 인낙하지 않은 이상 인낙의 효력은 발생하지 않는다.
검토: 출석하도록 강요해 소송을 지연시키고 당사자의 불편을 초래할 이유가 없으므로 긍정설이 타당.

<기일·기간 및 송달>
추후보완
[공시송달] **(처진의알)**
i) 처음부터 소장부본 등의 서류가 공시송달된 경우, 피고가 그 판결정본의 공시송달 사실을 모른데 과실이 없다. ii) 소송진행 도중 공시송달 된 경우, iii) 당사자에게 소송진행 상황을 조사할 의무가 있으므로 iv) 소송진행 상황을 알아보지 않았다면 과실이 있다.

[교도소수감 등]
判例 교도소 수감으로 인하여 또는 피고가 소송을 회피할 목적하에 등기부에 허위주소를 기재하는 바람에 송달불능되어 처음부터 공시송달된 경우 책임질 수 있는 사유이다.

[주소변경신고 간과]
判例 주소변경신고를 했음에도 법원이 신고를 간과하고, 이전 주소지로 기일통지서를 송달했다가 송달불능 되자, 일체의 서류를 공시송달한 경우 책임질 수 없는 사유이다.

[항소를 추완항소로 보는 경우] **(취주증처)**
判例 i) 항소하면서 추후보완항소라는 취지의 문언을 기재하지 않았더라도 ii) 그러한 주장이 있는 것으로 볼 수 있는 경우에는 당연히 그 사유에 대해 심판해야 하고, iii) 증거에 의해 항소기간의 경과가 책임질 수 없는 사유로 말미암은 것으로 인정되면 iv) 처음부터 추완항소라고 보아야 한다.

송달
[법인에 대한 송달] **(법이대보)**
判例 소장에 기재된 법인의 주소지로 발송했으나 이사불명으로 송달불능된 경우, 원칙으로 되돌아가 대표자의 주소지로 송달해보고 그곳으로도 송달되지 않을 때 주소보정을 명해야 한다.

[보충송달 template]
(교부송달의 원칙과 보충송달)
i) 송달은 특별한 규정이 없으면 송달받을 사람에게 서류를 교부한다. (178조1항) ii) 송달할 장소에서 송달받을 자를 만나지 못한 때에는 사리분별지능 있는 사람에게 보충송달 할 수 있다. (186조 1항)

[이해상반 수령대행인] **(상전쌍보)** 이B 5회-3-1
判例 i) 본인과 수령대행인 사이에 당해 소송에 관해 상반된 이해관계가 있는 때에는 ii) 수령대행인이 소송서류를 본인에게 전달할 것이라고 합리적으로 기대하기 어렵고, iii) 본인 대신 송달받는 것은 쌍방대리금지원칙에도 반하므로, iv) 수령대행인에게 보충송달할 수 없다.

[쌍방 동일한 수령대행인] **(동대전쌍보)** 이B 8회-2-2
判例 i) 동일한 수령대행인이 이해가 대립하는 소송당사자 쌍방을 대신해 서류를 동시에 수령한 경우 ii) 서류가 당사자에게 제대로 전달될 것이라고 합리적으로 기대하기 어렵고, iii) 쌍방대리금지원칙에도 반하므로, iv) 특별한 사정이 없는 한 보충송달은 무효이다.

[근무지 판단] **(경법영근)**
判例 i) 송달 받을 사람이 경영하는 그와 별도의 법인격을 가지는 회사의 사무실은 ii) 송달 받을 사람의 영업소나 사무소라 할 수 없고, iv) 그의 근무장소에 지나지 않는다.

[공시송달 template]
(부적법한 공시송달의 효력) **(재요명요명)**
判例 재판장이 요건이 충족된다고 보아 공시송달을 명한 이상 실제

로는 그 요건이 구비되지 않아 공시송달을 명할 수 없는 경우라도 그 명령에 의한 공시송달은 유효하다

(공시송달 적법한 경우) **(주2공책)**
判例 "i) 법인이나 대표자의 주소가 변경되었는데도 이를 신고하지 않아 ii) 2차에 걸친 변론기일소환장이 송달불능 되자 iii) 공시송달로 재판을 진행한 결과 쌍발불출석 취하간주 되었다면, iv) 이는 당사자의 책임으로 돌릴 수 없는 사유로 변론기일을 해태한 경우라고 볼 수 없다."고 하여 소 취하간주를 인정하였다.

(공시송달 부적법한 경우) **(주재적효변)**
判例 i) 당사자의 주소 등을 알 수 없는 경우가 아님이 명백함에도 ii) 재판장이 명함으로써 변론기일소환장이 공시송달 된 경우, iii) 당사자는 적법한 절차에 의한 송달을 받았다고 볼 수 없으므로, iiv) 공시송달의 효력이 있더라도 v) 변론기일에 출석하지 아니했다고 하여 쌍방불출석의 효과가 발생한다고 볼 수 없다.

<소송절차의 중단>
[당연승계] **(대소지대/238)**
긍정설: 포괄승계 원인의 발생으로 당연히 당사자로서의 지위가 상속인에게 승계
부정설: 당연승계개념은 형식적 당사자 개념과 부합하지 않으므로, 상속인이 수계절차를 밟아서 당사자로 표시되어야 당사자가 변경
判例 i) 대립당사자구조를 갖추고 적법히 소가 제기되었다가 ii) 소송 도중 당사자가 사망한 때에는, iii) 그때부터 소송은 지위를 당연히 이어받게 되는 상속인들과의 관계에서 iv) 대립당사자구조를 형성하여 존재한다.
검토: 238조가 소송대리인을 승계인의 대리인으로 보는 점

[수계신청] **(수상상수/경편)**
문제점: 수계신청은 중단 당시 소송이 계속되었던 법원에 해야 한다. 그런데 원심에서 중단사유가 발생했음에도 상소를 제기했다면 수계신청 법원에 대해 논의가 있다.
원심법원설: 243② 및 상소장원심법원 제출주의를 근거로
선택설: 소송경제를 위해 원심 또는 상소심에 수계신청 가능
判例 (i) 판결 선고 후 상속인이 수계신청하여 판결을 송달받아 상고하거나, (ii) 사실상 송달을 받아 상고장 제출하고 상고심에서 수계절차를 밟은 때에도 그 수계와 상고는 적법하다
검토: 소송경제와 당사자의 편의를 위해

[간과판결 효력] **(관무대/대)**
위법설: 당연승계긍정설의 입장에서 대립당사자구조를 간과한 위법은 없으므로 당연무효는 아니다
무효설: 당연승계부정설의 입장에서 대립당사자구조를 간과한 점은 제소 전 사망과 차이가 없다
判例 중단간과판결은 i) 소송에 관여할 수 있는 적법한 수계인의 권한을 배제한 절차상위법은 있지만, ii) 그 판결이 당연무효라 할 수 없고, iii) 적법하게 대리되지 않았던 경우와 마찬가지로 보아 상소 또는 재심에 의해 취소를 구할 수 있을 뿐이다.
검토: 당연승계 긍정한 이상 대립당사자구조를 간과한 위법이 있다고 볼 수 없다
(확정 전 상소 424조1항4호, 확정 후 재심 451조1항3호)

[소송대리인위임後 제소전사망]
(소의 적법) **(당소소시)**
判例 i) 당사자가 사망하더라도 소송대리인의 소송대리권은 소멸하지 아니하므로 (제95조 제1호), ii) 소송대리인에게 소송위임을 한 다음 소 제기 전에 사망하였는데 대리인이 당사자의 사망을 모르고 당사자를 원고로 표시하여 소를 제기하였다면 iii) 소의 제기는 적법하고, iv) 시효중단 등 소 제기의 효력은 상속인들에게 귀속된다.

{소송 중 사망, 상소특별수권 有, 상속인 C,D 누락}
(당연승계에 따른 판결의 효력) **(전망잘)**
判例 i) 소송대리인은 상속인 전원을 위해 소송을 수행하며 그 판결은 상속인 전원에게 효력이 있다. ii) 상속인이 불명할 때는 망인을 당사자로 표시해도 무방하며 iii) 신당사자를 잘못 표시했어도, iv) 정당한 상속인에게 판결 효력이 미친다.

(대리인이 상속인 중 일부에 대해 상소제기) **(잘합전)**
判例 i) 소송대리인이나 상대방이 잘못 기재된 당사자 모두를 상소인 또는 피상소인으로 표시해 상소제기한 경우, ii) 상소한 자의 합리적 의사에 비춰, iii) 정당한 상속인들 모두에게 효력이 미치는 판결 전부에 대해 상소가 제기된 것으로 본다.

제3장 증거 4개
[위법수집증거 증거능력] **(자위/실인단인)** 곽 7회-3-2
긍정설: 위법수집증거라도 조사해 실체적 진실 밝혀야 한다.
부정설: 소송상 신의칙에 반하고 인격권 침해를 가져온다.
절충설: 원칙적으로 부정하고, 위법성조각사유가 있으면 예외적으로 인정한다.
判例 2인간 대화 중 1인이 대화를 비밀녹음한 사건에서 "민사소송법이 증거에 관해 자유심증주의를 채택하고 있기 때문에 위법으로 수집되었다는 이유만으로 증거능력이 없다고 단정할 수 없다."
검토: 실체적 진실 발견과 인격권 보호를 조화하기 위해 원칙적으로 단순위법행위로 수집된 증거는 증거능력을 인정하고, 인격권을 침해해 위법수집된 증거는 증거능력 부정 (다른 절충설 취함)

<불요증사실>
I. 재판상자백
[선결적 법률관계] **(소권법동/소전소/요)**
긍정설: 소유권 문제는 사실관계와 다를 바 없어 자백 효력이 있다.
부정설: 법률판단에 관한 자백이므로 자백의 효력이 없다.
判例
1) 원칙부정
소송물의 전제가 되는 권리관계를 인정하는 진술은 권리자백으로서 법원을 기속하는 것도 아니며, 상대방의 동의 없이 자유로이 철회할 수 있다.
2) 사실에 대한 진술인 경우
소유권을 인정하는 진술은 그 전제가 되는 소유권의 내용을 이루는 사실에 대한 진술로 볼 수 있으므로 재판상자백이다.
검토: 요건사실인 토지소유사실은 요건 자체가 아닌 요건에 해당하는 구체적 사실이므로 판례 타당

(자기에게 불리한 진술) **(등증등자원/자)**
증명책임설: 상대방이 증명책임을 지는 사실만 불리한 진술
패소가능성설: 패소할 가능성이 있으면 자기에게 증명책임이 있는 사실도 포함
判例 소유권확인사건에서 "원고의 피상속인 명의로 소유권이전등기가 마쳐진 것이라는 점은 원고가 증명책임을 부담할 사항이지만, 위 등기를 마치지 않았다는 사실을 원고가 스스로 자인하고 이를 피고가 원용한 이상 자백이다."
검토: 자기책임원칙에 비추어 자기에게 증명책임 있는 사실도 자백

[간접사실] 이B 3회-1-2
긍정설: 금반언·자기책임을 근거
부정설: 주요사실이 아니므로 변론주의가 적용되지 않는바
判例 시효취득에서 점유개시시기는 요건사실인 점유기간을 판단하는데 수단구실을 하는 간접사실이므로 이에 대한 자백은 법원이나 당사자를 구속하지 않는다.
검토: 간접사실에 대한 자백이 법원을 구속하면 자유심증을 크게 제약하여 적정한 재판을 하기 어렵다

[진정성립] **(보주철인날/심신)** 이C8회-3-1
긍정설: 처분문서의 경우 진정성립이 갖는 의미와 중요성은 주요사실에 준하므로
부정설: 보조사실은 간접사실과 같은 역할을 하므로
判例 "i) 문서의 성립에 관한 자백은 보조사실에 관한 자백이나 ii) 그 취소에 관하여는 주요사실의 자백취소와 동일하게 처리해야 하므로 iii) 문서의 진정성립을 인정한 자는 이를 철회할 수 없다" 고 하여 자백을 긍정한다. 또한 "이는 문서에 찍힌 인영의 진정함을 인정했다가 철회하는 경우에도 같다"고 한다. 실무상 날인사실의 인정도 자백으로 처리한다.
검토: 자백으로 보고 철회를 제한하면 심리가 촉진되고, 금반언과 상대방 당사자의 신뢰보호 관점에서도

[준거법 합의사실] 이A6회-2-1
학설: 준거법 합의를 주요사실로 볼 수 없고, 직권조사사항으로서 자백의 대상이 아니다.
判例 i) 운송계약 당사자는 어느 국제협약을 준거법으로 하는 합의를 할 수 있고 ii) 그 준거법 합의가 있었다는 사실은 자백의 대상이다.
검토: 자백을 인정해도 합의를 허용하는 취지에 어긋나지 않는다.

cf. 권리자백
判例 원고가 운송계약이 몬트리올협약의 적용대상이라고 주장하고, 피고도 그에 대해 이의가 없다고 진술한 것은 준거법 내지 법적판단 사항에 관한 의견일 뿐 자백으로 볼 수 없다.
(+ 소송절차에서 당해사건에 적용할 규범에 관해 당사자가 일치하는 의견을 진술했어도 이를 준거법에 관한 합의가 성립된 것으로 볼 수 없다.)

(자백 철회방법) **(명배묵)** 곽4회-2-1
判例 자백의 취소는 반드시 명시적으로 해야 하는 것은 아니고, 종전의 자백과 배치되는 사실을 주장함으로써 묵시적으로도 할 수 있다.

(상대방 동의) **(이동착/이동)** 곽4회-2-1
判例 i) 자백을 취소하고 상대방이 이의 제기함 없이 동의하면 ii) 반진실, 착오 요건은 고려할 필요 없이 자백 취소를 인정해야 한다. iii) 그러나 자백 취소에 대해 상대방이 아무런 이의를 제기하고 있지 않다는 점만으로 취소에 동의했다고 볼 수 없다.

(진실에 반하고 착오 증명) **(반추/부변인)**
判例 i) 자백이 진실에 반한다는 증명이 있다고 하여 그 자백이 착오로 인한 것이라고 추정되는 것은 아니지만 ii) 그 자백이 진실과 부합되지 않는 사실이 증명된 경우라면 변론의 전취지에 의하여 그 자백이 착오로 인한 것이라는 점을 인정할 수 있다.

{선행자백, 진술간주 template} 이C 8회-2-2, 곽B 8회-1-1

(자인진술에 대한 상대방 원용 후 처리) **(선자원일)**
判例 i) 재판상 자백의 일종인 선행자백은 ii) 당사자 일방이 자기에게 불리한 진술을 자진해 한 후 iii) 상대방이 이를 원용함으로써 iv) 그 사실에 관해 쌍방 주장이 일치함을 요한다.

(자인진술에 대한 상대방 원용 전 처리) **(일선자원철)**
判例 i) 주장의 일치가 있기 전에는 ii) 선행자백이라 할 수 없고, iii) 따라서 자기에게 불리한 진술을 한 당사자도 iv) 상대방의 원용이 있기 전에는 v) 자인진술을 철회할 수 있다.

II. 자백간주
[청구원인사실 부인하는 답변서 제출한 경우]
判例 청구원인사실에 대한 주장을 부인하는 취지의 피고의 답변서가 제출되면 진술·진술간주 된 바 없어도 다툰 것으로 볼 것이다.
[청구기각판결만 구한 경우] 곽 3회-1-1
判例 청구기각판결을 구했을 뿐 청구원인사실에 대해 아무런 답변도 하지 않았다면 다툰 것으로 볼 수 없다.

[자백간주 후 공시송달] **(효공효자배)**
判例 i) 자백간주로서의 효과가 발생한 때에는 ii) 그 이후의 기일에 대한 소환장이 송달불능으로 되어 공시송달하게 되었어도 iii) 이미 발생한 자백간주의 효과가 상실되지 않으므로 iv) 자백한 것으로 간주해야 할 사실을 증거판단하여 v) 자백간주에 배치되는 사실인정을 하면 위법하다.

[공시송달 후 자백간주] **(공기다공다)**
判例 i) 1심에서 피고에 대해 공시송달로 재판이 진행되어 ii) 청구가 기각되었어도 iii) 원고 청구원인을 다툰 것으로 볼 수 없으므로, iv) 항소심에서 피고가 공시송달 아닌 방법으로 송달받고도 v) 다투지 아니한 경우 자백간주가 성립된다.

[무변론청구기각판결 가부]
긍정설: 절차의 신속과 원고와 피고의 평등 관점
부정설: 법률상 명문의 규정 없음
判例 무변론판결은 원고의 청구를 인용할 경우에만 가능하고, 원고의 청구가 이유 없음이 명백해도 변론이 없이 하는 청구기각 판결은 인정되지 않는다.
검토: 원고에게 가혹한 점을 이유로 입법화되지 않았는바

(현저한 사실 의의) **(직명기/직명)** 이B 3회-3-2
判例 다수의견: 법관이 직무상 알고 있는 사실로서 명확한 기억을 하고 있거나 또는 기록 등을 조사하여 곧바로 그 내용을 알 수 있는 사실
判例 소수의견: 법관이 직무상 안 사실도 명확한 기억을 하고 있지 않으면 현저한 사실이라고 할 수 없다.
검토: 적정한 재판을 위해 다수의견 타당.

(연령병 기대여명) 이B 3회-3-2
判例 생명표에 의한 연령별 기대여명은 법원에 현저한 사실이므로 당사자가 제출한 증거에 구애됨 없이 생명표에 의해 확정할 수 있다.

(확정판결이유 구성사실) **(판확채합현)** 이B 4회-3-2, 곽B 7회-1-1
判例 i) 확정판결의 존재를 넘어 판결이유를 구성하는 사실까지 법원에 현저한 사실로 볼 수 없다. ii) 이미 확정된 관련 민사사건에서 인정된 사실은 유력한 증거가 되지만, iii) 제출된 다른 증거 내

용에 비춰 채용하기 어려운 경우 iv) 합리적인 이유를 설시해 배척할 수 있다는 법리도 v) 그 사실이 현저한 사실에 해당하지 않음을 전제로 한 것이다.

<증거조사 개시와 실시>

증거조사 개시

[모색적 증명]

(의의) **(증입증)**

i) 증명책임을 지는 자가 사실의 경과과정을 상세히 모르는 경우, ii) 입증사항을 정확히 명시하지 않고 증거신청하면서 iii) 증거조사를 통해 구체적 주장의 기초자료를 얻어내는 것

(허용여부)

부적법설: 증거신청의 남용 우려

제한적 긍정설: 원칙 불허하되, 현대형 소송처럼 증거 편재가 심한 경우만 허용

검토: 당사자 형평을 위해 증거 편재가 심한 경우만 허용하되, 허용요건으로 i) 상대방이 사실관계를 해명하기 쉽고 ii) 추적가능한 실마리를 증명사실로 특정한 경우에만 허용함이 타당.

[유일한 증거]

(내용) **(주본당)**

1) 주요사실에 대한 증거

주요사실에 대해서만 유일한 증거인지 문제된다.

2) 본증에 한하는지

判例는 "유일한 증거는 입증책임이 있는 사항에 관한 것이며, 반증은 유일한 증거에 해당할 수 없다"고 판시.

생각건대, 본증이든 반증이든 배척되는 경우 당사자에게 패소의 불이익이 가해질 수 있으므로 본증과 반증을 구별하면 안 된다.

3) 당사자신문 해당여부

개정법 전 判例는 당사자신문은 다른 증거방법에 의하여 심증을 얻을 수 없을 때에 한해 할 것이므로 그 신청을 각하했다고 하여 유일한 증거를 각하한 위법이 없다고 하였으나 당사자신문의 보충성이 폐지되었으므로 유지될 수 없다.

증거조사 실시

[원칙-자유심증에 따른 판단] **(증자다)** 이B 3회-3-1

判例 i) 감정인의 감정결과는 증거방법의 하나에 불과하고, ii) 법관은 당해 사건에서 모든 증거를 종합해 자유심증에 의해 iii) 특정의 감정결과와 다르게 판단할 수 있다.

[당사자 원용 없는 경우] **(현변원)** 곽3회-3-2

判例 법원은 감정결과를 법정에 현출시켜 당사자에게 변론기회를 주어야 하고, 법정에 현출된 이상 당사자가 원용한다는 진술을 하지 않아도 증거자료로 사용할 수 있다.

[상반된 감정결과의 경우] **(어자논)** 곽3회-3-2

判例 상반된 감정결과 중 어느 것에 의해 사실인정 할지는 법원의 자유심증의 범위에 속하는 것으로서 논리와 경험칙에 위반되지 않는 한 적법하다.

[일부 오류가 있는 경우] **(오모일나)**

判例 i) 감정결과 일부에 오류가 있는 경우에도 ii) 그로 인해 감정결과가 전체적으로 서로 모순되거나 매우 불명료한 것이 아닌 이상, iii) 그 일부 부분만 배척하고 iv) 나머지 부분에 관한 감정결과는 증거로 채택해 사용할 수 있다.

{판결서 실질적 증거력 template} 이B 4회-3-1, 곽B 7회-1-1

判例 다수의견 **(판증보자사)**

판결서는 판시내용대로 어떤 사실이 있었는가를 증명하는 한도에서 보고문서성도 있어 자유심증으로 판결서를 사실인정의 자료로 삼을 수 있다고 한다.

判例 소수의견: 판결서의 내용은 '사실이 있었지 않겠느냐'하는 하나의 의견에 불과해 사실을 증명하는 자료로 사용할 수 없다.

검토: 판결서는 증거자료를 근거로 신중히 요증사실을 판단한 것이므로 보고문서성을 가진다.

{형식적 증거력 template} 이C 8회-3-1

(날인의 진정 추정 복멸)

(도용의 항변) **(날작사/인다반/인의)**

判例 i) 날인행위가 작성명의인 의사에 기한 것이라는 추정은 사실상 추정이므로, ii) 인영의 진정성립을 다투는 자가 반증을 들어 iii) 인영의 진정성립에 관해 법원으로 하여금 의심을 품게 할 사정을 입증하면 추정은 깨진다.

(재항변) **(인날작/문날작위)**

判例 i) 인영의 진정성립 추정은 날인행위가 작성명의인 이외의 자에 의해 이루어진 것임이 밝혀진 경우에는 깨지므로, ii) 문서제출자는 날인행위가 작성명의인으로부터 위임받은 정당한 권원에 의한 것이라는 사실까지 입증할 책임이 있다.

(진정성립의 추정 복멸)

[진정성립 추정 복멸 방법]

判例 (반증설) 358조는 유사적 추정으로서 사실상 추정을 명문화한 것에 불과해 다투는 자가 "반증으로" 진정성립에 관해 의심을 품게 하는 사정을 입증하면 추정이 번복된다.

본증설: "작성명의인의 의사에 기하지 않고 작성된 것이라는 것은 그것을 주장하는 자가 적극적으로 입증해야 한다"고 하였으므로 본증

검토: 반증을 들어 적극적으로 입증해야 한다는 취지이므로 반증

(백지문서 증명시 진정성립 추정 깨지는지)

1) 추정이 깨진다는 입장 **(작날백/백작보)**

判例 i) 작성명의인의 날인만 되어 있고 내용이 백지로 된 문서를 교부받아 ii) 백지 부분을 작성명의자가 아닌 자가 보충한 문서의 경우에는 문서의 진정성립의 추정이 깨진다.

2) 추정이 깨지지 않는다는 입장 **(보완)**

백지로 날인된 문서를 주었으면 백지보충권도 준 것으로 보아야 하고, 358조는 기재후 날인한 완성문서에 한한다고 볼 수 없으므로 백지문서의 경우 추정이 깨지지 않는다.

(재항변) **(진백/문기작위)**

判例 i) 진정성립 추정은 백지문서임이 밝혀진 경우에는 깨지므로, ii) 문서제출자는 그 기재 내용이 작성명의인으로부터 위임받은 정당한 권원에 의한 것이라는 사실을 입증할 책임이 있다.

{실질적 증거력 template} 이C7회-2-3

(복멸) **(진반기합)**

判例 i) 처분문서의 진정성립이 인정되면 ii) 반증이 없는 한 iii) 법원은 문서의 기재 내용에 따른 의사표시의 존재와 내용을 인정해야 하고, iv) 합리적인 이유 설시도 없이 배척해서는 안 된다.

[사본제출 형태]
(원본에 갈음하여 제출한 경우) **(존진대사)**
判例 "i) 원본의 존재와 진정성립에 관해 다툼이 없고, ii) 사본을 원본의 대용으로 함에 상대방의 이의가 없는 경우 iii) 사본만의 제출도 허용된다." 이 경우 원본제출과 같은 효력이 있다.

(원본으로 제출한 경우)**(독존진사)**
判例 i) 사본을 원본으로서 제출하는 경우 사본이 독립한 서증이 되나 원본이 제출된 것으로 되지 않고, ii) 증거에 의해 사본과 같은 원본이 존재하고 iii) 원본이 진정하게 성립했음이 인정되지 않는 한 iv) 사본이 존재한다는 것 이상의 증거가치는 없다.

[문서제출명령]
(문서제출명령 의의) (343조후단) **(제/증)**
i) 상대방 또는 제3자가 가지고 있는 제출의무 문서에 대해 제출명령을 신청하는 것으로서 ii) 증거개시제도와 같은 효과를 달성하기 위함이다.

(인용문서 의의) **(증자근보)**
判例 i) 증거로 인용한 경우뿐 아니라 ii) 자기주장을 명백히 하기 위해 적극적으로 문서의 존재와 내용을 언급하여 iii) 자기주장의 근거 또는 iv) 보조로 삼은 문서도 포함한다.

(제출거부 가부)
判例 인용문서에 해당하는 이상, 344조 2항에서 규정하는 바와 달리, 그것이 공무원이 직무와 관련해 보관하거나 갖고 있는 문서라도 제출의무를 면할 수 없다.

(직업의 비밀·보호가치 판단) **(공보/제공불실공)**
判例 i) 직업의 비밀은 공개되면 해당 직업에 심각한 영향을 미치는 경우인데, ii) 보호가치가 있는 비밀일 경우에만 문서제출을 거부할 수 있다. iii) 보호가치를 판단함에 있어서는 제반 사정을 종합해 비밀공개로 발생하는 불이익과 실체적 진실의 발견 및 재판의 공정을 비교형량한다.

(의의) **(목내소/문목외/개불)**
判例 i) 문서의 작성목적, 기재내용, 문서의 소지 경위나 그 밖의 사정을 종합적으로 고려할 때, ii) 오로지 문서소지자가 이용할 목적으로 작성되고 외부자에게 개시하는 것이 예정되어 있지 않으며, iii) 개시할 경우 문서소지자에게 간과하기 어려운 불이익이 생길 염려가 있다면 자기이용문서이다.

(회사내부 문서) **(열사동/외목/내자)**
긍정설: 자유로운 의사결정을 보장하기 위해
부정설: 회사내부의 의사결정이라도 투명성 확보 위해
判例 i) 신청자가 열람을 요구할 수 있는 사법상 권리를 갖는 문서와 동일한 정보가 당해 문서 내용에 포함된 경우 ii) 외부에서의 이용이 작성 목적에 전혀 포함되어 있지 않다고는 볼 수 없는 경우 iii) 내부문서라는 이유로 자기이용문서라고 쉽게 단정할 것은 아니다.
검토: 판례처럼 문서의 작성목적, 기재내용, 문서의 소지경위나 그 밖의 사정을 종합해 객관적으로 판단한다.

사안포섭 **(합내목/회의개불)**
判例 i) 합병과 관련해 교신한 공문은 오로지 내부이용에 제공할 목적으로 작성된 내부문서라고 단정할 수 없고, ii) 내부회계기준이나 결의서와 같이 이미 의사결정이 내려진 상태에서 작성되는 문서는 그 문서의 성질상 개시로 인해 문서소지자에게 심각한 불이익이 생긴다고 보기 어려워 자기이용문서에 해당하지 않는다.

[2항 거부사유 증명책임]
신청자설: 조문형식상 1항 3호의 경우 거부사유가 단서로 되어 있으므로 문서소지자가 거부사유를 증명해야 하나, 2항의 경우 거부사유 부존재가 본문에 규정되어 있어 신청자가 거부사유 부존재에 관해 증명책임
소지자설: 신청자가 거부사유 부존재를 증명하는 것은 매우 어렵기 때문에 소지자가 거부사유 증명책임
검토: 문서제출명령신청 단계에서는 거부사유에 해당하는 문서인지 여부가 구체적으로 증명될 수 없는 바 소지자설 타당.

[의견진술기회부여] **(송의/존소서제)**
判例 i) 문서제출신청에 관한 재판 할 때는 상대방에게 문서제출신청서를 송달하는 등 그에 관한 의견진술기회를 부여하고, ii) 문서의 존재와 소지여부, 문서가 서증으로 필요한지 여부, 344조에 따라 제출의무를 부담하는지 여부 등을 심리한 후 허가 여부를 판단해야 한다.

[필요하지 않은 경우]
判例 문서가 서증으로 필요하지 않다고 인정할 때에는 제출명령신청을 받아들이지 않을 수 있다. 또한 문서에 의해 입증하려는 사항이 당해 청구와 직접 관련이 없는 것이면 받아들이지 않을 수 있다.

(증명방해 의의 및 제제근거) **(고불/신)**
i) 고의나 과실로 ii) 상대방의 증명을 불가능하게 하거나 곤란하게 하는 것. iii) 신의칙에 어긋나는 행위에 해당하므로 제재가 있다.

(증명방해 효과 - 349) **(문주증/가편해)**
자유심증설: 증명방해를 변론의 전 취지로 삼아 어느 정도 불리한 판단을 할지 법관의 자유심증에 맡긴다
법정증거설: 증명할 사실 자체가 바로 증명된 것으로 본다
증명책임전환설: 증명방해자에게 증명책임이 전환된다
절충설: 원칙적으로 자유심증설을 취하면서 현대형소송에 한해 법정증거설
判例 i) 문서제출명령에 따르지 아니한 경우 ii) 법원은 상대방의 문서의 성질·내용·성립의 진정에 관한 주장을 진실한 것으로 인정해야 한다는 것이지, iii) 문서에 의해 증명하려고 하는 주장사실이 증명되었다고 인정해야 하는 것은 아니다.
검토: 증명책임전환설과 법정증거설은 증명방해자에게 가혹. 절충설은 모든 현대형 소송에서 증거가 편재되어 있다고 볼 수 없다. 자유심증설이 349조의 해석과 부합한다.
(증명방해 효과 - 350) **(문주증/가편해)** 이C7회-2-1
判例 i) 상대방 사용을 방해할 목적으로 문서를 훼손한 경우 ii) 법원은 훼손된 문서부분의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. 그러나 문서에 의해 증명하려고 하는 주장사실이 증명되었다고 볼 수는 없다.

(사용방해 목적 없이 훼손된 문서 제출) **(훼취불)** 이C 7회-2-2
判例 i) 문서의 훼손된 부분에 잔존부분과 상반되는 내용의 기재가 있을 가능성이 인정되어 ii) 문서 전체의 취지가 제출자의 주장에 부합한다는 확신이 없으면 iii) 이로 인한 불이익은 훼손된 문서를 제출한 당사자에게 돌아간다.

(증명방해 효과 - 369) **(369주요/가편해)**
判例 i) 369조에 의해 법원이 진실한 것으로 인정할 수 있는 것은 ii) 신문사항에 관한 상대방의 주장 즉 신문사항에 포함된 내용에 관한 것이므로 iii) 상대방의 요건사실에 관한 주장사실을 진실한 것으로 인정할 것은 아니다.

(증명방해 효과 - 명문의 규정 無) **(증자전/가편)**
判例 i) 의사측의 진료기록 변조행위는 증명방해 행위로서 ii) 법원은 이를 하나의 자료로 하여 자유로운 심증에 따라 방해자에게 불리한 평가를 할 수 있을 뿐 iii) 증명책임이 전환되거나 곧바로 상대방 주장사실이 증명된 것으로 보아야 하는 것은 아니다.

IV. 검증
[녹음테이프 증거조사 방법]
서증설: 증거 평가의 대상이 녹음테이프의 발언 내용에 있는 이상
검증설: 녹음테이프는 서면성이 흠결
判例 녹음테이프에 대한 증거조사는 검증의 방법에 의해야 한다.
실무적으로는 녹음테이프의 검증시에는 녹취서를 제출하게 하여 녹음내용과 녹취서의 기재가 일치하는지 여부를 대조하는 방식으로 검증을 시행한다.
검토: 재생할 음성이나 영상을 수록하고 있음에 그치므로

V. 당사자신문
(의의·법적성격) **(당경증)**
당사자 본인을 증거방법으로 하여, 그가 경험한 사실에 대해 진술하게 하여 증거자료를 얻는 증거조사이다. 여기에서의 진술은 증거자료이지 소송자료가 아니다.

(다른 증거신청에 앞선 당사자신문 신청가부) **(공/사신/367신진선)**
문제점: 보충성은 다른 증거조사에 의해 충분한 심증을 얻지 못한 때에 한해 당사자를 신문할 수 있다는 것
보충성 유지론: 당사자는 공정한 진술을 기대하기 어렵다
보충성 폐지론: 당사자는 사건 내용을 잘 알고 있는데 다른 증거를 조사한 후에만 조사할 수 있다면 재판의 신속에 방해
2002년 개정법: 개정법 367조는 신속하게 당사자 본인을 신문할 수 있도록 당자사신문의 보충성을 폐지하고, 당사자 진술의 진실성을 담보하기 위해 신문 전에 반드시 선서하도록 했다.

(당사자신문 결과만으로 주요사실 인정가부) **(확당다/완)**
判例 i) 개정법 전의 당사자신문의 증거방법으로서의 보충성을 증거력으로서의 보충성으로까지 확장해석하여 ii) 당사자신문 결과만 가지고는 주요사실을 인정할 수 없고 iii) 다른 증거와 합해서만 비로소 주요사실을 인정할 수 있다는 입장이었다.
검토: 당사자신문도 일단 적법하게 채택되면 완전한 가치가 있는 증거방법이므로 그 결과만으로 주요사실을 인정할 수 있다고 해야

<자유심증주의>
[독립적 증거원인] **(변사보/안)** 곽4회-3-2
보충적 증거원인설: 변론 전체의 취지는 모호하여 증거자료가 더 있어야 다툼이 있는 사실을 인정할 수 있다.
독립적 증거원인설: 202조는 항상 증거자료를 참작하라는 의미는 아니므로, 변론 전체 취지만으로 다툼이 있는 사실 인정할 수 있다.
判例 주요사실에 대해 변론 전체의 취지만으로는 사실을 인정할 수 없고, 다만 사실인정의 자료가 되는 다른 증거방법의 보충적 권능을 다할 뿐이다.
검토: 법관이 안일하게 사실을 인정할 염려

[증거공통원칙] **(어제원어유/평자)** 곽7회-3-2
긍정설: 제출한 증거를 어떻게 평가할지는 변론주의와 무관한 법원의 전권사항
부정설: 증거제출에도 변론주의가 적용되어 상대방이 증거를 원용하지 않으면 그에게 유리하게 이용할 수 없다.
判例 증거는 어느 당사자에 의해 제출되거나 상대방이 이를 원용하는 여부에 불구하고 당사자 어느 쪽의 유리한 사실인정 증거로 할 수 있다.
(+ 상대방이 제출한 증거방법을 원용하지 않은 경우, 상고이유에서 새삼스럽게 그 증거 판단의 유탈을 주장할 수 없다.)
검토: 증거평가는 증거제출에 관한 것이 아니고 증거제출 후의 자유심증의 문제이므로

<증명책임>
{기본 template}
(증명책임 의의 및 분배기준) **(요사/법주상)**
의의: i) 소송상 요증사실의 존부가 확정되지 않을 때에 ii) 당해 사실이 존재하지 않는 것으로 취급되는 불이익.
분배기준: 통설·判例인 i) 법률요건분류설의 입장에 따라, ii) 권리의 존재를 주장하는 자는 권리근거규정의 요건사실에 대한, iii) 상대방은 반대규정의 요건사실에 대한 증명책임을 진다.
소송요건의 경우: 본안판결을 받는다는 것 자체가 원고에게 유리한 점에 비추어 직권조사사항인 소송요건에 대한 입증책임은 원고에게 있다.

(부당이득반환청구 법률상원인흠결에 대한 증명책임) 이C 8회-2-1
민법 741조는 권리근거규정이므로 법률상 원인흠결을 포함한 부당이득 성립요건 모두에 대해 청구권자에게 증명책임이 있다는 견해
判例
1) 급부부당이득: 법률상 원인이 없다는 점에 대한 증명책임은 부당이득반환을 주장하는 사람에게 있다. 반환을 구하는 자는 급부행위의 원인이 된 사실의 존재와 함께 그 사유가 무효, 취소, 해제 등으로 소멸되어 법률상 원인이 없게 되었음을 주장·증명해야 한다.
2) 침해부당이득: 부당이득반환청구의 상대방이 그 이익을 보유할 정당한 권원이 있다는 점을 증명할 책임이 있다.
검토: 증명의 난이도를 고려한 형평의 관점

(무권대리 책임에 대한 증명책임) 이C3회-1-3
(대리권수여, 추인사실) **(원주무증)**
1항은 권리근거규정이다. 규정상 대리권수여사실 또는 추인사실의 증명책임은 무권대리인에게 전환되므로, 원고가 주장책임을 부담하나 무권대리인이 증명책임을 부담한다.
(대리권 없음 알았거나 알 수 있었다는 사실) **(주증무)**
判例 2항은 무권대리인의 무과실책임에 관한 원칙 규정인 1항에 대한 예외규정이므로 상대방이 대리권 없음을 알았거나 알 수 있었다는 사실에 대한 주장·증명책임은 무권대리인에게 있다.

(등기의 추정력)
(추정력의 성질) **(권다무법/신)**
법률상 추정설: 점유에도 법률상 추정을 인정한 것과 균형상 법률상 추정이라고 보며, 상대방이 본증을 제출하여 반대사실에 대해 확신을 갖게 해야 한다는 점에서 증명책임이 전환
사실상 추정설: 명문의 규정도 없으므로 사실상 추정이라고 보며, 상대방은 반증을 제출하여 추정사실에 대해 의심을 갖게 하면 충분하다는 점에서 증명책임이 전환되지 않는다
判例 "소유권이전등기는 i) 권리의 추정력이 있으므로, ii) 이를 다

투는 측에서 무효사유를 주장·증명하지 않는 한, iii) 등기를 무효라고 단정할 수 없다" 고 하여 iv) 법률상추정으로 본다.
검토: 등기를 신뢰한 제3자 보호

{공해소송 template} 이C 3회-2
(증명정도 완화로서 개연성이론) **(침손인상/반인)**
i) 침해행위와 손해 사이에 인과관계가 존재한다는 상당정도의 가능성을 입증함으로써 족하고 ii) 가해자는 이에 대한 반증을 한 경우에만 인과관계를 부정할 수 있다는 것이다.

(공해소송 判例)
(배도손/배손인)
判例 피해자가 i) 오염물질이 포함된 침출처리수 배출 및 어장 도달사실과 iii) 손해발생사실을 증명하면, 침출처리수 배출과 어장 손해 사이에 인과관계가 일응 증명된다.

(반원안/간손다)
判例 인과관계를 부정하려면 i) 반증으로 침출처리수에 원인물질이 없거나 있더라도 안정농도 내라는 사실을 증명하거나 ii) 간접반증으로 어장 손해는 침출처리수가 아닌 다른 원인에 의한 것이라는 사실을 증명해야 된다.

제4편【소송의 종료】
제2장 당사자에 의한 종료 3개
<소취하>
[선결관계] **(소전다동/다)** 이C 4회-3-3
긍정설: 선결관계로 하는 때도 재소금지의 제재를 가할 필요가 있으므로 동일한 소로 보아 재소금지
부정설: 선결관계로 하여 기판력이 후소에 작용하는 경우, 후소가 각하되는 것은 아니므로 재소를 각하하면 기판력을 받을 때보다 더 가혹
判例 i) 비록 소송물은 다르지만 ii) 원고는 전소의 목적이었던 권리·법률관계 존부에 대해 iii) 다시 법원 판단을 구할 수 없는 관계상 iv) 후소도 동일한 소로써 판결을 구할 수 없다
검토: 후소가 선결관계에 있는 때에도 전소의 법률관계에 대해 다시 심판을 요구하는 것이므로 재소금지 타당

<청구의 포기·인낙>

<재판상화해>
{제소전/소송상 화해 template}
(소송상화해 법적성질) **(소순/220461)**
사법행위설: 사법상 화해계약과 동일
소송행위설: 기판력을 발생시키는 소송행위로 소송법에 따라 규율
양성설: 사법행위와 소송행위의 성질을 모두 갖는 1개의 행위
判例 i) 소송상 화해는 소송물인 법률관계를 확정시키는 효력이 있으므로 ii) 순연한 소송행위로 볼 것이다. 다만, 조건부 화해와 창설적 효력을 인정한 것은 양성설의 태도
검토: 화해조서는 220조에 따라 확정판결과 같은 효력을 가지고, 이 조서에 대해 461조에 따라 준재심의 소만 제기할 수 있는 명문의 규정에 따라 소송행위설 타당.

(제소전화해 법적성질)
判例 재판상 화해는 순수한 소송행위로서 확정판결과 같은 기판력이 있다. 다만, 조건부 화해와 창설적 효력을 인정한 것은 양성설의 태도

(실체법상 하자 있는 경우 기판력 인정여부) **(재사화/준)**
이B 3회-4
무제한기판력설: 220조, 461조를 근거로 화해는 확정판결처럼 기판력을 가지므로 실체법상 무효·취소·해제를 주장할 수 없다.
제한적기판력설: 당사자의 권리구제를 위해 실체법상 하자가 없는 경우에만 기판력이 생기므로 실체법상 무효·취소·해제를 주장할 수 있다.
기판력부정설: 자주적 해결방법인 화해에 기판력을 인정할 수 없으므로 실체법상 무효·취소·해제를 주장할 수 있다.
判例 i) 재판상 화해는 순수한 소송행위로서 ii) 사법상 화해와는 달리 실체법상 무효·취소·해제를 주장하는 것과 같은 iii) 화해조서의 취지에 반하는 주장을 할 수 없다.
검토: 현행법상 준재심에 의해 취소되지 않는 한 화해의 취지에 반하는 주장을 할 수 없다고 할 것인바

(화해 조건 가부) **(합이조/자)** 이C 3회-3-2
긍정설: 사법행위설이나 양성설의 입장에서 조건부 화해는 사적 자치의 원칙상 당연히 허용.
부정설: 소송행위설은 법적 안정성을 내세워 조건부 화해 허용 X
判例 i) 재판상 화해의 내용은 합의에 따라 자유로이 정할 수 있으므로 ii) 제3자의 이의가 있을 때에는 화해의 효력을 실효시키기로 하는 내용의 재판상 화해가 성립되었다면 iii) 그 조건의 성취로써 화해 효력은 소멸한다.
(화해의 성질에 대해 기본적으로 소송행위설에 의하지만, 조건부 화해를 긍정한다)
검토: 재판상 화해는 판결과 달리 자치적 해결방법인만큼, 화해가 원활하게 성립될 수 있도록 조건을 허용하는 것이 타당.

제3장 종국판결에 의한 종료 4개
{기판력 기본 template}
(기판력의 의의) **(구/안)**
i) 확정된 종국판결의 내용이 가지는 후소에 대한 구속력. ii) 다시 다툴 수 없게 하여 법적 안정성 보장

(기판력 본질)
모순금지설(判): 기판력을 확정판결과 모순된 판단을 금지하는 효력으로 보고, 동일한 소를 승소자가 제기하면 소의 이익 흠결로 각하, 패소자가 제기하면 기각한다.
반복금지설: 기판력을 다시 재판함을 금지하는 효력으로 보고, 승패 불문하고 동일한 소제기시 기판력을 이유로 각하한다.
검토: 반복금지설은 선결 또는 모순관계처럼 소송물이 다른 경우에 이를 반복이라고 할 수 없음에도 불구하고 기판력이 작용하는 근거를 설명할 수 없으므로 모순금지설이 타당.

<기판력의 주관적 범위>
{변론종결 뒤 승계인 218① template}
[채권 승계]
判例 채권양수인이 변론종결 후 승계인에 해당하는지 여부는 채권양도합의가 이루어진 때가 아니라 대항요건이 갖추어진 때를 기준으로 판단한다.

[변종 전 승계인으로부터 변종 후 승계] **(12변)**
判例 i) 1차 승계가 이미 변론종결 이전에 있었다면, ii) 2차 승계가 변론종결 후에 있었더라도 iii) 2차 승계인은 변론종결 뒤 승계인으로 볼 수 없다.

(승계인의 범위 - 계쟁물 승계인) **(채변변/양실)**
구이론: 소송물이 물권적 청구권인 경우에만 대세효가 있어 계쟁물 승계인이 변론종결 뒤 승계인에 포함된다.
신이론: 소송물이 채권적 청구권인 경우도 포함된다.
判例 전소 소송물이 채권적 청구권일 때, 변론종결 후 등기를 경료받은 자는 변론종결 후의 제3자에 해당하지 않는다.
검토: 소송물이 채권적 청구권인 경우, 계쟁물 승계인은 원고와 양립하는 권리를 갖고, 원고에게 아무런 실체법상 의무를 부담하지 않으므로 (취득시효 이전등기청구권은 채권적청구권임!)

(고유의 방어방법이 있는 경우) **(명확매변/부)**
실질설: 방어방법이 있으면 변론종결 뒤 승계인이 아니므로, 승계집행문이 부여되지 않고, 집행문부여의 소를 제기해야 한다.
형식설: 방어방법이 있어도 변론종결 뒤 승계인이므로, 승계집행문이 부여되고, 승계인이 집행문부여 이의의 소를 제기해야 한다.
判例 명의신탁해지를 원인으로 청구한 경우, "소유권이전등기를 명하는 확정판결의 변론종결 후 목적물을 매수해 등기를 한 자는 변론종결 뒤 승계인에 해당하지 않는다."
검토: 승계인에게 집행문부여 이의의 소를 제기하게 부담을 주는 것은 부당

[물권적청구권 소송 원고측 계쟁물 승계인] **(소기/변패적패변)**
判例 i) 소송물은 인도청구권이므로 ii) 기판력은 인도청구권에만 미치고, 소유권 존부에는 미치지 않는다.
iii) 변론종결 후 iv) 패소자인 소유자로부터 소유권을 승계한 제3자가 갖는 인도청구권은 v) 적법하게 승계한 소유권의 일반적 효력으로서 발생된 것이고, vi) 패소자의 인도청구권을 승계해 갖게 된 것이 아니다. vii) 따라서 위 제3자는 변론종결 뒤 승계인에 해당하지 않는다.
判例 i) 소송물은 가등기말소청구권이므로, ii) 기판력은 가등기말소청구권에만 미치고, 소유권 존부에는 미치지 않는다.
iii) 변론종결 후 iv) 패소자인 소유자로부터 근저당권을 취득한 제3자가 갖는 말소청구권은 v) 적법하게 취득한 근저당권의 일반적 효력으로서 발생된 것이고, vi) 패소자의 가등기말소청구권을 승계해 갖게 된 것이 아니다. vii) 따라서 위 제3자는 변론종결 뒤 승계인에 해당하지 않는다.
학설: 기판력의 주관적 범위를 객관적 범위와 연계시킨 문제
검토: 기판력 확장여부는 정책적 문제인데, 승계인의 절차권 보장을 위해 판례 지지

{제3자소송담당 218③ template}
c1.[대위소송 확정판결 효력이 채무자에게 미치는지]
적극설: 담당설의 입장에서, 218조3항에 의해 기판력이 채무자에게 어느 경우나 미친다
절충설: 담당설의 입장에서, 채무자의 절차보장을 중시하여 대위소송이 제기된 사실을 채무자가 알았을 경우에만 기판력이 채무자에게 미친다.
소극설: 고유의 대위권설의 입장에서, 대위소송은 담당이 아니므로 218조3항이 적용되지 않아 기판력이 미치지 않는다.
判例 다수의견: 어떤 사유로든 대위소송이 제기된 사실을 채무자가 알았을 경우에는 그 판결의 효력이 채무자에게 미친다.
判例 소수의견: 기판력이 채무자에게 미치는 근거를 218조3항에서 찾는 한 피대위자가 알고 모르고를 가릴 근거가 없다
검토: 적극설에 의하면 채무자에게 가혹하고, 소극설에 의하면 제3채무자에게 가혹하므로, 공평과 분쟁의 1회적 해결을 도모하는 절충설이 타당.

c2.[채무자의 확정판결 효력이 대위채권자에게 미치는지]
1 [채무자→제3채무자 소제기 패소확정後 대위소송 제기]
1) 기판력 **(대판실효/채)**
기판력설: 담당설의 입장에서, 대위채권자는 채무자의 지위에 서기 때문에 기판력이 미친다
반사효설: 담당설의 입장에서, 채무자와 실체법상 의존관계에 있는 채권자에게 반사효
법률요건적 효력설: 고유의 대위권설의 입장에서, 민법 404조의 대위권이 발생하지 않는 결과 채권자가 패소
判例 i) 채권자가 채무자를 대위하여 제3자를 상대로 제기한 소송과 ii) 이미 판결확정이 되어 있는 채무자와 그 제3자 간의 기존소송이 iii) 당사자만 다를 뿐 실질적으로 동일 내용의 소송이라면 iv) 위 확정판결의 효력은 대위소송에 미친다. (76다688, 80다2751)
검토: 대위채권자는 채무자의 지위에 서므로 기판력의 확장으로
2) 당사자적격 흠결

2 [제3채무자→채무자 소제기 승소확정後 대위소송 제기]
1) 기판력 **(3소/이보/소3)**
기판력설, 반사효설, 법률요건 효력설 (학설 이름만 소개)
判例 i) 제3자가 소유자를 상대로 이전등기절차이행의 확정판결을 받아 등기를 경료한 경우, ii) 이전등기청구권을 갖는 자가 청구권을 보전하기 위해 iii) 소유자를 대위해 제3자 명의의 말소등기를 구하는 것은 기판력에 저촉된다.
검토: 대위채권자는 채무자의 지위에 서므로 기판력의 확장으로
2) 당사자적격 흠결 **(기이피)**
判例 i) 채무자가 기판력에 저촉되는 말소청구를 할 수 없고 ii) 대위채권자에 대한 채무자의 소유권이전등기의무는 이행불능이다. iii) 피보전채권이 인정되지 않는 이상 원고에게 당사자적격이 없어 부적법하다. (이중매매 74다2229, 조정 2009다104960)
c3.[대위소송 확정판결 효력이 다른 채권자에게 미치는지]
기판력설: 담당설의 입장에서, 대위소송이 제기된 사실을 채무자가 알았을 때 채무자는 기판력을 받으므로, 이 채무자를 통해 다른 채권자의 대위소송에 기판력이 미친다.
반사효설: 담당설의 입장에서, 채무자와 실체법상 의존관계에 있는 다른 채권자에게 반사효
부정설: 고유의 대위권설의 입장에서, 각 채권자는 자신의 대위권을 행사하는 것이므로 판결의 효력 받지 않는다.
判例 i) 어떤 사유로든 대위소송이 제기된 사실을 채무자가 알았을 경우에 한해 그 판결 효력이 채무자에게 미치므로, ii) 그 후 다른 채권자가 동일한 소송물에 관해 대위소송을 제기하면 전소 기판력을 받는다.

c4.[대위소송 피보전채권無 소각하판결확정後
채권자→채무자 피보전채권 이행소] **(대소소피)** 이B 7회-2-2
判例 i) 대위소송이 채무자에게 기판력이 미치는 것은 ii) 소송물인 피대위채권 존부에 관해 인정되는 것이지, iii) 소송요건인 피보전채권 존부에 대해 당사자가 아닌 채무자에게 기판력이 인정되는 것은 아니므로, iv) 피보전채권 흠결로 인한 소각하 판결 후 채권자가 채무자를 상대로 한 피보전채권 이행청구에는 기판력이 미치지 않는다.

c5.[채권자→채무자 피보전채권 이행소 패소확정後 대위소송 제기]
이B 7회-2-1
1) 기판력
判例 기판력은 당사자가 다를 때는 미치지 않음이 원칙이므로 채권자의 채무자에 대한 전소판결의 기판력이 후소에 미친다고 할 수 없다.

2) 당사자적격 흠결 **(말동보부)**
判例 i) 가사 채권자가 대위소송에서 승소하여 제3자 명의의 소유권이전등기가 말소된다 하여도 i) 채권자가 채무자에 대해 동일한 청구원인으로 다시 이전등기절차의 이행을 구할 수 있는 것도 아니므로, iii) 채권자는 대위권행사로 청구권을 보전할 필요성이 없다. iv) 대위소송은 부적법한 것으로서 각하되어야 한다.
(92다25151, 2000다55171)

c5. [채권자→채무자 피보전채권 이행소 승소확정後 대위소송 제기] 이B 7회-2-1
1) 기판력
2) 당사자적격 흠결 **(보승3/발강확3피)**
기타의 효력 학설: 확정판결이 유력한 증거라는 증명효설, 실체법상 의존관계 있는 자에게 반사효가 미친다는 반사효설, 확정판결존부가 대위소송의 요건이 된다는 법률요건적 효력설
기존 判例 채권자가 채무자를 상대로 그 보전되는 청구권에 기한 이행청구의 소를 제기해 승소판결이 확정되면 제3채무자는 그 청구권의 존재를 다툴 수 없다. (반대 증거로 다투는 것을 불허하여 증명효로 설명이 어려웠음)
최근 判例 i) 청구권 발생원인이 되는 사실관계가 제3채무자에 대한 관계에서도 증명되었다고 볼 수 있다. ii) 그러나 청구권 취득이 강행법규에 위반되어 무효인 경우에는 iii) 위 확정판결에도 불구하고 iv) 대위소송의 제3채무자에 대한 관계에서는 v) 피보전채권이 존재하지 않는다고 보아야 한다.
검토: 증명효로 보고 최근 판례처럼 피보전채권을 제3자가 다툴 수 있도록 하는 것이 근본적인 해결책이다.

<기판력 객관적 범위>
[이유 중 판단] 이C 4회-2-2, 이B 4회-1-1, 이B 5회-4-2
소수설: 전소 판결과 후소 소송물이 의미관련을 가지면 기판력을 인정하는 의미관련론, 경제적 가치가 동일하면 기판력을 인정하는 경제적 가치동일성론, 당사자가 쟁점으로 다투어 법원이 판단하면 쟁점효를 인정하는 쟁점효이론.
통判: "기판력은 소송물에 한해 생기고 판결이유 중 판단에 관해 생기는 것은 아니다" 고 한다. 다만 확정된 관련 민사사건에서 인정된 사실은 유력한 증거자료가 되므로 합리적 이유설시 없이 배척할 수 없게 하여 재판통일을 이루면 족하다고 한다.
검토: 이유 중 판단에 기판력을 인정하면, 216조의 문언에 반하고 판결이유에 심리를 치중해 심리지연을 일으킬 수 있으므로

[동시이행항변] **(존수조반이)** 이B 6회-4-2
判例 i) 상환이행판결의 기판력은 "상환이행을 명한 반대채권의 존부나 그 수액에 기판력이 미치는 것이 아니다." ii) 다만 청구권에 동시이행 조건이 붙어 있다는 점에는 기판력이 발생하므로 그 확정판결 후에 "반대의무의 이행을 하지 않아도 이행할 의무가 있다는 주장은 기판력에 저촉된다."

[상계의 대상이 된 수동채권이 동시이행항변 채권]
判例 i) 이 경우 "상계주장에 대한 판단에 기판력이 발생하지 않는다. ii) 위와 같이 해석하지 않으면 동시이행항변에 행사된 채권에 관한 iii) 판결이유 중 판단에 기판력이 미치는 결과에 이르기 때문이다."

[상계항변 template] 이C4회-4-1, 이B 5회-3-2
(상계항변 인정한 경우) **(대수대자)**
상계하자고 대항한 액수에 한해, 즉 수동채권의 상계적상일까지의 원리금과 대등액에서 소멸하는 자동채권의 원리금 액수의 범위에서 발생한다.

(상계항변 배척한 경우) **(존수대자)**
반대채권의 존재를 인정했더라면 수동채권의 상계적상일까지의 원리금과 대등액에서 소멸하는 것으로 판단할 수 있었던 자동채권의 원리금 액수의 범위에서 발생한다.

(상계항변 일부만 인정한 경우) **(2존부부잔)**
判例 i) 2개 이상의 반대채권으로 상계했는데, ii) 한 반대채권의 존재를 인정해 수동채권 일부와 대등액에서 상계하는 판단을 하고 iii) 나머지 반대채권은 부존재한다고 배척한 경우, iv) 반대채권의 부존재의 기판력 발생범위는 v) 상계를 마친 후의 수동채권 잔액을 초과할 수 없다.

[진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구 가부]
(표법말진/편경) 이C 2회-1
긍정설: 등기를 말소하든 진정한 권리자에게 직접 이전등기를 이행하든 본질적 차이가 없다
부정설: 등기제도는 현재의 권리관계 뿐 아니라 물권변동 과정까지 여실히 반영해야 한다
判例 i) 자기 앞으로 소유권을 표상하는 등기가 되어 있었거나, ii) 법률에 의해 소유권을 취득한 자는 iii) 현재 등기명의인을 상대로 등기말소를 구하는 것 외에 iv) 진정한 등기명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기절차의 이행을 직접 구할 수 있다.
검토: 등기가 여러 사람에 걸쳐 경료된 경우, 최종 명의인만을 상대로 직접 이전등기를 구함이 원고편의와 소송경제에 도움

[진정명의회복 말소등기청구와 이전등기청구 소송물 동일여부]
(목법동/방편)
동일설: 법적성질 및 효과가 동일하므로
별개설: 청구취지가 다르므로 소송물은 다르나 신의칙상 후소가 허용되지 않는다.
判例 i) 양 청구는 모두 진정 소유자의 등기명의를 회복하려는 것으로서 실질적으로 목적이 동일하고 ii) 두 청구 모두 소유권에 기한 방해배제청구권으로서 법적 근거가 동일하므로 iii) 소송물은 실질상 동일하다.
검토: 양 소는 단지 방해배제의 형태를 당사자의 편의를 위해 말소청구와 이전등기청구 방식으로 한 것에 불과

[前특정부분 소이등 後지분 소이등] **(취/공차/분/전불구)**
이C 8회-1-3, 곽B 7회-1-2
判例 다수의견: 전소와 후소는 청구취지를 달리하여 소송물이 동일하다고 볼 수 없으므로, 전소의 기판력은 후소에 미칠 수 없다.
判例 다수의견의 별개의견: 지분에 관한 이전등기청구가 구체적으로 공격방어의 대상이 되거나 될 수 있었던 것이 아니므로 차단효를 인정할 수 없어 기판력이 미치지 않는다.
判例 소수의견: 특정부분에 관한 지분권이전등기청구는 특정부분에 관한 이전등기청구의 분량적 일부이므로, 특정부분에 관한 한 기판력에 저촉된다.
검토: 특정부분이든 공유지분이든 어느 한 쪽으로는 전부승소해야 할 원고가 자신이나 법원의 불찰로 일부라도 패소하면 구체적 타당성 해하므로 다수의견 타당

[前말소등기 後건물인도/부당이득] **(소전말기)** 이B 2회-4-2
判例 (위와 같은 사안에서) i) 전소 소송물은 말소등기청구권이고,

ii) 소유권은 전제가 되는 법률관계에 불과해 기판력이 미치지 않고, iii) 전소인 말소등기청구권에 대한 판단이 건물인도 등 청구의 소의 선결문제가 되거나 모순관계에 있다고 볼 수 없어 iv) 전소 기판력이 후소에 미친다고 할 수 없다. (2013다53939)

[시효중단을 위한 재소]
(시효중단 위한 재소 가부)
判例 다수의견: i) 확정판결에 의한 채권의 소멸시효기간인 10년의 경과가 임박한 경우에는 시효중단을 위한 소는 소의 이익이 있다. ii) 다른 시효중단사유인 압류·승인의 경우 이를 1회로 제한하지 않음에도 재판상 청구만 1회로 제한될 근거가 없다.
判例 소수의견: 10년마다 소제기해 판결 받으면 영구적으로 존속하는 채권이 되어 소멸시효제도를 둔 취지에 반한다.
검토: 확정판결에 의한 채무라도 채무자가 파산이나 회생제도를 통해 이로부터 벗어날 수 있는 이상 채권자에게 시효중단을 위한 재소를 허용하는 것이 균형에 맞다.
긍정할 경우 재소의 요건 (判例)
i) 시효중단을 위해 소제기, ii) 시효기간인 10년의 경과가 임박.
iii) 전소판결 확정 후 시효가 중단된 적이 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 후소가 판결확정 후 10년이 지나 제기되었어도 소의 이익이 없다고 각하해서는 안 되고 본안판단 해야 한다. (소멸시효 걸려서 기각될 것)

(전소 변론종결 전 사유 차단) **(저확요)**
判例 i) 신소판결이 전소 승소확정판결의 내용에 저촉돼서는 안 되므로, ii) 후소 법원은 그 확정된 권리를 주장할 수 있는 iii) 모든 요건이 구비돼 있는지에 관해 다시 심리할 수 없다.
(전소 변론종결 후 사유 제출) **(변소항인)**
判例 i) 전소 변론종결 후에 발생한 변제, 상계, 면제, 소멸시효완성 등 ii) 채권소멸사유는 후소의 심리대상이 된다. iii) 채무자는 후소에서 위 사유로 항변할 수 있고, iv) 심리 결과 그 주장이 인정되면 법원은 청구를 기각해야 한다.

[시효중단을 위한 새로운 방식의 확인소송]
判例 다수의견:
1) 새로운 방식의 확인소송 허용 근거 **(시권권잠시)**
i) 종래 대법원은 시효중단사유로서 재판상 청구에 관해 ii) 반드시 권리 자체의 이행청구나 확인청구로 제한하지 않을 뿐 아니라, iii) 권리자가 재판상 그 권리를 주장하여 iv) 권리 위에 잠자는 것이 아님을 표명한 것으로 볼 수 있는 때에는 v) 널리 시효중단사유로서 재판상 청구에 해당한다고 해석해왔다.
2) 종래 시효중단을 위한 이행소송의 문제점 **(이의조집적)**
i) 전소와 소송물이 동일한 이행소송이 제기되면서 ii) 채권자가 의도하지 않은 청구권 존부에 관한 실체 심리를 진행하고, iii) 채무자는 청구이의사유를 조기에 제출하도록 강요된다. iv) 채무자는 이중집행의 위험에 노출되며 v) 후소의 적법성이 10년의 경과가 임박했는지 여부라는 불명확한 기준에 의해 좌우된다.
3) 다수의견의 결론
재판상 청구가 있다는 점만 확인을 구하는 새로운 방식의 확인소송이 허용되고, 채권자는 보다 적합한 것을 선택해 제기할 수 있다

判例 소수의견: **(변집시)**
i) 전소 변론종결 후의 사정은 후소에서 심리되지만 이는 채무자로서 당연히 감수해야 한다. ii) 이중집행시 채무자는 청구이의의 소로 그 배제를 구할 수 있다. iii) 다수의견은 새로운 방식의 확인소송 제기 시기에 제한이 없다는 취지인듯 하나, 후소를 지나치게 빨리 제기하면 시효중단의 가치가 있을지 의문이다.

검토: 시효중단을 위한 재판상 청구가 있었다는 사실 자체는 채무자가 다툴 여지가 전혀 없고, 확인의 소 대상은 원칙적으로 법률관계이어야 하고 사실이 될 수 없다. 다수의견에 반대한다.

<기판력 시적범위>
[법적견해] **(새기다)** 이C 4회-2-1
判例 i) 변론종결 후에 발생한 새로운 사유란 새로운 사실관계를 말하는 것일 뿐 ii) 기존의 사실관계에 대한 새로운 법적 평가 또는 iii) 그와 같은 법적 평가가 담긴 다른 판결이 존재한다는 등의 사정은 포함되지 아니한다.

[토지거래허가구역 해제]
(변론종결 전 토지거래허가구역 해제 주장) **(토변알기)**
判例 i) 토지거래허가구역 해제로 매매계약이 확정적으로 유효하게 된 사정은 ii) 전소 변론종결 전에 존재하던 사유이므로 iii) 원고가 사정을 알지 못해 전소에서 주장하지 못했더라도 iv) 이를 후소에서 주장하는 것은 기판력에 반한다.
(변론종결 후 토지거래허가 받은 사실 주장) **(변거결)**
判例 i) 전소 변론종결 후에 토지거래허가를 받았으나, ii) 그 허가는 거래허가 대상에서 제외된 후에 이루어진 것이어서 iii) 결론에 영향을 미치는 사정변경이라고 할 수 없다.

[변론종결 후 변제하는 조건] **(피회잔회기)**
判例 i) 전소에서 피담보채무 변제로 양도담보권이 소멸하였음을 원인으로 한 ii) 이전등기 회복청구가 기각되었어도, iii) 장래 잔존 피담보채무 변제를 조건으로 iv) 이전등기 회복을 구하는 것은 v) 기판력에 저촉되지 않는다.

[변론종결 후 조건성취]
判例 i) 전소에서 정지조건 미성취를 이유로 청구가 기각되었다 하더라도 ii) 변론종결 후에 그 조건이 성취되었다면, iii) 동일한 청구에 대하여 다시 소를 제기할 수 있다.

[형성권, 한정승인 template]
(변론종결 전 발생한 형성권 행사 가부) **(상청상적/임집임/안하)**
이B 4회-1-3
실권설: 법적안정성 때문에 모든 형성권은 실권
비실권설: 형성권의 실체법상 행사기간 존중하여 모든 형성권 실권되지 않는다.
상계권·매수청구권 비실권설: 상계는 출혈적 방법이고 매수청구권은 건물의 효용유지를 위해 인정되므로, 다른 형성권은 실권하나 상계권과 매수청구권은 실권되지 않는다.
제한적실권설: 절차촉진과 신의칙을 근거로 상계권과 매수청구권도 전소에서 행사가능함을 알고도 불행사한 때는 실권
判例
1) 원칙
判例 해제사유가 전소 변론종결 전에 존재했다면 변론종결 후 해제의 의사표시를 했더라도 이는 기판력에 저촉된다
2) 예외
상계권判例: i) 변론종결 후 상계의사표시를 한 때에는 ii) 청구이의의 원인이 변론종결 후에 생긴 때에 해당하므로, iii) 변론종결 전에 상계적상을 알았는가와 무관하게 iv) 적법한 청구이의의 사유가 된다.
건매청判例: i) 임대인이 제기한 토지인도 및 건물철거 청구소송에

서 임차인의 패소판결이 확정되었다고 하더라도, ii) 판결에 의하여 건물철거가 집행되지 않은 이상, iii) 임차인은 매수청구권을 행사해 별소로 임대인에 대해 건물 매매대금의 지급을 구할 수 있다.
검토: 비실권설은 법적 안정성에 반하고, 실권설과 제한적실권설은 소구채권의 하자 문제가 아닌 상계항변·매수청구권을 전소에서 행사하도록 강제하여 부당

(변론종결 전 한정승인사실 주장 가부) 곽B 8회-3-2
학설 **(책무기/책변청)**
i) 책임범위에 관한 유보가 없는 판결이 확정된 경우에도 무한책임을 판시한 것으로 보고 책임범위에 대한 기판력을 인정한다.
ii) 그러므로 한정승인은 책임범위를 다투려는 전소 변론종결 전 사유이므로 청구이의사유가 될 수 없다.
判例 **(한책주기/변책한청)**
i) 전소에서 채무자가 한정승인 사실을 주장하지 않으면, 책임 범위는 현실적인 심판대상으로 등장하지 않아 주문에서는 물론 이유에서도 판단되지 않으므로 그에 관해 기판력이 미치지 않는다. (객관적 범위)
ii) 그러므로 채무자가 한정승인을 변론종결시까지 주장하지 않아 책임범위에 관한 유보가 없는 판결이 확정되었더라도 그 후 한정승인 사실을 내세워 청구이의의 소를 제기할 수 있다. (차단효 문제)
검토: 한정승인은 전소에서 확정된 채무와 무관한, 강제집행시에 비로소 문제되는 책임범위의 문제이므로 판례 타당.

[전소에서 한정승인 인정 후 후소에서 단순승인 주장]
(한상변단책/상채) 이B 8회-4-1
判例 전소에서 한정승인이 인정되어 상속재산 한도에서 지급을 명한 판결이 확정된 때에는 채권자가 변론종결 전 존재한 법정단순승인 등 한정승인과 양립할 수 없는 사실을 주장해 책임범위에 관한 유보 없는 판결을 구하는 소는 허용되지 않는다.
이 법리는 상속인의 한정승인 주장이 인정되어 상속재산 한도에서 지급을 명한 판결이 확정된 경우와 채권자 스스로 위와 같은 판결을 구해 판결이 확정된 경우 모두에 적용된다.

[임료상승 template] 이B 4회-4
(추가청구 가부) **(일명기차/명)**
시적한계설: 전소에서 제출할 수 없었던 사실관계는 변론종결 후의 사유로서 후소에서 차단되지 않는다.
별개소송물설: 전소 변론종결시까지 예견할 수 없었던 부당이득·손해는 별개 소송물로서 후소에 기판력이 작용하지 않는다.
判例 i) 전소에서 일부청구임을 명시하지는 아니하였지만 ii) 명시한 경우처럼 보아, iii) 전소판결의 기판력이 iv) 차액상당의 부당이득반환청구에는 미치지 않는다.
검토 (2002 개정법): 명시하지 않았음에도 명시한 것으로 보는 것은 지나친 의제라는 비판이 있었다. 개정법은 변경의 소를 인정해 입법적으로 기판력 저촉 문제를 해결했다.
(변경의 소 입법 전 판례임. 여전히 유지는 됨.
이것도 현저한 사정변경이 있어야 이렇게 명시적 의제해주는 것임)

(변경의 소 의의 및 성질) **(액/형/형)**
i) 정기금 판결 후 액수산정의 기초가 된 사정이 현저히 바뀐 경우 정기금 액수의 변경을 구하는 소. ii) 당사자의 형평성을 보장. iii) 소송법상 형성의 소

[확정판결 위법] **(뒤사종위)**
判例 i) 변경의 소는 판결 확정 뒤에 발생한 ii) 사정변경을 요건으로 하므로, iii) 단순히 종전 확정판결의 결론이 iv) 위법하다는 사정을 이유로 정기금액수를 바꾸어 달라고 할 수 없다.

[변종 뒤 승계인] **(소점채변)**
判例 i) 토지 소유자가 무단 점유자를 상대로 제기한 차임상당 부당이득반환 판결이 확정된 경우, ii) 소송물은 채권적청구권인 부당이득반환청구권이므로, iii) 변론종결 후에 토지소유권을 취득한 사람은 변론종결 뒤 승계인에 해당한다고 볼 수 없다.

[후유증 or 기대여명 연장 template] 이C 4회-1-1
(추가청구 가부) **(불새예포별/심)**
判例 i) 불법행위로 인한 적극적 손해의 배상을 명한 전소송 변론종결 후 ii) 새로운 적극적 손해가 발생한 경우 iii) 변론종결시 손해발생을 예견할 수 없었고 iv) 그 부분 청구를 포기했다고 볼 수 없는 등 특별한 사정이 있다면 v) 이는 전소 소송물과 별개의 소송물이므로 기판력에 저촉되지 않는다.
검토: 새로운 적극적 손해는 예견할 수 없었다면 전소의 심판대상이 되었다고 할 수 없으므로 별개소송물설 타당.

(부제소합의)
判例 "부제합의 당시 외상에 대한 합의를 경우, 당시에 전혀 예상할 수 없었던 외상후신경증으로 인한 손해배상청구소송까지도 제기하지 않기로 하는 취지로 합의한 것이라고 볼 수 없다." 즉 추가청구는 부제소합의에 반하여 소의 이익이 없다고 할 수 없다.

(변경의 소 가부)
소송물동일설: 변경의 소 소송물은 전소 소송물과 동일하므로, 확대손해는 별개소송물이어서 변경의 소 대상이 아니다.
소송물별개설: 변경의 소 소송물은 확정판결의 내용을 변경해 달라는 변경청구권으로서 전소 소송물과 다르고 확대손해의 경우에도 변경의 소 허용
검토: 전소와 후소의 소송물이 동일한 경우에 기판력 저촉의 문제를 해결하려는 변경의 소의 입법취지

[화해권고결정 + 기대여명 단축 template]
(작용국면 모순관계) **(일재법기)** 이C 4회-1-2
判例 i) 피해자가 손해배상액 산정의 기초로 인정된 기대여명보다 일찍 사망해도 ii) 그 판결이 재심 등으로 취소되지 않는 한, iii) 배상금 중 일부를 법률상 원인 없는 이득이라 하여 반환을 구하는 것은 iv) 기판력에 저촉된다.

<판결의 편취>
{허위주소송달 편취판결 template}
(편취판결의 효력)
무효설: 피고의 재판받을 권리가 실질적으로 보장된 것이 아니므로
유효설: 법적안정성 위해 판결은 위법하지만 유효
判例 허위주소 판결편취사건에서 "판결이 형식적으로 존재하는 이상 편취판결도 당연무효의 판결이 아니다"
검토: 451조1항이 판결이 유효함을 전제로 재심사유로 규정

(소송법상 구제책)
항소설: 판결정본 송달은 무효이고 항소기간 진행하지 않아 항소제기
추후보완·재심설: 판결정본 송달 유효이고 항소기간 진행하므로 항소기간 도과하면 추후보완항소 또는 재심 제기

(공시송달) **(공허송항)**
判例 판결정본이 공시송달된 경우 피고 주소지를 허위로 하여 소가 제기된 경우라도 송달은 유효하고 그 때부터 항소기간이 도과하면 판결은 확정된다.
검토: 공시송달요건에 흠이 있어도 재판장의 명령인 재판형식으로 이루어지기 때문에 공시송달은 유효하다.

(허위주소송달) **(허송송항)**
判例 판결정본이 상대방의 허위주소로 보내져 다른 사람이 수령했으니 송달은 무효이고 상대방은 송달을 받지 않은 상태에 있는 것으로서 항소기간은 진행을 개시하지 않는다.
(참칭대표자) **(참자송항)**
判例 피고의 대표자를 참칭대표자로 적어 소장부본 등을 송달하고 자백간주에 의한 판결을 받아낸 경우 "송달은 유효하기 때문에 항소기간이 진행하므로 재심사유가 된다"고 한다.
(허위주소송달이나 참칭대표자)
검토: 항소설에 의하면 언제든 항소할 수 있어 불안정한 법률상태가 계속되므로 원칙적으로 추후보완·재심설이 타당. 다만 허위주소송달의 경우 송달 자체가 없었다고 볼 수 있으므로 항소설이 타당.

(실체법상 구제책)
재심필요설: 편취판결도 기판력이 발생하므로 재심에 의해 판결을 취소해야만 말소등기청구, 손해배상청구 등 가능
재심불요설: 편취판결을 기판력으로 보호하는 것은 자연적 정의에 반하므로 재심 없이 위 청구가 가능
判例
1) 말소등기청구의 경우 - 필요설 **(재기/기항별)**
判例 "판결이 재심의 소 등으로 취소되지 않는 한 그 판결의 기판력에 저촉되는 주장을 할 수 없다"고 한다. 다만, 허위주소송달의 경우 "사위판결에 기판력이 부정되므로 사위판결에 대해 항소하지 않고 별소인 말소등기청구를 할 수 있다"
2) 손해배상청구의 경우 - 원칙적 필요설 **(기재/절재효정)**
判例 i) 기판력을 인정한 취지나 재심이 원칙인 점에 비춰 불법행위의 성립을 쉽게 인정해서는 안 된다. ii) 편취판결의 강제집행이 불법행위로 되는 것은 절차적 기본권이 근본적으로 침해되었거나 판결에 재심사유가 존재하는 등 확정판결의 효력을 존중하면 정의에 반함이 명백한 경우로 한정된다.
검토: 법적 안정성 관점에서 재심필요설이 타당.

(부당집행에 대한 구제책 - 청구이의의 소) **(부변집/의집/외)**
긍정설: 구체적 타당성 강조하여 편취판결을 집행하는 것은 부당집행이므로
부정설: 법적안정성 강조하여 편취판결은 변론종결 전 발생한 사유이므로
判例 i) 청구이의의 소는 부당한 집행을 막으려는 것이므로 ii) 판결에 의해 확정된 청구가 변론종결 후에 변경·소멸된 경우 뿐 아니라 iii) 판결을 집행하는 것 자체가 불법인 경우에도 허용함이 상당하다.
다만, 이전등기청구소송처럼 "i) 의사의 진술을 구하는 소송에서 인용판결이 확정되면, ii) 집행기관에 의한 집행절차가 필요 없으므로 청구이의의 소는 허용될 수 없다."
검토: 불법은 판결에 의해 강제집행에 착수함으로써 외부에 나타나 비로소 이의원인이 되므로 긍정설이 타당. 다만 이전등기청구소송 특성상 예외

{공시송달 편취판결 + 재심보충성 template}
(보충성 위반 여부) **(상독추재)** 이B 8회-3-1, 곽B 8회-1-3
判例 i) 보충성은 상소할 수 있는 시기에 재심사유를 안 경우는 상소로 이를 주장하게 하려는 취지이고, ii) 추완상소와 재심은 독립된 별개의 제도이므로 iii) 추완상소를 택한 경우는 추완상소기간 내에, iv) 재심을 택한 경우는 재심기간 내에 제기할 수 있다.

제5편【병합소송】

제1장 복수청구소송 4개

[재심의 소에 통상의 민사청구 병합] 이A 8회-4-3
判例 편취판결 사건에서, "등기말소청구는 별소로 제기해야 하고 재심의 소에 병합해 제기할 수 없다"고 하여 통상의 민사청구를 각하했다.
학설: 재심의 소가 상급심 판결에 대한 재심인 경우를 제외하고, 소송경제를 위해 병합을 인정
검토: 통상소송과 재심소송은 동종절차가 아니므로 병합 부정

<청구의 병합 (객관적 병합)>
I. 단순병합
{단순병합 기본 template}
[관련성 없는 청구를 선택적·예비적병합 청구] **(논선보형)**
이C 6회-2-1
判例 i) 논리적으로 관련성이 없어 단순병합으로 구해야 할 수개의 청구를 ii) 선택적병합으로 청구하는 것은 부적법하다. iii) 법원은 단순병합청구로 보정하게 하는 조치를 취해야 하며, iv) 이러한 조치 없이 판결했어도 병합 형태가 선택적 병합 관계로 바뀔 수는 없다.

[관련적 단순병합 일부판결 적법여부] 이B 7회-4-1
학설: 소수설로서 일부판결이 부적법하다는 견해가 있지만, 통설은 일부판결이 부적당하지만 적법하다고 한다.
判例 원금청구부분만 판단하고 지연손해금청구 부분에 대하여는 재판의 탈루가 있었고, 이 부분 소송은 원심에 계속 중이다.
검토: 관련적 병합이라도 단순병합인만큼 재판의 누락을 위법하다고 할 수 없다.

(단순병합 상소불가분의 원칙 적용 여부)
이C 5회-2-1, 이B 8회-2-1
소수설: 합일확정 필요가 없으므로 상소하지 않은 부분은 분리확정
통설判例: 수개의 청구를 1개의 판결로 재판한 경우 한 청구에 관한 재판에 대해 항소하면 재판 전부에 대해 이심의 효력이 있다
검토: 부대항소의 기회를 넓게 보장하는 측면

(불복하지 않은 부분의 확정시기) **(변직)**
이C 5회-2-1, 이B 7회-4-2
통설: 상대방의 부대상소가 허용될 수 없는 시기에 이르면 불복 되지 않은 부분은 확정되므로, 항소심에서는 항소심 변론종결시, 상고심에서는 상고이유서제출시기의 도과시 확정
判例 항소심의 경우 항소심 판결선고시, 상고심의 경우 상고심 판결선고시에 확정된다고 한다.
검토: 항소심 변론종결 후에도 다시 변론재개될 수 있고, 상고심은 직권조사사항을 당사자의 주장 없이도 판단해야 하므로 판례 타당

{대상청구 template}
(집행불능대비 대상청구 병합형태) **(본현이집단)**
判例 i) 본래 급부청구에 이를 대신할 전보배상을 부가하여 대상청구를 병합한 경우, ii) 대상청구는 본래 급부청구권이 현존함을 전제로 iii) 이것이 판결확정 전에 이행불능되거나 iv) 판결확정 후 집

행불능이 될 경우에 대비해 전보배상을 구하는 경우로서 v) 현재 급부청구와 장래 급부청구의 단순병합으로 허용된다.
검토: 순서를 붙였으므로 부진정예비적병합이라는 견해가 있으나, 모두 인용될 수 있다는 점에서 단순병합으로 설명하면 충분하다.

(대상청구 심판방법) **(예인생)**
判例 i) 대상청구를 본래의 급부청구에 예비적으로 병합한 경우에도 ii) 본래의 급부청구가 인용된다는 이유만으로 iii) 예비적 청구에 대한 판단을 생략할 수는 없다.

II. 선택적병합
{선택적병합 판단누락 template}
[일부인용시 다른 청구 판단요부] **(하불일판/경인)**
학설: 선택적병합에서 여러 청구를 중첩적으로 행사할 수는 없으므로, 한 청구를 일부인용하면서 다른 청구를 판단하면 선택적 병합의 본래 의미에 반한다.
判例 i) 선택적 병합은 여러 개 청구가 하나의 소송절차에 ii) 불가분적으로 결합되어 있기 때문에, iii) 한 청구에 대해 일부만 인용하고 iv) 다른 선택적 청구에 대해 판단을 하지 않은 것은 위법하다.
검토: 경합하는 권리마다 인용범위가 다를 수 있으므로 한 청구에서 인용되지 않은 범위에서 다른 청구를 인용하는 것이 가능

(일부판결 가부) **(선항전판탈/하불)** 이B 5회-2-1
판단누락설: 판결의 모순방지를 위해 일부판결이 허용되지 않는 바, 판단누락의 일종으로 보아 상소·재심의 대상
재판누락설: 각 청구는 별개이고 별소가 가능한 만큼 일부판결이 허용되는 바 재판누락시 추가판결 대상
判例 i) 선택적 청구 중 하나만 판단해 기각하고 나머지 청구를 판단하지 않은 것은 위법하고, ii) 원고가 위법한 1심판결에 대해 항소한 이상 iii) 선택적 청구 전부가 항소심으로 이심되며, iv) 판단되지 않은 부분이 재판의 탈루로서 1심에 있는 것은 아니다.
검토: 수개의 청구가 하나의 소송절차에 불가분적으로 결합되어 있기 때문에 일부판결과 추가판결 허용하면 판결이 모순될 수 있으므로 판단누락설 타당.

{선택적병합 청구인용 template} 이C 7회-3-1
(심판의 범위 및 순서) **(선인심/불순)**
우선심판설: 복수의 집행권원이 병존한다는 오해를 막기 위해 1심이 인용한 청구를 먼저 심판한다.
判例 (선택심판설) i) 1심부터 선택적병합되고 한 청구에 대한 인용판결에 대해 피고가 항소한 경우 (항소심에서 선택적병합된 경우도) ii) 항소심은 1심에서 인용된 청구를 먼저 심리해 판단할 필요는 없고, iii) 1심에서 심판되지 않은 청구를 임의로 선택해 심판할 수 있다.
검토: 1심에서 판단되지 않은 청구는 항소심이 사실상 1심으로 심판한다고 볼 수 있으므로 불이익변경금지원칙에 반하지 않는다. 순서가 없는 선택적병합의 특성에 비춰 선택심판설이 타당하다.

(항소심판결) **(결취새/소414)**
항소기각설: 결론이 1심판결의 주문과 동일하다는 점에서 414조 2항에 따라 항소기각
判例 (항소인용설) 1심에서 심판되지 않은 청구를 인용할 경우 i) 그 결론이 1심판결 주문과 동일한 경우에도 ii) 1심판결을 취소한다음 iii) 새로이 청구를 인용하는 주문을 선고해야 한다.
검토: 선택적병합에서 소송물이 다른바, 어느 권리가 존재하는지를 분명하게 밝힌다는 의미에서 항소인용설 타당. 414조2항은 소송물이 동일한 경우에만 적용.

(선결: 항소심 심판대상
순위를 붙일 합리적 필요성이 인정되면 교환적 변경이므로 1심에서 판단되지 않은 청구가 심판대상이 될 수 있고, 합리적 필요성이 없다면 선인심/불순에 따라 심판대상이 될 수 있다.)

(순위를 붙인 경우) **(심주인예/결항새)**
判例 선택적 청구 중 한 청구가 인용된 후, i) 항소심에서 원고가 1심에서 심판되지 않은 청구를 주위적으로, ii) 1심에서 인용된 청구를 예비적 청구로 구한 경우, iii) 주위적 청구가 이유 있으면 결론이 1심판결 주문과 동일해도 iv) 항소기각해서는 안되고 v) 새로이 청구를 인용하는 주문을 선고해야 한다.

III. 예비적병합
[양적·질적 감축된 예비적 청구] **(양동감흡)**
判例 i) 예비적 청구는 주위적 청구와 양립할 수 없는 관계여야 하므로, ii) 주위적 청구와 동일한 목적물에 관해 동일한 청구원인을 내용으로 하면서 iii) 주위적 청구를 양적·질적으로 감축해 하는 청구는 iv) 주위적 청구에 흡수될 뿐 예비적 청구라고 할 수 없다.

{판단누락 template}
(일부판결 가부) **(주배예/상누예판탈/하불)**
判例 i) 주위적 청구를 배척하면서 예비적 청구에 대해 판단하지 않은 일부판결은 허용되지 않으며, ii) 판결에 대한 상소가 제기되면 iii) 판단이 누락된 예비적 청구도 상소심으로 이심되고, iv) 판단되지 않은 부분이 재판의 탈루로서 원심에 계속 중이라고 볼 것은 아니다.
(별소제기 가부 - 권리보호자격 여부) **(상오별권/분제)**
判例 당사자가 상소할 수 있었음에도 하지 않았다면, 판결은 오류가 있는 그대로 확정되어, 그 후 그 분쟁을 별소로 다시 제기하는 것은 권리보호를 위한 적법요건을 갖추지 못해 허용될 수 없다.
학설: 제소장애사유는 '제소시'에 간단한 구제절차가 있을 때를 의미하므로 판례 부당하다
검토: 분쟁의 1회적 해결을 위해 제소전에 간단한 구제절차 이용할 수 있었음에도 이용하지 않았다는 사정은 제소장애사유로 볼 것이다.

{예비적병합 1차 청구인용 template}
(심판의 범위) **(주심예/주배예/불)**
判例 i) 주위적 청구를 인용한 판결은 전부판결로서 이 판결에 대해 피고가 항소하면 ii) 1심에서 심판받지 않은 예비적 청구도 이심되고 iii) 항소심이 주위적 청구를 배척할 때는 예비적 청구에 관해 심판을 해야 한다.
검토: 1심에서 판단되지 않은 청구는 항소심이 사실상 1심으로 심판한다고 볼 수 있으므로 불이익변경금지원칙에 반하지 않는다.

{1차기각/2차인용에 대한 피고항소 template}
(심판의 범위) **(1이부심/방)**
통설: 원고가 1심판결에 대해 불복하지 않은 것은 주위적 청구에 대한 판단을 요구하지 않겠다는 의사이므로 항소심 심판대상은 예비적 청구에 국한
소수설: 판결의 모순방지를 위해 원고의 부대항소를 의제한 후 주위적 청구도 심판한다.
判例 i) 제1심에서 주위적 청구를 기각하고 예비적 청구를 인용한 판결에 대해 피고만 항소한 경우 ii) 이심의 효력은 사건 전체에 미치더라도 iii) 원고로부터 부대항소가 없는 한 iv) 항소심의 심판대상은 예비적 청구에 국한된다.
검토: 원고가 불복하지 않은 주위적청구를 인용하면 피고의 방어권침해

(심판대상이 되지 아니한 주위적 청구에 대한 인낙가부)
(1이인확종)
判例 i) 제1심에서 주위적 청구를 기각하고 예비적 청구를 인용하는 판결에 대해 피고만 항소해도, ii) 이심의 효력은 사건 전부에 미치므로, iii) 피고가 주위적 청구를 인낙하면 iv) 그 조서는 확정판결과 동일한 효력이 있고, v) 따라서 인낙으로 인해 예비적 청구는 심판할 필요가 없어 사건이 종결된다.
학설: 주위적 청구가 이심되더라도 현실적인 심판대상이 되지 않는 이상 인낙이 불가능하다는 견해
검토: 인낙은 판결이 선고되더라도 판결이 확정될 때까지 할 수 있다는 것이 통설이다. 주위적 청구가 확정되지 않고 이심되어 있는 이상 인낙이 가능하다.

[예비적 청구에 대한 청구인낙 가부] **(주예피효)** 이C 3회-4-1
判例 i) 주위적 청구의 당부를 먼저 판단하여 그 이유가 없을 때만 예비적 청구에 관하여 심리판단할 수 있고, ii) 예비적 청구만을 분리하여 심리하거나 일부판결을 할 수 없으며, iii) 피고로서도 예비적 청구만 인낙을 할 수 없다. iv) 인낙한 취지가 조서에 기재되어도 인낙의 효력이 없다.

{부진정예비적병합 - 대여금/불법손배 template}
(부진정예비적병합 허용여부) 이C 6회-2-2, 이C 7회-3-2
긍정설: 순서를 중시하는 당사자의 의사를 존중하여 예비적 병합처럼 심판
부정설: 병합의 성질에 따라 병합의 종류가 정해지므로 단순 또는 선택적 병합으로 취급
判例 양립할 수 있는 수 개의 청구라도 당사자가 심판순위를 붙여 청구할 합리적 필요성이 있는 경우에는 당사자가 붙인 순위에 따라서 심리해야 한다.
검토: 심판대상에 대한 원고의 처분권을 존중하기 위해

(청구병합의 형태) **(형당성실/계불)** 이C 7회-3-2
선택적병합설: 순위를 붙여 청구할 필요성이 없으므로 선택적병합
부진정예비적병합설: 불법행위채권은 상계제한, 과실상계 등에서 다른 채권과 차이가 있어 순위를 붙여 청구할 합리적 필요가 있으므로 부진정예비적병합
判例 i) 병합의 형태가 선택적병합인지 예비적병합인지 여부는 ii) 당사자의 의사가 아닌 iii) 병합청구의 성질을 기준으로 판단해야 하므로 iv) 실질적으로 선택적병합 관계에 있다.
검토: 계약에 기한 청구권과 불법행위에 기한 청구권의 성질 차이만으로 순위를 붙일 합리적 필요성을 인정하기 어렵다.

(심판의 범위) **(실1피항/동구)** 이C 7회-3-2
학설: 부진정예비적병합으로 보되 부대항소를 석명해 주위적 청구를 판단해야 한다는 견해
判例 i) 실질적으로 선택적 병합 관계에 있는 두 청구에 관해 순위를 붙여 청구했고, ii) 제1심법원이 주위적 청구를 기각하고, 예비적 청구만을 인용하는 판결을 선고하여 iii) 피고만이 항소한 경우에도, iv) 항소심으로서는 두 청구 모두를 심판대상으로 해야 한다.
검토: 주위적 청구는 판단하지 못한다면 원고가 동일한 목적으로 결합한 위 권리를 모두 실현하지 못해 구체적 타당성 해한다. (부대항소의 석명은 적극적 석명으로서 가능할지 의문)

{부진정예비적병합 일부인용 template}
(주위적 청구 일부인용시 예비적 청구 판단요부) **(주예의)**
判例 주위적 청구에서 인용되지 않은 수액 범위에서 예비적 청구에 대해서도 판단해주기를 바라는 취지로 결합시켜 제소할 수도 있다. 이는 원고 의사해석에 달린 문제이다.

(법원의 석명의무) **(주예주예석)**
判例 주위적 청구의 일부를 기각하고 예비적 청구보다 적은 금액만을 인용할 경우에는, 주위적 청구에서 인용되지 않은 수액 범위에서 예비적 청구도 판단해주기를 바라는 취지인지 석명해 그 결과에 따라 판단해야 한다.

<소변경>
[교환적변경 후 항소취하, 항소각하] **(교심1대)** 곽6회-1-1
判例 i) 항소심에서 교환적 변경되면 1심판결은 소취하로 실효되고, ii) 항소심 심판대상은 새로운 소송으로 바뀌어 iii) 항소심이 사실상 1심으로 재판하므로, iv) 피고가 항소취하해도 그 대상이 없어 효력이 없다.
判例 i) 항소심에서 교환적 변경되면 1심판결은 실효되고 ii) 항소심 심판대상은 새로운 청구로 바뀌어 iii) 항소심은 1심판결이 있음을 전제로 한 항소각하 판결을 할 수 없다.

[교환적 변경 후 구청구 심판] **(소처종)** 곽6회-1-1
判例 i) 취하되어 소송계속이 소멸된 구청구에 대해 심판한 것으로써 ii) 처분권주의를 위반한 것이므로 iii) 이를 취소하고 구청구에 대해 소송종료선언해야 한다. (신청구는 추가판결)

[교환적 변경과 자백] **(교대/배묵원예)** 곽5회-2-2, 이B 7회-1-2
判例 i) 원고가 교환적 변경함으로써 종전 주장사실 철회시, ii) 이미 성립된 피고의 자백도 그 대상이 없어짐으로써 소멸된다. iii) 그 후 피고가 자백내용과 배치되는 주장을 함으로써 iv) 그 진술을 묵시적 철회하면, v) 원고가 이를 다시 원용할 수 없고, vi) 원래 주장을 예비적 청구원인으로 추가해도 자백효력이 부활하지 않는다.

[소변경 형태 불명확]
(신청구가 부적법한 경우 소변경 해석) **(명부교종)**
判例 i) 구청구를 취하한다는 명백한 의사표시 없이 신청구를 한 경우에 ii) 신청구가 부적법하여 법원의 판단을 받을 수 없는 경우까지도 iii) 구청구가 취하되는 교환적변경이라고 볼 수 없다. iv) 청구변경을 하는 당사자는 소송을 종료시킬 의도로 청구를 변경했다고는 볼 수 없기 때문이다.

{3억 소제기, 2억으로 감축, 2억2천 판결 template}
(청구취지의 감축이 소의 일부취하인지여부)
다수설: 원고에게 유리하게 해석해야 하므로 일부취하
소수설: 감축부분에 관해 일부판결할 수 있을 정도로 특정성이 있는 경우 일부취하로, 특정성이 없으면 일부포기로 (단순암기)
判例 소송상 청구금액을 감축한다는 것은 소의 일부취하를 뜻하는 것이니 취하된 부분의 청구를 포기했다고는 볼 수 없다.
검토: 일부포기로 보면 감액 부분을 후소로 청구했을 때 기판력에 의해 배척되나, 일부취하로 보면 재소가 가능한바 일부취하로

(취하서 제출시 법원의 처리) **(266송확결종)** 이C4회-3-1
判例 i) 법원은 266조4항에 따라 ii) 소취하서 등본을 상대방에게 송달한 다음 상대방 동의 여부에 따라 iii) 심판범위를 확정해 재판해야 하고, iv) 상대방의 동의 여부가 결정되지 않은 상태에서 v) 종전 청구에 대해 재판해서는 안 된다.

{항소심에서 교환적변경 後 추가적변경 template}

(부대항소 의의 및 성질) **(피자/경)**
i) 피항소인이 개시된 항소심절차에 편승하여 ii) 자기에게 유리하게 항소심 심판의 범위를 확장시키는 신청 / iii) 소송경제 도모

(교환적 변경 법적성질) **(신결심)**
독자제도설: 교환적 변경은 신청구에 대해 재판을 받으려는 것이므로 소송을 종료시키는 소취하와 다르다.
判例 (결합설) 교환적 변경은 신청구의 추가적병합과 구청구 취하의 결합형태이다.
검토: 교환적 변경의 경우 구청구를 더 이상 심리하지 않으므로 구청구 취하의 성질이 있다.

(교환적 변경 후 재소금지 저촉여부) **(농재/본구종)**
독자제도설: 교환적 변경 후 다시 구청구로 변경해도 법원 농락의 도가 없으므로 재소금지원칙에 저촉되지 않는다.
判例 (결합설) 본안판결 후 구청구를 신청구로 교환적 변경 한 다음 iii) 다시 구청구를 추가한 경우 (또는 교환적 변경) iv) 종국판결 후 소를 취하했다가 동일한 소를 제기한 경우에 해당하여 부적법하다.
검토: 교환적 변경에 구청구 취하의 성질이 있는 이상 재소금지원칙 적용된다.

{항소심에서 지분양도·소취하 後 추가적변경 template}
이C 3회-3-1
(변론종결 뒤 승계인 재소금지) **(취양권/권기)**
특정승계인포함설: 특정승계인도 당사자 동일의 요건을 충족하나 특정승계인에게 소취하의 책임이 있는 경우를 제외하고 새로운 권리보호이익이 생겼다고 한다.
불포함설: 타인이 한 소취하 효과까지 특정승계인이 받으면 가혹
判例 i) 소취하한 자는 변론종결 뒤 특정승계인을 포함하나 ii) 전소취하 후 토지를 양수한 원고는 소유권을 침해하고 있는 피고에게 iii) 그 배제를 구할 새로운 권리보호이익이 있다.
검토: 포함설에 의하더라도 새로운 권리보호이익이 있으면 재소가 가능하므로, 기판력승계인처럼 재소금지에서도 일반승계인과 특정승계인을 구별하지 않는 포함설이 타당.

(사안) **(지농취권권)**
判例 i) 항소심 계속 중 지분 양도에 따라 소취하 및 재소한 경우 ii) 법원이 농락당한 것이라 할 수 없고, iii) 지분양수인에게 소취하에 대한 책임이 있다고 할 수 없으며, iv) 양수인은 자기 권리를 보호하기 위해 양수지분에 기해 다시 소를 제기할 필요도 있어 v) 권리보호의 이익을 달리하여 재소금지의 원칙에 위배되지 않는다.

<반소>
[반소이익] **(이채실)**
判例 i) 어떤 채권에 기한 이행의 소에 대해 ii) 동일 채권에 관한 채무부존재확인의 반소를 제기하는 것은 iii) 그 내용이 실질적으로 본소 청구기각을 구하는 데 그치므로 부적법하다.

[채무부존재확인 본소와 이행청구의 반소] **(소상소이/반본)**
(채무부존재확인의 소 확인의 이익 소멸여부)
소의 이익 존부 판정 시기는 원칙적으로 사실심 변론종결시이므로 채무부존재확인의 소는 확인의 이익이 없다는 견해
원고가 본소를 취하한 경우 피고가 일방적으로 반소를 취하함으로써 원고가 당초 추구한 기판력을 취득할 수 없는 사태가 발생하므로 확인의 이익이 있다는 견해
判例 i) 소송요건을 구비하여 적법하게 제기된 본소가 ii) 그 후 상대방이 제기한 반소로 인해 iii) 소송요건에 흠결이 생겨 부적법하게 되는 것은 아니므로, iv) 이행을 구하는 반소를 제기한 사정만으로 본소가 확인의 이익이 소멸한다고 볼 수 없다.
검토: 반소청구기각판결의 기판력은 원칙적으로 본소 원고가 채무부존재확인소송에 의해 달성하려는 목적과 동일하다.
(결국 채무부존재확인의 소는 확인의 이익 소멸로 각하해야 한다.)
(대법원과 반대로 검토)

[제3자 반소] **(원3반/필68/규경)**
문제점: 제3자가 반소원고 또는 반소피고 되는 것 허용할지
긍정설: 소송경제
부정설: 필수적 공동소송관계에 있는 제3자를 68조에 의해 '원고'가 추가할 수 있으므로 피고가 반소로 추가하는 것은 해석론의 한계를 넘는다.
判例 (제한적 긍정설) i) 피고가 원고 이외의 제3자를 추가하여 반소피고로 하는 반소는 원칙적으로 허용되지 않고, ii) 다만 피고가 제기하려는 반소가 필수적 공동소송이 될 때에는 68조의 필수적 공동소송인 추가의 요건을 갖추면 허용될 수 있다.
검토: 명문의 규정이 없는 이상 원칙적으로 부정하되, 소송경제를 위해 필수적 공동소송관계에 있는 경우에만 허용

[본소 각하 후 반소 취하시 원고 동의 요부] **(271반반강의)**
동의불요설: 반소는 본소에 의해 유발된 것이므로 본소가 각하된 때에도 원고의 동의 없이 취하 가능
判例 (동의필요설) i) 271조는 원고가 반소제기를 유발한 본소는 스스로 취하해놓고 ii) 반소만의 유지를 상대방에게 강요함은 공평치 못하다는 이유에서 나온 규정이므로, iii) 본소가 원고 의사와 관계없이 각하된 경우까지 유추적용 할 수 없다.
검토: 271조는 원고가 본소를 스스로 취하한 경우만 규정했으므로 (단순반소에 관한 논의임)

[점유권에 기한 본소에 소유권에 기한 반소]
(반소 적법여부) **(208점본/청점본/별)**
문제점: 민법 208조 2항은 점유권에 기한 소는 본권에 관한 이유로 재판하지 못한다고 규정한다
반소적법설: 민법 208조 2항이 본권을 방어방법으로 할 수 없다는 것만 규정하고 본권에 기한 '반소'제기를 금지하지 않고 있다.
반소부적법설: 본권에 기한 반소를 인정하면 점유권자는 점유의 회복을 할 수 없다.
判例 i) 점유권에 기한 소는 본권에 관한 이유로 재판하지 못하므로 (민법 208조) ii) 점유권에 기한 본소에 대해 iii) 본권에 기한 예비적 반소를 제기하고 iv) 양 청구가 모두 이유 있는 경우, v) 점유권에 기한 본소와 본권에 기한 예비적 반소를 모두 인용해야 한다.
검토: 본권에 기한 별소가 당연히 허용되므로 반소도 적법

(집행문제) **(본점본반/실정장청)**
1) 본소 집행의 원칙적 허용
i) 본소와 예비적 반소가 모두 인용되어 확정되면, ii) 점유자가 집행문을 부여받아 강제집행으로 점유를 회복할 수 있다. iii) 본권자는 본소 집행 후 집행문을 부여받아 iv) 반소 확정판결에 따른 강제집행으로 점유를 회복할 수 있다.
2) 본소 집행의 예외적 불허
i) 다만 점유자의 점유회수의 집행이 아무런 실익이 없거나 ii) 명백히 정의에 반할 경우 iii) 또는 점유자가 본소판결을 장기간 강제집행하지 않는 등 특별한 사정이 있다면 iv) 본권자는 청구이의의 소로 점유권에 기한 집행을 저지할 수 있다.

[반소 재판누락] **(이주재/주재1상)** 곽콜 2회-1-2
判例 i) 판결이유에 청구가 이유 없다고 설시되었더라도 ii) 주문에 그 설시가 없는 경우 iii) 재판누락에 해당한다.
i) 1심이 반소에 관해 주문에서 판단하지 않아 ii) 반소에 관한 재판을 누락한 경우 iii) 이 부분 청구는 여전히 1심에 계속 중이어서 iv) 적법한 상소의 대상이 될 수 없다.

{항소심 반소 template}
[본소청구와 관련성] **(취원대발주공)**
i) 양 소의 청구취지가 동일한 법률관계 형성을 목적으로 하거나 ii) 청구원인이 동일 iii) 대상이나 발생원인의 주된 부분이 공통

[본소방어방법과 관련성] **(대발사법공/현허)**
i) 본소의 항변과 대상이나 발생원인에서 사실상 또는 법률상 공통. ii) 방어방법이 반소 제기시 현실적으로 제출되고, 법률상 허용되어야 한다.

{예비적 반소 template}
(심판의 범위) **(예본예/무불)** 이C 8회-4-2, 곽B 8회-4-1
피고가 불복하지 않은 예비적 반소를 심판대상으로 하는 것은 원고에게 불이익하므로 심판대상이 아니라는 견해
본소청구가 인용될 때 예비적 반소를 심판하는 것은 예비적 반소의 성질상 당연하다는 견해
判例 i) 심판대상이 될 수 없는 예비적 반소에 대해 1심이 판단했더라도 효력이 없으므로 ii) 2심으로서는 본소청구를 인용한 이상 iii) 예비적 반소를 심판대상으로 삼아 판단했어야 한다.
검토: 예비적 반소에 대한 판단은 무효로서 항소 또는 부대항소의 대상이 될 수 없어서 상급심에서 판단해도 불이익변경의 문제가 없다.
<중간확인의 소>

제2장 다수당사자소송 4개
<공동소송>
I. 통상공동소송
[매매예약완결권을 원인으로 한 가등기에 기한 본등기청구]
(공지매/동의지피)
1) 공동행사 여부를 정한 경우
判例 수인의 채권자가 공동으로 매매예약완결권을 갖는 관계인지 아니면 각자 지분별로 별개의 독립적인 매매예약완결권을 갖는 관계인지는 매매예약의 내용에 따라야 한다.
2) 공동행사 여부를 정하지 않은 경우
判例 공동으로 예약한 동기, 공동행사 의사의 유무, 지분권 표시 여부 및 지분비율과 피담보채권 비율의 일치 여부 등을 종합해 판단한다.

[독립의 원칙 수정여부] **(66변행/66석)**
주장공통원칙인정설: 1인의 공동소송인이 한 유리한 주장은 다른 공동소송인의 원용이 없어도 그에게 효력이 있다.
증거공통원칙인정설: 1인의 공동소송인이 제출한 유리한 증거는 다른 공동소송인의 원용이 없어도 그에게 사실인정의 자료로 할 수 있다.
判例 "66조 독립원칙과 변론주의 소송구조에 비추어 볼 때, 통상공동소송에서 주장공통원칙은 적용되지 아니한다."고 하고, "통상공동소송에서 입증행위가 행위자를 구속할 뿐 다른 당사자에게 영향을 주지 않는 것이 원칙"이라고 하여 증거공통원칙을 부정한다.
검토: 66조가 명문으로 독립원칙을 규정한 이상 이를 수정할 수 없다. 판결의 모순 문제는 법원이 석명권을 행사하여 해결.

II. 필수적공동소송
[소수지분권자 공유물 독점점유 다른 소수지분권자 상대 인도청구]
(이보265지/공독/방)
判例 다수의견: i) 다른 공유자의 인도청구는 피고의 이해와 충돌한다. 보존행위를 공유자 중 1인이 단독으로 할 수 있게 한 것은 다른 공유자에게 이익이 되기 때문인점을 고려하면, 이러한 행위는 민법 265조 단서에 따른 보존행위라고 보기 어렵다. ii) 인도청구를 허용하면, 피고가 적법하게 보유하는 지분비율에 따른 사용·수익권까지 박탈하는 결과가 된다.
判例 소수의견: 소수지분권자인 피고는 다른 공유자들과의 관계에서 공유물 전부나 일부를 독점할 권리가 없으므로, 피고의 독점적 점유는 전체가 위법하다.
검토: 지분권에 기해 방해배제를 청구해 위법상태 충분히 시정 가능

{고유필수적 공동소송 template}
(고유필수적공동소송에서 공동소송참가 가부)
문제점: 유사필수적 공동소송에서 공동소송참가가 인정됨에는 이견이 없으나, 고유필수적 공동소송에서도 인정되는지 논란
긍정설: 소를 부적법 각하하고 신소를 제기하게 하는 것은 소송경제에 반한다.
부정설: 일부가 누락된 경우 부적법 각하
검토: 당사자적격은 변론종결시까지 구비하면 족하므로 참가 긍정

[공유물분할청구 소송 중 공유지분 양도]
(공변일부) 이C 6회-1-1, 이B 7회-1-3
判例 i) 공유물분할청구 소송계속 중 공유자 중 1인의 공유지분의 일부가 이전된 사안에서, ii) 변론종결시까지 81조의 승계참가나 82조의 소송인수 방식으로 iii) 일부 지분권을 이전받은 자가 소송의 당사자가 되었어야 함에도 그렇지 못한 경우 iv) 소송 전부가 부적법하다. (2013다78556)

[공유물분할청구 공유자 1인의 제소 전 사망]
(공합흠부) 이B 7회-1-3
i) 공유물분할청구는 고유필수적 공동소송으로서 ii) 공유자 전원에 대하여 판결이 합일확정되어야 하므로, iii) 공동소송인 중 1인에 소송요건의 흠이 있으면 iv) 소송 전부가 부적법하다.
(2010다105310)

III. 예비적·선택적공동소송 (70)
(법률상 양립불가능) **(법택반판)** 이C 6회-3-1
判例 i) 동일 사실관계에 대한 법률적 평가를 달리하거나 ii) 택일적 사실인정에 의해, iii) 일방의 법률효과를 긍정하거나 부정하면 다른 일방의 법률효과를 부정하거나 긍정하는 반대 결과 되는 등 iv) 각 청구에 대한 판단 과정이 필연적으로 상호 결합되어 있는 관계

(원고 청구 병합시)
判例 주위적피고에 대한 주위적청구가 인용되지 않을 경우 그와 법률상 양립불가능한 예비적 피고에 대한 청구를 인용해달라고 결합하는 것도 가능하다.

(소송법상 양립불가능) **(실개피어법)**
判例 i) 실체법적으로 뿐만 아니라 소송법상 양립할 수 없는 경우도 포함한다. ii) 개인뿐만 아니라 소속단체를 공동피고로 한 경우 iii) 누가 피고적격을 갖는지에 관한 법률적 평가에 따라 iv) 어느 한쪽에 대한 청구는 부적법하고 다른 쪽의 청구만 적법하게 되므로 v) 이는 법률상 양립할 수 없는 관계이다.

(일부판결 가부) **(일흠상누판)**
判例 i) 예비적·선택적 공동소송에서 일부 공동소송인에 관한 청구만 판결한 경우, ii) 이는 일부판결이 아닌 흠이 있는 전부판결에 해당하여 iii) 상소로써 다투어야 하고, iv) 판결에서 누락된 공동소송인은 v) 판단유탈을 시정하기 위해 상소할 이익이 있다.

(주위적 피고에 대한 소 취하시 심판범위)
判例 공동소송인 중 일부가 소를 취하하거나 일부 공동소송인들에 대한 소를 취하할 수 있고, 이 경우 소를 취하하지 않은 나머지 공동소송인에 관한 청구는 여전히 심판의 대상이 된다.

[예비적 피고 인낙·화해] 이C 6회-3-2
허용설: 70조 명문 규정이 불허하지 않으므로. 예비적 피고의 인낙·화해가 유효할 경우 i) 주위적 피고에 대한 청구 인용할 수 있다는 견해, ii) 주위적 피고에 대한 청구는 반드시 기각해야 한다는 견해
불허설: 객관적 예비적 병합에서 예비적 청구에 대해 인낙할 수 없는 것처럼.
검토: 예비적 피고가 인낙·화해로 소송을 종료시키려하는데도 이를 불허하고 주위적 피고와 함께 심판받게 하는 것은 처분권주의 反
예비적 피고 인낙시, 주위적 피고에 대해 청구도 인용할 수 있는데 이중집행은 청구이의의 소로 막을 수 있다.
(주위적 피고 인낙하는 경우, 예비적 피고에 대해 기각
예비적 피고 인낙하는 경우 주위적 피고에 대해 기각 or 인용 可)

[1인의 자백]
긍정설: 인낙이 허용된다는 70조 단서의 취지를 고려할 때
부정설: 70조가 67조를 준용하므로 소송자료의 통일이 요구되므로
검토 (절충설): 1인의 자백이 다른 공동소송인에게 유리한 점을 고려할 때 원칙적으로 허용하되, 자백이 다른 공동소송인에게 불리한 경우에는 전원이 함께 하지 않으면 효력이 없다고 할 것이다.

(조정·화해권고결정(231)의 효력) 이C 6회-3-3
원칙 **(재이확)**
判例 i) 조정에 갈음하는 결정이 확정된 경우 재판상 화해와 동일한 효력이 있으므로 ii) 그 결정에 대해 이의 안한 일부 공동소송인에 대한 관계에서는 iii) 결정이 확정될 수 있다.
(70조 단서 적용설의 입장에서)
예외 **(분공통)**
判例 i) 결정에서 분리확정을 불허하거나, ii) 결정에서 정한 사항이 공동소송인들에게 공통되는 법률관계를 형성함을 전제로 이해관계를 조절하는 경우 등 iii) 소송진행의 통일 목적으로 하는 70조1항 본문의 입법 취지에 반하면 분리확정이 불허된다.
학설 - 판례 비판 견해
조정에 갈음하는 결정은 재판의 일종이므로 70조1항 본문이 적용되어 일부 당사자만 이의한 경우에도 모든 당사자에 대해 결정이 확정되지 않는다는 견해
검토 **(재상)**
i) 당사자의 이의권이 보장되며 확정되면 재판상 화해와 동일한 효력이 있는 이상, 단서가 적용되어 원칙적으로 이의하지 않은 당사자에 대해서는 분리확정. ii) 다만, 공동소송인들 사이의 권리의무가 상호 관련된 경우 등은 예외로 할 것이다.

Ⅳ. 추가적공동소송
[규정에 없는 주관적 추가적 병합 가부] **(표필/해)**
긍정설: 당사자편의와 소송경제
부정설: 절차불안과 소송지연
判例 i) 표시정정신청을 한 경우에도 실질적으로 당사자가 변경되는 것은 허용할 수 없고, ii) 필수적 공동소송이 아닌 사건에서 소송 중에 당사자를 추가하는 것 역시 허용될 수 없다.
검토: 규정에 없는 주관적 추가적 병합의 허용은 해석론의 한계를 넘는 것이다.

<선정당사자>
(공동의 이해관계 인정범위) 이C 5회-1-1
65조 전문의 경우에만 공동의 이해관계 인정하는 견해,
65조 후문의 경우에도 주요한 공격방어방법을 공통으로 하는 경우 인정하는 견해
判例
1) 공동 이해관계의 의미 **(공주권발)**
判例 i) 공동이해관계란 다수자 상호간에 공동소송인이 될 관계에 있고, ii) 또 주요한 공격방어방법을 공통으로 하는 것을 의미하므로, iii) 다수자의 권리·의무가 동종이며 iv) 발생원인이 동종이 관계에 있는 것만으로는 공동의 이해관계라 할 수 없다.
2) 65조 후문의 경우 **(임쟁주)**
判例 i) 임차인들이 피고를 임대차계약상의 임대인이라고 주장하며 보증금반환을 청구할 경우, ii) 쟁점은 피고가 임대인으로서 계약당사자인지 여부에 있으므로, iii) 임차인들은 주요한 공격방법을 공통으로 하여 공동의 이해관계가 있다.
검토: 후문의 경우에도 주요한 공격방어방법을 공통으로 하는 경우가 있을 수 있고, 이 경우 선정으로 절차가 단순화되기 때문에 판례 타당.

(심급을 제한한 선정가부) **(총장심/강)** 이C 5회-1-1
소송종료설: 심급을 제한하면 소송 복잡하게 되어 입법목적 반함
심급한정설: 선정자는 언제라도 선정을 취소·변경할 수 있어 심급제한 허용
判例 i) 선정은 총원의 합의로써 ii) 장래를 향하여 이를 취소, 변경할 수 있는 만큼 iii) 당초부터 어떠한 심급을 한정해 선정하는 것도 허용된다
검토: 당사자의 의사에 반하면서까지 선정을 강제할 수 없는 바

('1심 소송절차에 관하여' 가 심급제한인지) 이C 5회-1-1
判例 이는 사건명과 더불어 선정당사자를 선정하는 사건을 특정하기 위한 것이고, 1심에 한정하는 것이 아니라고 해석함이 상당하다
검토: 문언을 지나치게 엄격하게 해석한다는 견해도 있으나, 실제로 사건을 특정하려고 '1심 소송절차' 라고 기재하는 경우가 있음을 고려할 때 타당.

[선정당사자 지위] **(일개)** 이C 5회-1-2
判例 i) 선정당사자는 일체의 소송행위와 사법상의 행위를 할 수 있고, ii) 이와 같은 행위를 함에 있어서 선정자의 개별적인 동의가 필요한 것은 아니다.

[묵시적 선정철회의사표시] **(명자항묵)** 곽6회-4-2
判例 i) 명시적으로 선정철회사실을 통지하지 않았더라도 ii) 선정자가 자신의 패소 부분에 대해 자신 이름으로 항소했다면, iii) 항소장 제출로써 묵시적으로 선정철회의사를 표시했다고 해석할 수 있다.

[선정자 지위]
적격유지설: 경정권을 유추해 선정당사자의 독주를 견제
적격상실설: 선정당사자에게만 소송수행권을 부여해 절차를 간소화
判例 선정당사자는 소송수행을 위한 포괄적 수권을 받은 당사자로

서 일체의 소송행위를 할 수 있으며, 선정자들은 소송수행권을 상실하고 소송관계에서 탈퇴한다.
검토: 선정자가 선정을 언제든지 취소해 스스로 소송수행권을 확보할 수 있으므로 선정자가 적격 유지한다고 볼 필요 없다.

<참가>
I. 보조참가
{보조참가 template}
[기일통지]
判例 보조참가인에게도 기일통지, 소송서류송달을 해야 하고, 참가인에게 송달하지 않아 변론 기회를 주지 않은 채 행해진 기일진행은 부적법하다. 다만, 보조참가인이 변론기일에 출석해 변론기회를 갖고, 송달받지 못한 점에 관해 이의하지 않으면, 절차진행상 흠이 치유된다.

(피참가인의 행위와 어긋날 경우의 의미) **(적소명자적)**
이C 5회-3-2
判例 i) 참가인의 행위가 피참가인의 행위와 적극적으로 배치되는 경우를 말하고 ii) 소극적으로 불일치할 때는 해당하지 않는다. iii) 피참가인이 상대방의 주장사실을 명백히 다투지 않아 iv) 그 사실을 자백한 것으로 볼 경우 v) 참가인이 그를 다투는 것은 피참가인의 행위와 적극적으로 배치된다고 할 수 없어 효력이 있다.

[보조참가인의 상소제기 기간] **(할피부/당)** 이B 6회-1-2
다수설: 당사자의 승소보조자에 불과하다는 종속성을 강조하여 피참가인의 상소기간에만
소수설: 피참가인의 승소를 도모할 참가인의 독자적 이익이 있다는 독립성 강조하여 독자적인 상소기간
判例 i) 보조참가인은 소송 진행 정도에 따라 피참가인이 할 수 없는 소송행위를 할 수 없으므로, ii) 보조참가인의 상고가 이미 피참가인에 대한 관계에 있어서 상고기간이 경과한 것이라면 iii) 보조참가인의 상고는 부적법하다.
검토: 당사자가 할 수 없는 상태에서 보조참가인이 할 수 있다고 하면 보조참가인의 지위에 맞지 않은 해석

{참가적 효력 template}
(참가효의 성질) **(공형패)** 이B 6회-1-3
i) 보조참가인이 피참가인을 보조하여 공동으로 소송을 수행했으나 패소한 경우, ii) 형평의 원칙상 보조참가인이 피참가인에게 iii) 패소판결이 부당하다고 주장할 수 없게 하는 참가적효력이다.

[화해권고결정] **(화법참)** 이B 6회-3-1
判例 화해권고결정에 의해 종료된 경우 확정판결에서와 같은 법원의 판단이 이루어졌다고 할 수 없으므로 참가적 효력이 인정되지 않는다.

[참가효의 주관적 범위] 이B 6회-1-4
참가적효력설(判): 77조는 참가인이 피참가인에게 패소판결이 부당하다고 주장할 수 없게 하는 참가적 효력만을 규정하므로 참가효는 참가인와 피참가인 사이에만 미치고, 그 판결의 기판력이 참가인과 피참가인의 상대방 사이에까지 미치지 않는다고 한다.
신기판력설: 분쟁의 반복을 막고 재판의 통일을 도모하기 위해 참가인과 피참가인의 상대방 사이에까지 기판력이 미친다. 판결이유 중 판단에 기판력을 인정함을 전제한다.
검토: 신기판력설은 77조, 216조, 218조 명문 규정에 반한다.

II. 공동소송적 보조참가
III. 공동소송참가
{대위소송 중 채무자 참가 template}
(채무자의 참가 형태) **(합적중/적중/기/경모적)** 이C 5회-4-1
공동소송적 보조참가설: 담당설의 입장에서, 대위소송 중 채무자는 기판력을 받을 자로서 합일확정 필요가 있고, 당사자적격이 있으나(병행형), 공동소송참가하면 중복소제기이므로
공동소송참가설: 담당설의 입장에서, 채무자는 기판력을 받을 자로서, 당사자적격이 있고, 참가는 중복소제기가 아니므로
보조참가설: 고유의 대위권설 입장에서, 채무자는 대위소송의 기판력을 받지 않으므로 보조참가만 가능
判例
1) 75년 전원합의체
대위소송 중 채무자에게 고지 등의 방법으로 알게 하여 공동소송적(보조)참가 기타의 방법으로 권리를 보호할 기회를 주어야 한다.
2) 주주대표소송
"주주대표소송에 판결 효력을 받는 회사가 참가할 경우 소송경제가 도모될 뿐만 아니라 판결 모순을 유발할 가능성도 없음을 고려할 때 공동소송참가로 해석함이 타당하고 중복소제기금지규정에 반하는 것도 아니다" 라고 판시한다.
검토: 동일 절차에 참가하는 것은 소송경제가 도모될 뿐 아니라 판결의 모순 가능성도 없으므로 중복소제기로 볼 수 없다. 대위통지를 받은 채무자는 당사자적격을 상실하는바 (민법 405조) 공동소송적 보조참가 타당.

(피참가인이 할 수 없는 행위 - 재심의 소취하) **(배효불취)**
判例 i) 재심의 소 취하는 더 이상 확정판결의 효력을 배제할 수 없게 하는 ii) 재판의 효력과 직접적 관련이 있는 소송행위로서 iii) 공동소송적 보조참가인에 대해 불리한 행위이다. iv) 피참가인이 재심의 소를 취하하해도 공동소송적 보조참가인의 동의가 없는 한 효력이 없다.

(피참가인이 할 수 있는 행위 - 소취하) **(유취/효불취)**
判例 i) 공동소송적 보조참가는 유사필수적 공동소송에 준하는데, ii) 이 경우 원고 중 일부가 소를 취하하는데 다른 공동소송인의 동의를 받을 필요가 없다.
iii) 소취하는 재판의 효력과 직접적 관련이 없는 소송행위로서 vi) 공동소송적 보조참가인에게 불이익이 된다고 할 수 없다. vii) 따라서 피참가인이 공동소송적 보조참가인의 동의 없이 소취하해도 유효하다.

{대위소송 중 다른 채권자 참가 template}
(소송목적 합일확정 필요여부) **(대동83적/피이대/명초동)**
법정소송담당설: 채무자가 대위소송을 안 경우 채권자들은 판결의 효력을 받으므로 합일확정 되어야 하는 경우로 본다.
고유의 대위권설: 대위소송 판결의 효력이 다른 채권자에게 미치는 것이 아니므로 합일확정이 필요한 경우가 아니다.
判例
① 채권자들의 대위소송의 경우 합일확정 요부
判例 i) 대위소송 계속 중 다른 채권자가 공동소송참가신청을 한 경우, ii) 양 청구의 소송물이 동일하다면 iii) 83조 1항의 '소송목적이 한쪽 당사자와 제3자에게 합일적으로 확정되어야 할 경우'에 해당하여 iv) 참가신청은 적법하다.
② 채권자들이 자신을 이행상대방으로 한 경우 합일확정 요부
判例 i) 소송물이 동일한지는 피대위채권이 동일한지에 따라 결정되고, ii) 채권자들이 각기 자신을 이행상대방으로 지급을 청구했더라

도 iii) 채권자들이 채무자를 대위해 변제를 수령하게 될 뿐 소송물이 다르다고 할 수 없다.
③ 일부청구임을 명시한 대위소송의 경우 합일확정 요부
判例 i) 원고가 일부청구임을 명시하여 피대위채권의 일부만 청구한 경우, ii) 참가인의 청구금액이 원고의 청구금액을 초과하지 않는 한 iii) 참가인의 청구가 원고의 청구와 소송물이 동일하여 중복되므로 합일확정 필요가 인정된다.
검토: 담당설의 입장에서 채무자가 알았을 경우 기판력이 확장되므로 합일확정의 필요가 있다.

IV. 소송고지
V. 독립당사자참가
(독립당사자 참가 의의) **(권침당/분)**
i) 소송목적의 전부나 일부가 자기의 권리라고 주장하거나, ii) 소송결과에 따라 권리가 침해된다고 주장하는 제3자가 iii) 당사자로 참가하는 것. iv) 제3자간 분쟁을 1회적으로 해결.

[이중매매] **(주소양부/주)**
적법설: 79조는 실체법적으로 유효하게 대항할 수 있는 법률상 이유가 있을 것을 요구하지 않으므로
부적법설: 원고와 참가인이 모두 승소할 수 있는 경우는 제외된다
判例 i) 참가인의 주장 자체에 의할 때 ii) 피고가 원고에 대하여 소유권이전등기의무를 지는 경우라도 iii) 참가인에 대한 소유권이전등기의무 역시 이와 양립할 수 있는 법률관계이므로 iv) 참가인의 참가신청이 참가요건을 갖추지 못하여 부적법하다
검토: 이중매매에서 원고의 청구와 참가인의 청구는 증거조사 없이 주장 자체로도 양립 가능하므로 판례 타당. 다만 사해방지참가 가능할 수도 있으므로 이를 검토

(소송결과에 따라 권리침해의 의미)
판결효설: 본소판결의 기판력이나 반사효가 제3자에게 미칠 경우
이해관계설: 소송결과로 실질상 권리침해를 받을 경우
判例 (사해의사설) "사해의사를 갖고 있다고 객관적으로 인정되고, 그 소송결과로 참가인의 권리가 침해될 염려가 있다고 인정될 경우"라고 한다.
검토: 판결효설은 참가범위를 지나치게 좁히고, 이해관계설은 보조참가의 요건과 구별이 불분명한 바 사해의사설 타당. 사해의사의 **객**관적 징표로 피고가 자백·인낙하는 등 **불**성실한 태도를 보이는 것, 주장이 **허**위로 보이는 것이 있다. **(객불허)**

[참칭채권자에 대한 청구권확인] **(채변침즉장)**
判例 i) 한 채권에 관해 서로 채권자라고 주장하는 경우, ii) 참칭채권자가 변제 받아버리면 iii) 진정채권자는 자기 권리가 침해될 우려가 있어 iv) 채권 귀속에 관해 즉시 확정 받을 필요가 있고, v) 또 채권 귀속에 관한 확인판결을 받는 것이 가장 유효·적절한 권리구제수단이다.

[상대방의 청구권부존재확인] **(독원/참원/원3)**
判例 i) 독립당사자참가인의 권리가 원고로부터 부인당한 경우 ii) 참가인은 원고를 상대로 자기 권리의 확인을 구해야 하며, iii) 원고에 대해 원고의 제3자에 대한 권리가 부존재한다는 확인을 구하는 것은 확인의 이익이 없다.

[채권자취소소송 사해방지참가 소의 이익] **(사원법/독법목)**
곽B 7회-3-2
判例 i) 채권자가 사해행위취소의 판결을 받은 경우 ii) 수익자가 채권자에 대해 원상회복의무를 부담하게 될 뿐, iii) 채권자와 채무자 사이에 법률관계가 형성되는 것은 아니다. iv) 사해행위취소를 청구하며 독립당사자참가신청을 한 경우, 참가인의 청구가 받아들여져도 v) 원고와 피고 사이의 법률관계에는 아무 영향이 없으므로 vi) 참가신청은 사해방지참가의 목적을 달성 할 수 없어 부적법하다.
학설: 사해방지참가는 채권자, 수익자, 채무자를 당사자로 하여 합일확정되는 소송임을 근거로 판례 비판하는 견해
검토: 사해행위취소소송의 본질은 취소가 아닌 원상회복에 있는 이상, 상대적 효력만 가지므로 판례 타당

(독립당사자참가 상소 이심의 범위) **(독차이/합)**
분리확정설: 처분권주의를 근거로 상소하지 않은 당사자의 소송은 이심되지 않는다.
判例 (이심설) i) 독립당사자소송에서는 세 당사자 사이에서 합일확정적인 결론을 내려야 하고, ii) 본안판결에 대해 일방이 항소한 경우에는 1심판결 전체의 확정이 차단되고 iii) 사건 전부에 관해 이심의 효력이 생긴다.
검토: 독립당사자소송은 67조가 준용되는 합일확정이 필요한 소송이므로

(독립당사자참가 상소 심판의 범위) **(합항유/각항항)** 이B 6회-3-3
(합일확정 필요한 경우)
判例 i) 합일확정을 위하여 필요한 경우에는 ii) 그 한도 내에서 항소 또는 부대항소를 제기한 바 없는 당사자에게 iii) 결과적으로 제1심판결보다 유리한 내용으로 판결이 변경되는 것도 배제할 수는 없다.
(합일확정 필요 없는 경우)
判例 i) 본소를 인용하고 참가인의 참가신청을 각하한 1심판결에 대해 참가인만 항소했는데 ii) 참가인의 항소를 기각하면서 iii) 1심판결 중 피고가 항소하지 않은 본소 부분을 취소하고 기각할 수 없다.

[일부화해] **(불효재합/이효소)** 이C 6회-4-2
(일부화해가부)
判例 i) 두 당사자의 소송행위는 나머지 1인에게 불이익이 되는 한 ii) 두 당사자 간에도 효력이 발생하지 않는다고 할 것이므로, iii) 원고·피고 사이에만 재판상 화해를 하는 것은 iv) 3자간의 합일확정 목적에 반하여 허용되지 않는다.
(1인 이의의 효력)
判例 i) 참가인이 화해권고결정에 대해 이의한 경우, 이의의 효력이 원고·피고 사이에도 미친다. ii) 따라서 결정은 참가인에 대하여 뿐 아니라 원고와 피고 사이에서도 효력이 발생하지 않고, iii) 소송은 화해권고결정 이전 상태로 돌아간다.

<당사자 변경>
I. 임의적 당사자변경
II. 소송승계
[수계 후 승계인(진정상속인) 아님이 밝혀진 경우 조치]
(1파기환/간243) 곽B 7회-4-2
소각하설: 당사자적격 흠결
수계신청각하설: 수계신청이 부적법하므로 수계재판을 취소하고 신청을 각하
수계신청기각설: 243조에 따라 수계재판을 취소하고 신청을 기각
判例 종국판결 후에 수계신청이 자격 없음이 판명된 경우 i) "제1심을 그대로 유지하여 수계신청인의 항소를 기각한 원심판결은 위법이 있으므로, ii) 원심판결을 파기하고, 제1심판결을 취소하며, iii)

수계신청인의 수계신청을 기각하고, vi) 소송이 중단된 채 제1심에 계속되어 있음을 명백히 하는 의미에서 사건을 제1심법원에 환송한다." (2000다21802)
검토: 소각하설은 진정상속인 절차는 중단되고 참칭수계인에게 소각하를 하나 이는 소송절차가 하나의 절차란 점을 간과. 수계신청 각하설은 243조 규정에 반함.

[참칭상속인에 대한 판결의 효력] **(청중기)**
判例 i) 법원이 수계재판을 취소하지 않고 수계인이 진정한 상속인이 아니어서 청구권이 없다는 이유로 본안판결 했다면 ii) 진정수계인에 대한 관계에서는 소송은 중단상태에 있지만, iii) 참칭수계인에 대한 관계에서는 판결이 확정된 이상 기판력을 가진다. (80다1895)

[인수신청 후 승계인 아님이 밝혀진 경우 조치] **(명청청인/적실분)**
이C 6회-1-2
소각하설: 당사자적격 흠결
인수신청각하설: 승계사실이 인정되지 않으면 승계요건이 흠결
청구기각설: 승계사실이 인정되지 않으면 본안문제이므로
判例 i) 인수신청시 주장하는 사실관계 자체에서 승계적격 흠결이 명백하지 않은 한 신청을 인용해야 하고, ii) 승계인 해당여부는 청구 당부와 관련해 판단할 사항으로 iii) 승계사실이 인정되지 않으면 청구기각판결을 하면 되지 iv) 인수신청 자체가 부적법해지는 것은 아니다.
검토: 당사자적격은 주장 자체로 판단하므로 소각하설X, 실제 의무자인지 여부는 신청 적법사유가 되지 않으므로 신청각하설X. 분쟁의 종국적 해결이 가능한 청구기각설 타당.

{참가승계 template}
(승계인의 범위)
구이론(判例)은 소송물이 물권적 청구권인 경우에만 계쟁물 승계인이 계쟁물 승계인이 소송승계인에 포함된다고 한다. 신이론은 소송물이 채권적 청구권인 경우도 포함된다고 한다.
생각건대 소송물이 채권적 청구권인 경우, 계쟁물 승계인은 피승계인의 상대방에게 권리·의무자가 될 수 없어 승계이익이 없으므로 판례가 타당.

{참가승계 소송형태 template}
(승계 후 甲(전주)와 丙(승계인)의 소송형태) 이B 8회-1-2
(승계사실 다툼이 없는 경우) **(독통/승인주필합/필양필)**
학설: 다툼이 없으므로 대립관계가 없는 바 통상공동소송이라는 견해
원고와 참가인의 청구가 모두 인용될 수 없는 관계이므로 대립관계로 보아 필수적 공동소송이라는 견해
判例
① 종래 判例
i) 독립당사자참가와 같은 삼면소송관계는 성립할 여지가 없고, ii) 원고의 청구과 승계참가인의 청구는 통상공동소송으로 존속한다.
② 전합 判例
i) 승계참가에서 승계된 부분에 관한 원고의 청구와 참가인의 청구는 ii) 모두 인용될 수 없기 때문에 iii) 주장 자체로 법률상 양립할 수 없다. iv) 따라서 독립당사자소송이나 예비적 공동소송처럼 필수적 공동소송을 적용해 v) 두 청구를 합일확정할 필요성이 있다.
검토: "개정법은 편면적 독립당사자참가를 허용하고 예비적 공동소송을 신설해 필수적 공동소송 규정을 준용했으므로 양립할 수 없는 청구를 하는 공동소송인들 사이에 필수적 공동소송 규정을 적용할 수 있는 근거가 마련된바" 판례가 타당.
(준용이라는 표현이 맞음)

{인수승계 template}
(추가적 인수 가부) **(건말공)** 이C 6회-1-1, 이B 7회-1-3
判例 부정 예: 건물철거소송 중 건물을 양수한 제3자에게 건물등기 말소청구 추가하는 것은 부정한다.
判例 긍정 예: 말소등기청구소송 중 피고로부터 소유권이전등기 경료한 제3자에게 말소등기청구 추가하는 것, 공유물분할청구소송 중 공유지분의 일부 이전받은 제3자를 피고로 추가하는 것은 허용한다.
검토: 판례가 모든 추가적 인수를 부정하는 것이 아니라, 소송목적인 권리·의무를 승계한 경우에는 허용한다고 평가해야 한다.

[시효중단 효력 유지여부] **(소인6재재유)**
심8회-4-3, 이B 6회-4-1, 곽B 1회-1-2
判例 i) 소송목적 양수 효력이 부정되어 iii) 인수참가인에 대한 청구기각 또는 소각하 판결이 확정된 날부터 iv) 6개월 내에 v) 탈퇴한 원고가 다시 재판상 청구를 한 경우, vi) 탈퇴 전 재판상청구로 인해 발생한 시효중단의 효력은 vii) 유지된다.
(탈퇴자에게 판결효력이 미치므로 탈퇴자가 6개월 내 청구한 것도 동일하게 취급해야 한다는 논리)

제6편【상소심절차】
제1장 총설
(상소이익) 이C 1회-1-3, 이B 7회-3-2
형식적불복설: 당사자의 신청과 주문을 비교하여 결정
실질적불복설: 실체법상 더 유리한 판결을 받을 가능성을 기준
절충설: 원고는 형식적불복설, 피고는 실질적불복설
신실질적불복설: 판결효력에 있어 불이익 입게 되는지 기준
判例 자기에게 불이익한 재판에 대해서만 상소를 제기할 수 있고, 상소인에게 불이익한지 여부는 재판의 주문을 표준으로 하여 결정되는 것이다.
검토: 실질적불복설 상소의 범위 넓어짐. 절충설 당사자 평등주의反 신실질적불복설은 예외를 인정하는 형식적불복설과 같다. 기준이 명확한 형식적불복설을 따르되 예외적으로 기판력 때문에 별소제기가 불가한 경우 상소의 이익을 인정하는 것이 타당.

[묵시적 일부청구]
(잔기전나)
判例는 i) 잔부를 유보하지 않은 묵시적 일부청구의 경우 ii) 기판력에 의해 잔부청구를 위한 후소가 불가능하기 때문에, iii) "원고는 1심에서 일부만 청구하여 전부승소한 청구에 대해서도 iv) 나머지 부분에 관하여 청구를 확장하기 위해 항소할 이익이 있다"고 한다.

(단편실항)
判例 "i) 재산상 손해나 위자료는 단일한 원인에 근거한 것인데 ii) 편의상 별개 소송물로 분류한 것에 지나지 아니하므로 iii) 이를 실질적으로 파악하여 iv) 항소심에서 위자료는 물론 소극적 손해도 청구의 확장을 허용함이 상당하다." 이 경우도 묵시적 일부청구의 논리를 이용함이 타당하다.
(이 사안에서는 추가적으로 써주면 좋은 판례)

[상계항변] **(상소기)**
i) 상계항변이 인정되어 전부승소한 피고는 ii) 소구채권 부존재를 이유로 승소한 것보다 반대채권 상실이라는 불이익이 있고, iii) 상계항변의 판단에 기판력이 발생하기 때문에 상소이익이 있다.

[청구권 경합] **(주원청불)** 이C 1회-1-3, 이B 7회-3-2
학설: 신이론은 신청을 소송물로 보아 승소판결하면 다른 청구권을 판단해도 상소이익 부정
判例 (구이론) i) 주문상으로는 원고의 전부승소로 보이나, ii) 양 청구는 청구원인이 달라 동일한 청구라 볼 수 없는 바, iii) 원고 청구는 실질적으로 인용한 것이 아니어서 iv) 판결결과가 불이익하므로 처분권주의 위배로 상소이익이 인정된다.
검토: 신이론은 법원의 실무부담이 가중되고 원고의 권리구제 불리

[대위소송 피보전채권] **(기승피)** 이C 1회-1-3, 이B 7회-3-2
判例 i) 기판력이 미치는 것은 피대위권리의 존부이고, ii) 원고가 승소한 이상, iii) 판결이유에서 피보전채권의 발생원인을 잘못 인정하였더라도 그 사유만으로는 상소의 이익이 없다.

제2장 항소

<항소 제기와 취하, 부대항소>
[항소장부본 송달불능] **(402항주각문최수/소불/주공)** 이B 8회-4-2
문제점: 소장부본 송달불능인 경우 원고에게 주소보정명령을 하고 불이행시 소장각하명령하는데 (255조 2항), 항소장부본 송달불능시 문제된다.
判例 다수의견: i) 항소장부본 송달불능시 항소심재판장은 402조 1항, 2항에 따라 항소인에게 상당한 기간을 정해 피항소인 주소보정명령하고, 불이행시 항소장각하명령 해야 한다. ii) 이 태도는 402조 1항, 2항의 문언 해석에 부합하고, iii) 항소심 진행에 필요한 최소한의 요건을 갖추지 않는 데 대한 제재의 의미이며, iv) 항소인에게 수인 못할 과중할 부담을 부과한 것도 아니다.
判例 소수의견: i) 항소장부본 송달불능은 소송 계속 중 서류가 송달불능된 것에 불과한 점, ii) 불이익을 항소인에게만 돌리는 것은 부당한 점을 고려할 때 다수의견 부당하다.
검토: 항소인은 주소보정명령을 근거로 관계기관에 피항소인의 주민등록표 교부신청 할 수 있으며, 공시송달신청으로써 보정명령을 이행할 수도 있다.

[항소취하 후 재항소] **(후만확/전내다)** 곽7회1-1
1) 항소취하 효과
判例 항소취하가 있으면 소송은 처음부터 항소심에 계속되지 않은 것이나, 소취하와 달리 1심 종국판결이 유효하게 존재한다.
2) 항소취하 후 재항소
判例 i) 항소기간 경과 후 항소취하가 있는 경우, 항소기간 만료시로 소급하여 1심판결이 확정되나, ii) 항소기간 경과 전에 항소취하가 있는 경우, 판결은 확정되지 않고 항소기간 내라면 항소인은 다시 항소제기가 가능하다.

[항소 일부취하] **(전일효/일불변효)**
1) 항소 일부취하 가부
判例 "항소취하는 항소 전부에 대해 해야 하고 항소의 일부취하는 효력이 없다." 항소제기는 상소불가분원칙에 의해 모든 청구에 미치기 때문이다.
2) 항소취지감축이 항소 일부취하인지
判例 i) 항소 중 일부에 대한 불복신청을 철회했더라도 ii) 단지 불복 범위를 감축해 심판대상을 변경하는 효과를 가져올 뿐, iii) 항소심 변론종결시까지 언제든지 서면 또는 구술에 의해 불복범위를 다시 확장할 수 있는 이상 iv) 항소 자체의 효력에는 아무런 영향이 없다.

[파기환송 후 항소취하] **(파항종부/부은)**
긍정설: 393조 명문에 따라 파기환송 후 항소취하 가능
부정설: 부대항소 소멸로 부대항소인에게 가혹하고, 항소인이 환송판결의 기속력을 허물게 되어 부당
判例 i) 항소심 판결이 파기환송된 경우, ii) 항소심 판결이 없었던 것과 같은 상태로 돌아가므로, iii) 새 종국판결이 있기까지는 iv) 항소인은 피항소인이 부대항소했는지 여부와 관계없이 항소를 취하할 수 있다.
검토: 항소취하 때문에 피항소인이 부대항소의 이익을 잃어도 이는 본래 상대방의 항소에 의존한 은혜적인 것으로 어쩔 수 없다.
(393조에서 항소심 종국판결이 있기 전까지 항소취하할 수 있다고 규정했으므로 파기환송되면 이전 종국판결은 없어졌고, 새 종국판결이 있기 전까지 항소취하할 수 있다는 의미)

(부대항소의 성질)
항소설: 부대항소도 항소로 보아 항소이익 필요하다
비항소설: 부대항소는 특수한 구제방법이고 항소가 항소이익 필요 없다.
判例 1심에서 전부승소한 원고도 피고만 항소한 경우 청구취지를 확장·변경할 수 있고 그것이 피고에게 불리하게 되는 한도 내에서 부대항소를 한 취지로 보아야 한다.
검토: 부대항소에 의해 항소심절차가 개시되는 것은 아니므로

<항소심 심리>
<항소심 종국적 재판>
[소각하판결] **(각심청항/잘경)** 이C8회-4-1, 이B 8회-2-2
항소기각설: 불이익변경금지원칙상 원판결 취소하고 청구기각 할 수 없으므로 항소기각
환송설: 심급의 이익을 보장하기 위해 418본문에 따라 환송
청구기각설: 소각하판결에 대해 원고가 항소하는 것은 본안판결을 요구한 것이므로 418단서 요건이 갖춰지면 원판결 취소하고 청구기각 가능
判例 i) 소각하한 1심판결에 대해 원고만 항소했으나 ii) 심리결과 청구가 이유 없는 경우 iii) 1심판결을 취소하여 청구기각하면 항소인인 원고에게 불이익한 결과가 되어 부당하므로 iv) 항소기각해야 한다.
검토: 항소기각설은 잘못된 1심판결 확정하는 문제, 환송설은 소송경제에 反,

[상계항변 인용판결]
(상계항변 인용판결에 대해 원고만이 항소한 경우) **(소청불)**
判例 항소심이 소구채권의 발생이 인정되지 않는다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 것은, 항소인인 원고에게 불이익하게 1심 판결을 변경한 것이다.

(상계항변 인용판결에 대해 피고만이 항소한 경우) **(자배불)**
判例 항소심이 1심이 자동채권으로 인정했던 부분을 인정하지 않고 상계항변을 배척했다면, 항소인인 피고에게 불이익하게 1심 판결을 변경한 것이다.

제3장 상고

(파기이유 전제로 판단되는 경우) **(피본피논기)**
判例 i) 대위소송에서 피보전채권은 소송요건으로서 직권조사사항이므로, ii) 환송판결이 본안에 관해서만 판단했어도, iii) 이는 피보전채권이 있어 소송요건을 구비했다는 판단을 iv) 당연한 논리적 전제로 하므로 v) 환송판결의 기속력은 청구가 소송요건을 구비한 적법한 것이라는 판단에도 미친다.

제4장 항고

[결정이나 명령 고지 전에 항고제기]
(성고고성효/444시효/다)
判例 다수의견: i) 이미 성립한 결정에 불복하여 제기한 즉시항고가 ii) 결정의 고지 전에 이루어져 부적법하다고 하면 iii) 고지 후 즉시항고를 다시 제기하도록 하는 부담을 지우는 것이 되므로, iv) 성립한 결정에 대해서는 v) 고지되어 효력이 발생하기 전에도 항고할 수 있다.
判例 소수의견: i) 민사소송법 444조1항과 민사집행법 15조2항은 ii) 즉시항고기간에 관하여 종기뿐 아니라 시기도 규정한 것으로 새겨야하므로, iii) 결정이 송달되어 효력이 발생한 후에만 항고 제기할 수 있다.
검토: 고지 전의 즉시항고가 부적법하면, 다시 즉시항고하려는 시점에서는 즉시항고 기간이 경과할 수 있다.

제7편【재심절차】

{재심 판례 사안 template 1}
(재심사유 451①1호 해당여부) **(재전법합소)**
判例 i) 재심대상 대법원판결에서 표시한 의견이 ii) 그 전에 선고된 대법원판결에서 표시한 의견을 변경하는 것이라면 iii) 법원조직법에 의해 iv) 대법관 전원의 3분의 2이상의 합의체에서 심판했어야 할 것인데, v) 소부에서 심판했다면 1호 재심사유에 해당한다.

(환송판결이 '확정된' 종국판결인지) **(형직실/소)**
긍정설: 환송 후 하급심에서 환송판결의 재심사유를 다투게 하면 심급제도 본질에 반한다
부정설: 재심을 인정하면 환송판결 후의 항소심 절차를 소멸시켜야 하는데, 실정법상 그 장치가 없다.
判例 환송판결은 형식적으로 보면 확정된 종국판결이지만, 직접적으로 기판력, 형성력, 집행력이 생기지 아니하므로 실질적으로 확정된 종국판결이라고 할 수 없다.
검토: 환송판결은 소송물에 관한 기판력이 없으므로 부정설 타당.

{재심 판례 사안 template 2} 이B 8회-3-2
(재심판결에 재심사유 있는 경우 조치) **(재재본종)**
判例 i) 재심판결에 대한 재심의 소에서 ii) 재심사유가 있다고 인정하여 iii) 본안에 관해 심리한다는 것은 iv) 종전 재심청구에 관한 변론을 재개해 속행하는 것이다.

(원래확정판결에 재심사유 없는 경우 조치) **(종확재종)**
判例 i) 종전 재심청구에 관해 다시 심리한 결과 ii) 원래 확정판결에 재심사유가 인정되지 않을 경우에는 iii) 재심판결을 취소하고 iv) 종전 재심청구를 기각해야 한다.

{재심 판례 사안 template 3} 이B 8회-4-1
(재심의 소 제기기간 판단) **(수이다기)**
判例 i) 법인 대표자가 포기·인낙·화해를 하는 데 필요한 수권을 받지 않고 한 경우, ii) 법인의 이익을 정당하게 보전할 권한을 가진 iii) 다른 임원이 그 준재심사유를 안 때 iv) 비로소 준재심 제기기간이 진행된다.